

특허청구범위에 대해

특허청구범위에 대해

< 차례 >

1. 특허청구범위의 의의 -----	3
1) 의의	
2) 특허청구범위 기재의 중요성	
2. 특허청구범위의 역할 -----	4
1) 보호범위적 기능과 구성요건적 기능	
2) 각 주체에 따른 특허청구범위의 역할	
3. 특허청구범위의 기재방법 -----	7
1) 일반적인 사항	
2) 특허청구범위의 기재형식	
4. 다항제에 따른 기재방법 -----	19
1) 다항제의 장·단점	
2) 법규정에 의한 기재	
3) 청구항 기재시 유의사항	
4) 다항제에 따른 특허법상 타제도와의 관계	
5) 실용신안법상 다항제와의 비교	
5. 특허청구범위의 해석 -----	37
1) 해석의 필요성	
2) 해석의 일반원칙	
3) 제반 학설	
4) 주변한정주의와 중심한정주의	
5) 균등론과 금반언의 원칙	
6) 해석의 기준	
7) 미국 특허법 해석상의 균등론과 금반언의 원칙	
6. 청구항 작성시 유의사항 -----	49
1) 신규성과 진보성	
2) 청구항의 도입부	
3) 특허침해에서의 청구항 해석	
* <참고자료> -----	72
* [참고문헌] -----	76

1. 특허청구범위의 의의

1) 의의

특허제도는 신규한 발명의 공개의 대가로 독점권을 부여하는 것이다. 그리고 발명이란 자연법칙을 이용한 무형의 기술적 사상으로서, 구체적이고 객관적인 파악을 위한 입법 기술이 필요해진다.

따라서 특허법은 특허를 받고자 하는 자로 하여금 명세서 및 도면에 보호를 받고자 하는 발명을 법이 요구하는 정도에 부합되도록 충분히 기재하여 제출하도록 하고 있다. 이중 특허청구범위는 보호범위를 정하는 기준이 될 뿐만 아니라 심사의 대상을 특정하는 역할을 하게 된다.

그래서 출원발명의 기술적 내용을 독점권을 가지는 특허로서 인정받기 위해서는 특정된 기술내용과 출원인이 밝히는 발명의 범위, 정확하게는 발명기술의 기술적 경계가 확정되어 있어야 한다. 독점권 부여와 발명내용의 공개를 목적으로 하는 특허제도의 원활한 운영을 위해서도 특허출원인과 일반 공중 양자의 이익의 형평이 중요한 사안이 될 수밖에 없는데, 일반 공중에게 돌아가는 이익은 발명의 상세한 설명이 주가 되어 표현되는 것이고, 특허출원인의 이익은 특허청구범위로서 표현되는 것이다.

이러한 특허청구범위는 독점권을 설정해주는 핵심이 되는 사항이기 때문에, 특허청구범위는 특허권 소유자와 일반 공중에게 미치는 영향이 지대하다. 즉, 발명내용 이상의 권리범위를 설정해 주면 일반 공중이 불측의 손실을 입을 수 있고, 발명내용을 너무 축소하여 권리를 부여하게 되면 발명자의 발명의욕저하 등의 부작용이 우려되므로 특허청구범위의 설정은 신중하게 해야 한다.

특허제도는 공익과 사익의 형량에 의한 원활한 운영을 통하여 궁극적으로는 산업발전을 도모하는 것이다. 그러한 관점에서 볼 때 특허청구범위의 운영취지는 특허제도의 취지를 그대로 표현하는 것임을 알 수 있다. 과거 특허제도 시초부터 특허청구범위가 존재한 것은 아니었다. 제도의 운영과정에서 도출되는 특허권의 침해에의 합리적인 대응의 필요성에 의해서 출현한 것이 특허청구범위이다.

2) 특허청구범위 기재의 중요성

특허청구범위는 앞으로 권리를 주장할 수 있는 범위이므로 어떻게 작성하느냐에 따라 그 권리의 효력의 범위가 좌우된다.

타인이 특허권을 침해하였다 하여 특허권자가 경찰서 등에 특허권침해죄로 고소하였을 때 또는 침해금지나 손해배상 등을 청구하였을 때에 경찰수사 담당관·검사 및 판사는 타인이 제조·판매하고 있는 물건과 특허권의 청구범위와 동일유사한가를 판단하게 되므로 특허청구범위의 작성은 매우 중요하다. 특허청구범위가 공지·공용된 사항, 불특허사항, 명확하고 간결하게 기재되지 아니한 사항을 가지고 특허권침해죄로 하게 되면 침해가 되지 않을 뿐만 아니라 오히려 무고죄가 성립될 우려가 있다.

또 특허청에 무효심판이나 권리범위확인심판이 청구되었을 때에도 특허청심판관·심사관이 먼저 검토하는 사항이 바로 특허청구범위이므로 특허청구범위를 기술적으로 잘 작성하여야 한다.

2. 특허청구범위의 역할

1) 보호범위적 기능과 구성요건적 기능

특허청구범위는 명세서 중에서 가장 중요한 부분으로 발명의 보호범위적 기능과 발명의 구성요건적 기능을 수행할 수 있도록 발명의 상세한 설명란에 기재된 발명범위보다 넓지 않게 보호를 요구하는 사항은 빠짐없이 기재할 필요가 있다.

(1) 보호범위적 기능

특허청구범위는 그 이름이 나타내듯이 출원인이 특허를 청구하고 싶은 범위, 즉 특허권으로서 보호를 요구하는 범위이다. 바꾸어 말하면 타인이 이것을 침해할 때에는 특허권을 침해하는 것이 되는 구역(출입금지지역)이다. 이상의 견지에서 특허청구범위는 특허권이 미치는 기술적 범위를 정하는 기준으로 해야 한다는 것은 당연하며, 특허법 제97조의 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다”는 이것을 다짐하기 위해 명확하게 한 것이라고 해석된다(이하, 이 같은 기능을 ‘보호범위적 기능’이라고 한다).

따라서 발명의 상세한 설명에만 기재하고, 특허청구범위에 기재하지 않은 발명은 특허권으로서의 보호를 요구할 수 없으며, 특허청구범위를 좁은 범위를 기재할 때에는 비록 발명의 상세한 설명 중에 넓은 범위의 발명을 기재했다고 해도 좁은 범위의 보호밖에 받을 수 없다.

(2) 구성요건적 기능

특허청구범위에서 기재해야 할 것은 발명의 상세한 설명 중에 기재된 발명의 목적·효과 등을 제외하고 발명의 구성만으로, 더구나 그 구성 중 오로지 그 발명의 구성에 없어서는 안 될 사항만으로도 아니면 안 된다(이하 이 같은 기능을 ‘구성요건적 기능’이라고 한다).

특허법은 이것에 대하여 “특허청구범위에는 발명의 상세한 설명에 기재한 발명의 구성에 없어서는 아니 될 사항만을 기재하여야 한다”고 규정하고 있다.

2) 각 주체에 따른 특허청구범위의 역할

(1) 출원인의 입장에서 본 역할 (보호범위적 기능)

① 권리요구서로서의 역할

특허청구범위는 특허출원인이 특허발명을 보호받고자 하는 범위로서 특허 후 권리서로서의 역할을 하는 부분이므로 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재하여야 한다(§42④).

② 제3자의 특허(실용신안등록) 금지적 역할

선원주의 판단은 선원의 특허청구범위(실용신안등록청구범위)와 후원의 특허청구범위(실용신안등록청구범위)를 비교하여 판단한다.

(2) 특허권자의 입장에서 본 역할 (보호범위적 기능)

① 제3자의 실시금지적 역할

특허권자는 특허청구범위에 기재된 발명뿐만 아니라 이와 동일성 범위의 발명을 업으로서 실시하는 것을 독점하며, 제3자가 정당한 이유 없이 특허청구범위에 기재된 발명 또는 이와 동일성

범위의 발명을 업으로서 실시하는 것을 금지할 수 있다.

② 특허발명의 보호범위의 판단기준 (침해여부의 판단기준)

특허발명의 보호범위라 함은 특허발명이 법으로서 보호받을 수 있는 범위를 의미한다. 특허법 제97조에서 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다”고 규정하여 새로운 발명으로서 특허 받을 만한 발명이라 하더라도 그것이 발명의 상세한 설명에만 기재되고 특허청구범위에 여러 개의 구성요건이 기재되었을 경우 이들이 결합하여 전체적으로 하나의 권리로서 보호되는 것이지 각각의 구성요건에 대하여 보호되는 것은 아니며, 이를 ‘1 클레임 1 권리의 원칙’ 또는 ‘권리일체의 원칙’이라 한다. 그러나 이와 같은 원칙이 특허청구범위가 여러 개의 항으로 기재되었을 경우 그 여러 개의 항이 전체적으로 하나의 권리임을 뜻하는 것은 아니며, 각각의 청구항마다 권리가 인정되는 것임은 물론이다.

(3) 특허청의 입장에서 본 역할

① 불수리처분의 대상

명세서에 특허청구범위가 기재되어 있지 아니한 경우 불수리사유에 해당된다.

② 구성요건적 기능

특허청구범위의 구성요건적 기능이라 함은 특허청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항은 모두 기재하여야 하는 것을 의미한다. 특허법 제42조 4항에서 규정한 “발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항”이라 함은 발명의 구성상 필수불가결한 구성요소를 의미하며, 이와 같이 발명의 구성상 필수불가결한 구성요소가 누락되었을 경우에는 명세서 기재불비(§42④) 위반을 이유로 거절이유나 무효사유가 된다. 따라서 특허청구범위가 구성요건적 기능을 다하기 위하여는 특허청구범위는 다음과 같이 기재할 필요가 있다.

(i) 구성요건 전부를 기재할 것

특허청구범위에는 특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항(발명의 구성상 필수불가결한 요소)은 이를 모두 기재하여야 한다.

예컨대, 발명이 A, B, C, D, E의 요소로 구성되는 발명의 경우 그 중 어느 하나의 구성요소의 기재 결(缺)하였을 경우에는 특허법 제42조 4항에 위반되며, 또 그 발명은 구성요건의 결여로 인하여 구성상 상호간에 유기적인 결합이나 공동작용관계가 이루어질 수 없으므로 산업상 이용할 수 없는 발명(미완성발명)으로 인식되거나 신규성, 진보성(신규항 구성요소를 결하였을 경우)이 없는 발명으로 취급되게 된다.

또한 이와 같은 구성요건을 기재함에 있어서는 그 구성요소 상호간의 유기적인 결합관계나 공동작용관계를 기재하여야 하며, 단순히 그 구성요소만을 나열하듯이 기재한 것은 특허법 제42조 4항에 위반된다.

(ii) 구성요건만을 기재할 것

구성요건만을 기재한다 함은 특허청구범위에는 발명의 구성상 필수구성요건만을 기재함을 의미하며, 필수구성요건이 아닌 발명의 작용효과나 부수사항, 실시예 등을 특허청구범위에 기재하면 안 된다. 이와 같이 필수구성범위만을 특허청구범위에 기재토록 한 것은 쓸데없는 사항을 특허청구범위에 기재할 경우 특허청구범위 해석의 혼란으로 발명의 요지 파악이나 특허분쟁 등에 있어 특허청구범위 해석에 어려움이 있기 때문이다.

(iii) 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것

특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 기재된 사항의 범위 내에서 기재하여야 한다. 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항, 즉 발명의 상세한 설명의 범위를 넘어서 특허청구범위를 기재한 경우에는 특허법 제42조 4항 위반을 이유로 거절이유나 무효사유가 된다. 이와 같이 특허청구범위를 발명의 상세한 설명의 범위 내에서 기재토록 한 것은 사회 일반에 공개되지 아니한 발

명에 대하여 독점적 권리를 인정하여 주는 결과가 되어 부당하기 때문이다.

③ 신규성의 판단대상

신규성 판단은 공지발명과 특허청구범위에 기재된 발명을 비교하여 발명의 동일성 판단방법에 의하여 판단한다.

④ 확대된 선원의 지위의 판단대상

선출원의 내용과 후출원의 특허청구범위를 비교하여 발명의 동일 판단방법에 의하여 판단한다.

⑤ 선원주의 판단대상

⑥ 다항제 기재방법(§42⑤)의 판단대상

⑦ 1특허출원의 범위(§45)의 판단대상

⑧ 보정(요지변경) 여부의 판단대상

특허청구범위에 기재된 구성요건을 변경하거나 다른 구성요건을 추가하는 것은 요지변경이 된다.

⑨ 분할·변경 여부의 판단기준

⑩ 권리범위확인의 판단(보호범위의 판단)기준

⑪ 정정심판의 판단기준

(4) 제3자의 입장에서 본 역할

① 정보제공대상

② 이의신청의 대상

③ 무효심판청구 대상

④ 정정무효심판청구 대상

⑤ 권리범위확인심판청구 대상

⑥ 통상실시권허여심판청구 대상

⑦ 소극적 효력의 제한 대상

참고로 발명의 카테고리(category, 범주)를 살펴보면 다음과 같다.

우리 나라 특허법에서는 발명의 대상을 특정하는 것으로 i) 물의 발명, ii) 방법의 발명, iii) 물을 생산하는 방법의 발명(특허법 제2조 3항)으로 구분하고 있다. 이는 발명의 대상에 따른 구별이며, 후술하는 특허청구범위에 기재된 기술적인 구성의 형식에 따른 구분이다. 그리고 물의 발명은 다시 i) 기계·기구·장치 등의 발명과, ii) 물질의 발명, iii) 조성에 특징이 있는 발명으로 분류된다. 방법의 발명은 원칙적으로 일정한 목적을 달성하기 위한 수단이 시계열적인 처리과정으로 되어 있는 점에서 물의 발명과 구분된다. 관행상 특허법상 발명의 카테고리는 위의 것 외에는 인정하지 않고 있다. 발명은 그 카테고리에 따라 분류할 수 있지만 이것은 발명의 특허청구범위의 표현형식에 따라서 분류된다. 즉 발명의 카테고리의 결정은 발명의 대상의 특징에 따라서 정해지는 것이지만 때로는 특허출원인의 주관적인 판단에 의해서 선택되어지는 경우도 있다.

미국의 특허법에서는 “방법(process), 기계(machine), 제조품(manufacture), 결합체 (또는 조성물)(composition of matter), 재료(material)의 새로운 용도(new use)”로 표현하여 구분하고 있다.(미국 특허법 제100조)

3. 특허청구범위의 기재방법

1) 일반적인 사항

특허청구범위의 작성에 관한 것은 그 형태(다항제, 단항제)에 관계없이 설명된다. 특허청구범위의 작성과 해석은 상호 보완관계에 있다. 그러나 양자의 영역은 상당한 차이가 있다고 볼 수 있다.

특허출원의 단계에서는 특허 받기 위한 것이므로 '작성'의 면이 중요하다. 그러나 특허청구범위는 결국 해석을 받기 위해서 작성되는 것이라고 볼 수 있으므로 청구범위의 작성과 해석을 명확히 구분되는 별도의 개념이라고 보기에는 곤란하다.

특허청구범위의 작성은 다항제에서는 독립항과 이 독립항을 인용한 1 또는 2 이상의 종속항으로 기재하고 이러한 형태를 1 또는 복수개 기재하는 것이다. 단항제 형태로 독립항 1항만 기재하든 또는 다항으로 기재하든 출원인의 선택은 자유롭다. 그러나 바람직한 기재방법은 역시 발명내용을 최대한의 권리로 할 수 있도록 다항으로 기재하는 것이다. 다항제이든 단항제의 청구범위이든 하나의 독립항을 기재하는 형식은 공통적으로 적용된다고 볼 수 있다. 특허청구범위를 작성하는데 고려하여야 할 일반적인 사항에 대하여 설명하기로 한다.¹⁾

① 먼저 다항제인 경우 그 발명의 주가 되는 청구범위(독립항)는 그 권리범위를 선행기술이 허용하는 한 넓게 기재하는 것이 실질적으로 발명을 보호받을 수 있는 바람직한 방법이다. 넓은 청구범위를 작성하기 위한 방법으로는 첫째, 독립항의 청구범위에 기재되는 발명 구성요소의 수를 최대한 줄인다. 즉 발명을 이루는 구성요소의 수가 적을수록 그 발명이 미치는 범위는 넓게 된다.

예컨대 발명이 $[A+B+C+D+E+F]$ 와 같이 6개의 구성요건으로 이루어진 것이라면 유사한 기능을 발휘하는 영역을 한데 묶는다. 즉 $[(AB)+(CD)+(EF)]$ 와 같이 묶어서 이를 $[X+Y+Z]$ 로 하여 특허청구범위에 기재하는 것을 발명의 구성요건의 수를 줄였다고 일컫는다.

둘째, 그 수를 최소화한 각각의 구성요소의 기술적 영역을 최대한 넓힌다. 즉 그 구성요소를 구체화하지 말고 그 분야의 일반적인 용어로서 기재함으로써 청구범위의 권리범위가 확장되도록 하는 것이다.²⁾

위의 예에서 구성요건의 하나인 $[Y]$ 가 $[X]$ 와 $[Z]$ 에 상호 연결되어 회전력을 전달하는 장치(톱니바퀴, 벨트, 체인 등)라 할 때 이 구성요건 $[Y]$ 의 기술적 영역을 최대한 넓힌다는 의미는 회전력을 전달하는 구체적인 수단인 톱니바퀴 또는 벨트나 체인 등으로 기재하는 것이 아니라 이들을 모두 포함하는 용어, 즉 "동력전달장치"와 같이 기재하는 것을 의미한다.

여기서 "구성요건"이란 발명의 구성을 이루는 개개의 독립된 요소를 의미한다. 예컨대 전자회

1) 참고로 카테고리에 대한 우리 나라의 미국의 구별은 다음과 같다. 먼저, 우리 나라는 특허법 제2조 3항에서 물건/방법/물건을 생산하는 방법의 발명으로 구별한다. 그리고 물건의 발명은 다시 기계·기구·장치/물질/조성에 특징이 있는 발명으로 구분한다. 미국의 특허법 제100조에는 방법(process)/기계(machine)/제조품(manufacture)/조성물(또는 결합체)(composition of matter)의 발명으로 구별한다.

2) 이렇게 권리범위가 넓어진다는 것은 종래기술과의 충돌가능성이 커진다는 이야기와 동일하다. 그래서 기술적 영역을 넓혀 권리범위를 확장할 때는 종래기술의 침해여부에 대해 신중을 기하여야 한다.

로에서는 어떤 기능을 하는 회로 전체를 이루는 각각의 부품(소자) 하나하나가 구성요건이 될 수 있고, 또한 그 회로 내에서 특정기능을 하는데 필요한 소자끼리 묶어질 때(블록) 그 묶음 하나 하나가 구성요건이 된다. 즉 구성요건의 상호 결합을 했을 때에 발명의 전체구성이 완성된다. 구성요소라고 하는 것도 구성요건과 같은 의미로 사용(심사.심판실무상)된다.

② 청구범위는 발명의 목적을 실시할 수 있을 정도로 구성요소를 명확하고 충분하게 기재하여야 한다. 특허제도의 취지상 공익과 사익의 경계라고도 볼 수 있는 특허청구범위에 대하여, 심사시에 심사관은 그 권리범위를 일차 확정지어주는 역할을 하므로 심사관에게 충분히 설득될 수 있을 만큼 그 구성요소가 충분하게 기재되어 있어야 한다는 의미이다. 또한 각 구성요소에 대한 장황한 설명은 피하고 가능한 한 간결하게 기재하는 것이 필요하다.

③ 청구범위에 기재되는 상기의 각 구성요소들은 그 상호간의 결합관계가 유기적 혹은 논리적으로 이루어져야 한다. 복수의 구성요소가 상호 아무런 작용을 하지 않는 것이 결합(주합 또는 집합이라고 한다)되어 있다든지 하는 것은 소위 유기적인 결합으로 볼 수 없고, 또한 육지와 섬처럼 하나 또는 복수개의 구성요소가 결합되지 않고(특성상 결합되지 않는 것은 제외한다) 떨어져서 구성요소가 나열식으로 기재된 경우도 역시 유기적이라거나 논리적인 결합이 아니다. 다시 말하면 유기적 결합이라는 것은 결합되는 구성요소간에 상호 작용이 있는 소위 특허성 있는 결합을 의미한다.

여기서 주합(湊合, aggregation)과 결합(結合, combination)을 설명해보자.

발명은 복수개의 구성요건의 상호결합에 의해서 완성되는 것이 일반적이다. 그러나 그 결합의 양태는 특허성 있는 결합과 특허성 없는 결합으로 구별된다. 여기서 후자를 주합이라고 한다. 주합은 복수개의 구성요건 각각이 자기의 독자적인 기능을 하고 있을 뿐 이들 구성요건의 결합 후에도 상호간에 어떠한 영향을 끼치거나 상호작용이 없는 상태의 결합을 의미한다(예컨대, 세탁기 위에 단순히 시계를 부착했다거나, TV세트 전면에 취침전 등을 부착한 것 등). 즉 주합은 단지 보통의 접합수단으로 각 구성요소들을 나열하거나 결합함으로써 단순한 편리함만을 제공할 뿐인 결합이다. 그러나 특허성 있는 결합은 각 구성요소의 결합으로 상호조정, 상호작용을 특징 또는 목적으로 하여 발명의 목적을 제대로 수행하도록 결합된 것이다.

그리고 발명의 기능적인 설명이 주가 되는 기재형식은 피해야 할 것이다. 출원인은 특허청구범위를 가능한 한 넓게 작성하기 위해서 발명의 내용을 기능적, 즉 작용효과를 강조하는 기재형식을 채용하기 쉽다. 발명의 목적 또는 효과를 달성하는데 필요한 구성을 명확하게 청구범위로 기재하는 것이 아니라 기능을 위주로 하여 기재하는 것은 그 발명의 권리범위가 불명확해서 재산권으로 형성되기에는 부적당하다. 그러나 자신의 발명을 실시 가능할 정도로 기재하자면 각각 구성요소의 설명에 덧붙여서 기능에 대한 설명이 추가되는 것은 피할 수 없다. 이러한 기재방법은 오히려 권장할 만한 것이라고 생각되나, 순수기능만을 기재한다던가, 상호결합이 불명료한 소수의 구성요소에 대한 기능을 장황하게 기재한 특허청구범위의 기재방법은 피해야 한다.

기능이 추가된 청구범위를 인정할 수밖에 없는 경우에도 그 기능을 실현하는 구체적인 수단은 명세서의 상세한 설명이 기재되어야 한다.

④ 청구범위에 기재되는 발명의 기술내용은 명세서의 상세한 설명과 첨부된 도면에 명확하게 설명되어 있는 것이어야 한다. 즉 명세서의 상세한 설명에는 없던 내용 또는 용어가 돌발적으로 청구범위에 나타난다던가 하면 안 된다.

⑤ 가능한 한 특허청구범위에 사용되는 기술의 한정용어(발명의 카테고리를 표현하는 용어)는 발명의 명칭과 일치시키는 것이 바람직하다.

⑥ 작성대상을 누구를 기준으로 할 것인가? 특히 미국출원의 경우 청구항은 소송 관점에서 작성되어야 한다. 특허심사관에게 받아들여진 클레임 언어가 판사나 배심원에게는 불확실하게 느껴질 수 있다.

2) 특허청구범위의 기재형식

특허청구범위는 명세서의 발명의 상세한 설명에서 충분히 설명되는 발명의 목적, 구성 및 효과를 전부 기재한다던가, 아니면 이 3요소 중 어느 하나 혹은 둘을 기재하는 형식이 아니다. 즉 특허청구범위는 당해 발명의 이점 등을 기재하는 것이 아니라는 의미이다. 그러므로 특허청구범위의 기재는 발명의 내용을 이해할 수 있도록 기재되어야 함은 물론이고, 출원인이 원하는 권리의 범위가 명확하게 영역 지어지도록 기재하여야 한다.

통상적으로 발명의 상세한 설명 중에 특허청구범위에 기재될 사항이 이미 포함되어 있는 경우가 대부분이지만 꼭 그러한 형식으로 기재해야 하는 것은 아니다. 즉 특허청구범위의 기재형식에 대한 획일적인 모델이 정해져 있지 않다.

청구범위의 형태가 다항제에 의한 것인가 아니면 단항제에 의한 것인가에 따라서 기재형식이 구분될 수도 있지만, 여기에 구매됨이 없이 더 포괄적인 특허청구범위의 기재형식에 대하여 설명되어야 한다. 왜냐하면 특허청구범위의 기재형식은 발명의 내용을 어떻게 하면 실질적으로 보호받을 수 있도록 기재하느냐 하는 것이 관건이기 때문이다. 결국 보호받을 수 있는 권리범위를 정하여 기재하는 방법에 따른 구분은 차후에 특허권이 설정되고, 이에 대해서 타인과 권리의 다툼이 발생했을 때에 문제가 된 특허청구범위의 권리의 한계를 어떻게 해석하느냐 하는 특허청구범위의 해석으로 귀결된다.

그러므로 특허청구범위를 기재할 때에는 해석의 방법이 당해 국가에서 어떻게 운용되고 있는가를 판단하고 기재하여야 한다. 여기에서 당해 국가란 특허청구범위를 최종적으로 확정해줄 수 있는 곳, 즉 우리 나라 대법원 같은 곳이다.

특허청구범위의 해석의 양태에 따른 기재의 형식을 구분해 보는 것이 이 기재형식의 구분에 관한 대표성을 인정해준는데 무리가 없다고 본다. 일반적으로 법제의 대립이나 비교판단을 함에 있어서는 영미법 계통의 법제와 대륙법 계통의 법제로 명확하게 구분된다. 특허법제 역시 예외는 아니어서 다른 어떤 기준보다도 양자의 법제의 차이에서 구별이 뚜렷하다. 독일 등을 대표로 할 수 있는 대륙법계에서의 특허청구범위의 해석에 관한 기준은 소위 중심한정주의와 현재의 미국 등을 대표로 하는 영미법계의 주변한정주의에 의한 특허청구범위의 해석의 차이에 의해서 청구범위 기재형식이 뚜렷하게 구별되어 온 것이 사실이다. 상기의 양자의 차이에 의한 특허청구범위 기재형식의 구별을 야기한 특허청구범위의 해석에 대해서는 항을 바꾸어 설명하기로 한다.

(1) 일반적인 기재형식

특허청구범위(다항으로 기재되어 있는 경우에는 하나의 청구항을 말한다)는 일반적으로 단일의 문장으로 기재하고 전제부, 특징부, 연결부, 종결부 순의 기재 형식으로 작성할 수 있다.

전제부	특징부	연결부	종결부
<-----+-----+-----+----->			
발명의 요약	발명의 핵심	연결용어	특징적 용어
공지 기술	- 기술적 구성	- 포함된	- 주로 명칭 사용
발명의 기술분야		- 구성된	

① 전제부(또는 도입부)

전제부에는 발명의 기술분야, 발명의 공지기술 또는 발명의 요약 등을 기재하는 것으로 통상 문맥을 매끄럽게 하기 위한 것이고, 작성자가 사용하는 청구범위의 형태에 따라 길거나 짧을 수 있다.(전제부에 대한 해석은 '6-2) 청구항의 도입부' 참조)

물론 이러한 전제부를 기재하지 않고, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 발명의 특징부가 먼저 기재되어도 무방하다.

또한, 전제부와 특징부가 서로 모순이 되지 않게 기재하여야 하고, 두 부분이 합쳐서 전체를 이룬다고 생각하여야 한다. 그 표현의 대표적인 것이 “...에 있어서”이다.

② 특징부

특징부는 발명의 핵심으로서 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항, 즉 발명의 목적 달성에 없어서는 아니 되는 구성요소를 기재하는 것으로 주로 결합에 대한 부품으로서의 요소와 이들 요소간의 상호 어떠한 관계를 가지고 있는가를 기재한다.

특히 여기서는 발명의 카테고리를 불명확히 표현한다던가, 요소들이 장황하게 표현된다던가, 요소를 불필요하게 중복 표현한다던가 하는 것은 피해야 한다.

따라서 모든 청구범위는 한 요소와 다른 요소간의 결합의 형태로 나타나기 때문에 특징부에는 결합에 대한 주요 요소(부품, 공정, 성분) 등만을 기재하고 이것들이 어떻게 상호 구성되어 있는지를 기재하여야 하는 것이다.

③ 연결부

연결부는 전술한 특징부와 종결부를 연결하는 표현을 기재하는 것으로, 그 대표적인 표현 용어는 “...으로 구성된 것을 특징으로 하는”, “...을 포함한 것을 특징으로 하는”, “...을 수행하는 것을 특징으로 하는” 등이 사용된다.

④ 종결부

종결부에는 발명이 내면적·표면적으로 상징될 수 있는 기술적 사항에 대하여 기재한다. 주로 명칭을 사용하는 것이 일반 관례이고 일치되어야 할 필요성은 없다. 특히 여기에서 “...용”이라는 대표적인 용어가 사용되나 이러한 용어를 사용할 경우에는 권리의 범위가 한정될 수도 있는 경우가 있고, 특히 국제특허분류에 의한 해당 출원의 분류가 잘못될 가능성이 농후하기 때문에 실체 심사에 막대한 지장을 준다. 첨언하면 국제특허분류(IPC)는 전 산업을 크게 기능위주와 응용위주로 나누고, 발명의 기능이 응용될 수 있는 산업분야는 항상 이중적으로 나타나 있다.

따라서, 자칫 잘못하면 올바른 발명의 해당분류를 찾지 못하여 후원에 대한 선행기술의 역할을 다하지 못할 우려가 있다.

우리 나라의 “~에 있어서” 형식의 청구항을 미국식 Claim과 비교해서 분류하면, 대강 다음의 5 종류가 있다. 국문영역의 관점에서 기술한다.

<Jepson 형>

이 잭슨 형의 경우는, “~에 있어서” 보다도 앞 부분이 공지이고, 그것보다도 뒷부분은 신규이다. 따라서 “~에 있어서”의 자리에 “characterized by”나 “the improvement comprising” 등의 잭슨 형식을 사용할 수 있다.

<미국에서 일반적인 comprising 형>

이 형의 경우는 “~에 있어서”의 앞에 전제부가 나오고, 이후에 Claim 본문(body)이 온다. “~에 있어서” 후에는 공지사항과 신규사항 양쪽을 기재한다. 따라서 국문 청구항의 “~에 있어서”의 자리에 “comprising” 등을 사용할 수 있다. 주의해야할 것은 잭슨 형의 claim으로 해서는 안되는 것이다.

<whereby 형>

이 whereby 형의 경우에는, 영문 claim에서는 발명의 구성을 기술한 후에 작용을 기재했지만, 국문 청구항에서도 “~에 있어서” 보다도 전에 발명의 구성을 쓰고, 그 후에 작용을 쓴다. 따라서 국문 청구항의 “~에 있어서”의 자리에는 whereby를 사용할 수 있다.

<Subcombination 형>

“~에 있어서”의 전에 콤비네이션을 기재하고, 그 후에 Subcombination을 기재하는 경우도 있다. 예를 들면, “In an automotive vehicle……, an engine comprising……”과 같은 영문 claim은 국문에서는 “……을 갖춘 자동차에 있어서 ……을 특징으로 하는 엔진”과 같은 “~에 있어서” 청구항이 된다.

<Catalog 형>

“~에 있어서”의 앞에 복수의 부재를 카탈로그형으로 열거하고, 예를 들면 “A부재와 B부재와, …을 갖춘 …에 있어서”라고 기재하고, 그 “~에 있어서” 이후에 이들 A부재나 B부재의 상호관계나 작용을 설명한 국문청구항도 드물지만 있다.

이와 같은 청구항은 “~을 갖춘 …에 있어서”의 부분을 소거하고, 거의 그대로 영역하면, 미국에서도(일반적인 스타일이 아닐지도 모르지만) 통용될 수 있을 것이다.

(2) 잭슨(Jepson) 형태의 청구항

잭슨형태의 청구항을 사용하는 발명은 오로지 종래 기술을 바탕으로 그 부분적인 개량에 특징이 있는 것이 대부분이다. 이러한 관점에서, 공지된(혹은 주지된) 구성부분을 청구항의 전문에 기재하고, 그 공지된 기술에 대하여 그 발명이 특징으로 하는 개량점을 명확하게 지적하는 형식으로 청구항을 기재할 수 있다. 이를 미국에서는 Jepson type Claim이라 부르고, 이러한 Claim에 의해 기재된 경우 전문도 청구된 발명에 포함된 것으로 해석하며, 일본이나 독일, 기타 유럽제국에서 채용되고 있는 방식이다.

* 형태
전문부(전제부) 특징부
<-----+----->
* 연결용어: …에 있어서, xx를 특징으로 하는 ○○
* 대상 : 개량발명
* 전문은 통상 공지기술을 기재
* 전문도 청구한 발명에 포함

전형적인 예를 들면, A와 B가 공지이고 C가 신규사항으로 부가된 것일 때, “A+B로 구성된 …장치에 있어서, C를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 …장치”, 또는 A와 B와 C가 공지이고

C'이 개량사항일 때, "A+B+C로 구성된 ...장치에 있어서, 상기 C는 C'으로 구성된 것을 특징으로 하는 ...장치"이다.

또 하나의 예를 들면, "컴퓨터의 각종 작업시 입출력작업 또는 데이터의 보존을 위한 상기 메모리 매체인 컴퓨터 보조기억장치에 있어서, 상기 보조기억장치는 원반형의 메모리 매체인 자성체와 자성체 케이스 및 여닫이 개폐구로 구성되어 있고, 상기 메모리 매체인 원반형의 자성체는 회전이 가능하도록 중앙에 일정지름을 갖는 돌출부가 일체로 형성되어 있고, 상판과 하판으로 분리.결합될 수 있고, 상하판 중 어느 한 판에는 상기 원반형 자성체의 돌출부가 끼워질 수 있도록 원형의 홈이 형성되어 있으며, 상하판 양면의 양단부 중앙은 일정 크기의 장홈이 형성되어 상기 자성체를 사이에 두고 결합되는 상기의 자성체 케이스와, 상기의 자성체 케이스의 일단에 형성된 장홈을 덮고 좌우로 미끄러지면서 장홈을 여닫을 수 있도록 단지 결합된 여닫이 개폐구로 형성된 컴퓨터용 플로피 디스켓"을 보자.

상기 [Jepson-type]의 특허청구범위의 실례의 정체를 파악해보면, i) 종래 또는 이미 알려진 당해 발명의 산업상 이용분야 및 당해 발명의 기술분야를 특정하는 전문과, 즉 상기의 예문에서 "컴퓨터의 각종 작업시 입출력기억 또는 데이터의 보존을 위한 상기 메모리 매체인 컴퓨터 보조기억장치에 있어서", ii) 출원인이 발명한 것으로 여기에서 청구된 결합부분을 구성하는 구성요소나 공정의 나열과, 즉 "상기 보조기억장치는 원반형의 메모리 매체인 자성체, 자성체 케이스 및 여닫이 개폐구로 구성되어 있고", iii) 상기의 구성요소나 각 공정의 상호결합으로 형성되는 것이 특징임을 알 수 있다. 즉 상기의 예문에서 각 구성요소의 결합을 의미한다.

여기서 잭슨 청구항의 장.단점을 살펴보자.

잭슨 청구항이라는 것은, 발명의 구성을 공지 부분과 신규 부분으로 분리하여 기재한 청구항을 말하는데, 잭슨 청구항의 장점은 출원인이 발명의 구성 가운데 어느 부분을 공지한다고 생각하고, 어느 부분을 신규하다고 생각하고 있는지가 이해하기 쉬운 점이다. 이것에 의해 설득력이 증가한다. 특히 특허성이 부족한 개량발명일 때, 개량부분을 강조하는데 잭슨 형식을 적용하고 있다. 그러나 발명의 구성을 공지 부분과 신규 부분으로 나누는 것이 곤란한 것도 있다. 그곳에 잭슨 형식의 결점이 있다.

예를 들면, 복수의 부재 각각이 모두 공지되어 있고, 이들 부재의 조합이 신규일 때에는 잭슨 형식의 적절한 청구항은 기재하기 어렵다. 또한 두 개의 공지 기술을 조합했을 때에도, 잭슨 청구항은 작성하기 어렵다.

게다가 잘못된 청구항의 공지 부분에 발명의 신규 사항을 기재해 버렸을 때 문제가 된다. 잭슨 형식으로 해서 미국의 여러 가지 Claim의 제원칙을 만족시키려고 하는 것은, 다른 방식과 비교해서 극히 곤란하다. 잭슨 형식의 Claim이라도 일반 미국 Claim과 같이 복수의 부재를 열거해야 하며, 더욱이 신규 부분과 공지 부분을 명확히 분리해야 하기 때문이다.

잭슨 형식의 Claim 표현의 방법은 현재는 여러 가지가 있다. 잭슨이 고안해낸 형식은 하나였지만, 요컨대 신규 부분과 공지 부분을 나누면 되는 것이다.

이러한 잭슨 청구항은 다음과 같은 경우에 쓰인다. 즉, ㉠ 선행기술의 요소를 개량했을 때, ㉡ 선행기술에 새로운 요소를 부가했을 때. 그리고 잭슨 청구항의 초점은 그 기술 전체에 있는 것이 아니고 개량된 부분에 있다. 그래서 특허의 심사관들은 잭슨 청구항들을(일반 청구항들보다 심사하기 쉬우므로) 선호하고, 반면 출원인들은 이를 기피하는 경향이 있다. 잭슨 청구항은 그러므로 꼭 필요할 때만 사용되어야 한다. 대부분의 경우 잭슨 청구항을 작성할 수 있는 사항은 일반청구항도 작성할 수 있다.

특허의 침해나 특허권의 효력이 문제되었을 때 잭슨 청구항을 어떻게 해석할 것인가에 대해서는 미국 법원의 입장이 분명하지는 않다. 이런 경우 특허권이 도입부에서 언급된 요소에도 미치

는가에 대해서 법리가 확립되어 있지 않다.(이에 대해서는 본 글의 '6-2-2) Jepson 청구항'을 참조하라) Jepson 청구항 작성할 때에는 도입부에서 언급하는 선행기술의 요소들을 될수록 광범위하게 언급하도록 노력하여야 한다. 도입부에서 언급하는 이런 요소들이 이미 공지的事实임을 확실히 인정해야 한다. (이러한 잭슨 청구항은 유럽에서 많이 사용된다.)

(3) 프로덕트 바이 프로세스(Product-by-Process) 형태의 청구항 (MPEP 706.03(e) 참조)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * 제법에 의한 생산물로 표현 * 생산물이 구조나 물리화학적 성질로 표현되지 못할 경우에 사용 |
|---|

Product는 Article of manufacture가 신규하여 특허될 수 있고, 그것이 제조되는 Process에 의한 것 이외에는 규정할 수 없을 때에 사용되는 방법이다. 즉, 방법적인 표현에 의해 물건의 발명을 한정된 청구항을 일컫는다. 물건의 발명이 물건의 구조에 있어서 기재 불가능한 경우에는 출원인은 물건의 발명은 방법적으로 청구할 수밖에 없다.

특히, 화학관계의 발명에 있어서 물건(Product)이 신규하여, 발명에 포함되는 것이면서 그 제조방법을 특정하지 않으면 그 물건을 한정할 수가 없는 경우가 있다. 이러한 때에 사용되는 Claim의 형식을 Product-by-Process라 부른다.

이러한 청구항에 의해 기재된 경우 그 발명된 물품(Article)은 방법에 의하여 한정되기 때문에 순전한 Product Claim 보다는 범위가 협소하게 된다.

(4) 마르쿠쉬(Markush) 형태의 청구항 (MPEP 706.03(y), MPEP 803.02 참조)

청구항에 있어서 “택일적인 표현”은 허용되지 않고 있지만 화학분야의 발명의 청구항에 한하여 특별히 허가되는 경우가 있다. 주로 발명이 2이상 병렬적 개념에 상당하고 이들을 총괄하는 발명의 개념이 없을 경우에 사용된다.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> * 형태 <ul style="list-style-type: none"> - A, B, C 및 D로 구성된 군에서 선택한 하나의 ... * 화학분야에서 일반식에 대한 치환체 정의시 사용 |
|---|

예를 들면, 어떤 물질을 일반용어로 정확하게 표현하고, 이것을 한정하는 것이 가능하지 않는 경우에 한하여 “A, B, C 또는 D” 혹은 “A, B, C 및 D로부터 구성된 군에서 선택한 ...”이라는 형태로 표현하는 것이 허용된다. 이를 Markush type claim이라 부른다. 즉 내용은 실질적으로 균등하다는 조건에서 발명의 내용에 따라 [and] 뿐만 아니라 [or]를 사용할 수 있다.

마르쿠쉬 표현을 이용할 때에는 그룹에 속하는 요소(전술한 a, b, c 등)는 서로 균등한 것이어야 한다. 균등하지 않다고 생각되어지는 요소에 대해서는 다른 형태의 청구항을 기안하는 편이 무난하다.

이러한 청구항에 의해 기재된 A, B, C 각각을 단독으로 사용하는 경우에도 당연히 보호대상이 되는 것이다.

3) 특허청구범위 관련 법규정

현행 특허법에서는 명세서에 기재되는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허청구범위가 기재되어야 함을 규정하고 있다(특허법 제42조 2항)

제42조【특허출원】②제1항의 규정에 의한 특허출원서에는 다음 각 호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다.

1. 발명의 명칭
2. 도면의 간단한 설명
3. 발명의 상세한 설명
4. 특허청구범위

그리고 특별히 특허청구범위를 기재하는 방법에 관하여 규정하고(특허법 제42조 4항), 특허청구범위 기재에 대한 구체적인 방법은 특허법시행령 제5조에 위임하고 있다.

제42조【특허출원】④제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항 (이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다.

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것

(1) 발명의 상세한 설명에 의한 지지 (§42④-1)

특허법 제42조 제4항의 특징은 우선 특허청구범위의 다항제 운영을 규정한 것이고, 청구범위에는 보호받을 객체가 기재되어야 한다는 것(보호범위적 기능)과 특허청구범위에는 실시 가능한 발명의 구성의 결합만으로 기재되어야 한다는 것(구성요건적 기능)이다. 청구항이 1 또는 2 이상 있어야 한다는 것은 출원인(발명자)의 발명내용을 실질적으로 두텁게 보호해준다는 의미에서의 다항제를 표현하고 있다.

보호받을 수 있는 객체를 기재하여야 한다 함은 출원인 스스로가 발명의 내용 내에서 권리로 하고자 하는 영역을 확정하여 기재함으로써 그 권리의 실체가 명확한 보호범위를 가져야 한다는 것을 의미한다. 그리고 발명의 구성만을 기재한다는 것은 특허청구범위의 구성요건적 기능을 의미하는 데 특허법 제42조 제4항의 각 호가 이에 대한 기준으로서의 역할을 하고 있다.

특허청구범위의 구성요건적 기능에 알맞은 기재에 관하여 설명하기로 하자. 특허법 제42조 제1에 “발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것”이라고 규정하고 있다. 특허청구범위는 발명의 기술내용을 표현하는 것이다. 즉 당해 출원발명의 실체는 특허청구범위에 기재된 내용으로 파악된다(특허법 제97조).

출원인들은 이런 내용의 거절이유를 통지 받을 때가 있다. 즉 “청구범위의 기재내용이 발명의 상세한 설명에서 충분히 지지 받지 못하는 것이다”. 이와 같이 청구범위가 발명의 상세한 설명에서 지지 받지 못한다는 거절이유의 근거는 바로 상기의 제42조 제4항 제1호에 있다. 특허청구범위는 발명의 기술내용 중 출원인이 보호받고자 하는 범위를 확정하여 기재하는 것이고, 발명의 상세한 설명은 발명은 목적·구성 및 효과를 당해 기술분야의 통상의 지식인이 용이하게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하는 것이다. 그러므로 특허청구범위에 기재되는 기술내용은 명세서의 발명의 상세한 설명에서 충분히 설명된 것 중에서 기재되어야 한다.

특허청구범위에 기재한 발명의 기술내용의 범위가 상세한 설명 상에 기재한 발명의 기술내용보다 넓게 되어 있는 것에 대하여 특허권을 설정해준다면, 발명의 범위를 벗어난 것까지 독점권으로 설정해준다는 것이므로 특허제도의 취지에 어긋나는 것이다. 그러나 심사과정에서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 특허청구범위를 간과하여 등록되고, 당해 특허권에 대하여 침해사건이 발생했을 때 과연 어떻게 권리를 판단할 것인가. 물론 당해 특허권에 대한 무효문제는 전제로 하지 않은 상태에서이다. 이 때에는 당해 특허가 무효로 되지 않는 한 당연무효로 취

급할 수 없으므로 현재의 특허권을 인정하되 그 권리범위의 해석에 있어서는 발명의 상세한 설명 상에 기재된 발명의 기술범위에 국한하여 해석하여야 할 것이다. 역으로 발명의 상세한 설명에 넓은 범위의 기술내용을 기재했다 해도 출원인의 발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 기술 내용으로 국한된다. 물론 이 때의 특허청구범위의 판단은 발명의 상세한 설명의 기재사항을 참고로 하여 판단해야 할 것이다.

(2) 명확하고 간결하게 기재할 것 (§42④-2)

특허청구범위는 발명의 목적이나 효과를 나타내는 내용을 기재하거나, 구성요소의 기능을 장황하게 설명하거나 또는 불필요한 용어를 과다하게 기재하는 것을 배척한다. 명확한 기재란 어떠한 것을 의미하는가. 우선 종래 기술과 구별이 되어야 하고, 각각의 구성요소들의 구별이 뚜렷하여야 한다.

참고로, 특허청 심사편람의 “특허청구범위의 명확하고 간결한 기재요령”은 다음과 같다.

① 특허청구범위의 기재내용을 이해하기 위하여 필요한 경우에는 도면에 사용된 부호를 괄호로 하여 용어 뒤에 사용할 수 있으며, 이 부호를 사용하지 않음으로써 구성이 불명료하게 되어서는 안 된다.

② 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어를 기재해서는 안 된다. 다만, 이러한 용어를 사용하지 않고서는 적절한 표현이 없고, 그 의미가 명세서의 상세한 설명에 의해 명확히 뒷받침되고(기술내용범위의 광범에 관한 사항도 포함된다) 발명의 단일성에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다. 예를 들면 “소망에 따라”, “필요에 따라”, “및/또는”, “임의로”, “일반적으로”, “...등”, “같은 ...”, “대부분의”, “약” 등의 용어를 상용하는 경우 특허청구범위에 기재된 발명의 권리범위가 불명료해질 우려가 있으므로 원칙적으로 인정되지 않는 것으로 하고, 이러한 표현을 하지 아니하고는 달리 표현할 방법이 없거나 발명의 내용이 간결하게 표현되는 경우에만 사용하기로 한다.

③ 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명의 기재와 모순되지 않아야 하고, 용어는 명세서에 사용된 용어와 일치되게 기재하여야 한다. (그러나 이는 내용상의 모순이 없으면 충분하고, 따라서 본문의 내용을 권리화하기 위한 청구항 작성시 넓은 클라임의 작성을 위해 청구항의 명칭변경을 하는 것은 허용된다)

④ 특허청구범위의 기재는 필요 이상으로 장황하여 발명의 구성을 불명료하게 하면 안 되고, 각 구성요소의 상호관계를 명확히 표현하여야 한다. 예를 들면 각 구성요소를 단지 나열함으로써 그들간의 관계를 불명료하게 하면 안 된다.

⑤ 특허청구범위에서 수치로 발명의 구성을 한정할 때에는, 예를 들면 “120에서부터 200까지”와 같이 수치의 범위를 정해주는 것은 무방하나, “120, 200 또는 300”과 같이 수치의 한정이 불명확한 표현의 기재는 하여서는 안 된다.

⑥ 특허청구범위의 청구항 중 구성요소는 특정기능을 수행하기 위한 “수단” 또는 “공정”으로 기재할 수 있다. 이 경우 그에 대한 용어의 개념을 발명의 상세한 설명에 기재하여야 한다.

다음의 경우에는 간결성의 결여로 본다.

① 카테고리의 불명료 - 각 청구항의 기재로부터 파악되는 발명이 물건의 발명.방법의 발명.물건을 생산하는 방법의 발명의 어느 범주에 속하는지 불명료할 때

② 물건의 발명 - 물건의 발명에 있어서 기술적 수단이 방법적으로 표현되어 있을 때

③ 방법의 발명 - 방법의 발명에 있어서 그 발명의 기술적 수단이 물건으로 표현되어 있을

때

④ 기능적(작용적) 표현 - 청구범위에 기재된 사항이 단일의 기술적 수단으로부터 되는 경우에 있어서 그 기술적 수단이 기능적(작용적)으로만 전부 표현되어 있을 때, 단 구성적 한정을 표현하는 데는 기능적 한정 사항의 일부가 삽입될 수도 있다.

⑤ 부정적인 표현 - 청구범위의 기재에 있어서 부정적인 표현을 사용해서 기술적 수단을 기재하고 있기 때문에 그 기술적 수단이 불명료할 때

⑥ 총괄적 표현, 상위개념에 의한 표현 - 청구범위의 상위개념에 내포되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재된 목적 및 효과로부터 판단해서 서로 등가가 아닌 것으로 인정되는 상위개념을 사용하고 있을 때, 총괄적 표현도 또한 같다. (예, 명세서 내에 진공관의 회로설명, 청구범위 내에 트랜지스터의 회로 기재를 한 경우)

⑦ 종래 기술의 표현(청구범위 기재의 전반부) - 특허청구범위의 기재에 있어서 종래 기술의 일부로 표현되는 청구범위 전반부의 기재내용이 발명의 상세한 설명과 종래 기술이 상이할 때

⑧ 청구범위 기재의 후반부 표현 - 청구범위 기재의 후반부 즉, 특징적인 부분의 기술사항이 발명의 상세한 설명과 상이할 때 (통상은 명칭과 동일하게 기재)

⑨ 정도 및 범위를 나타내는 어구 - 특허청구범위에 “어느 정도 비중이 큰”, “상당히 큰”, “저온”, “고온” 등의 정도를 기재한 경우 그 비교의 기준, 정도가 불명료할 때; “...이상”, “...이하” 등의 상한 또는 하한의 수치의 한정을 붙이고 있어 그것 때문에 기술적 수단이 불명료한 경우

⑩ 불명료한 어구의 기재 - “...하도록 한 A”, “...하기 위한 B”의 기재가 있어 기술적 수단이 불명료한 경우; “양호하게”, “...과 같은”, “특히”, “예를 들면”, “등등”, “바람직하게”, “적당히...”, “...을 제외한”, “또는” 등의 자구와 함께 임의부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재되어 있어 그것 때문에 발명의 구성에 없어서는 안될 사항이 불명료한 경우(이러한 용어는 필요에 따라 명세서의 본문에서 사용하는 것이 가능하다)

⑪ 청구범위에 발명의 기술적 사항을 기재할 때에 “명세서 및 도면”이 언급되어서는 안 된다. 특히 “상세 설명의부에 기재된 바와 같은”, “도면 중 그림 2에 도시된 바와 같은” 표현은 불가하다. 그러나 그런 표현이 절대적으로 필요한 경우에는 그 필요사실을 입증하여야 한다.

⑫ 청구범위에 “상표”, “판매지역”, “판매선” 등 발명의 구성에 무관한 표현이 기재된 경우

⑬ 독립항에는 일반적인 용어에 의하여 의미되는 사항을 제외하고는 발명을 정의하는데 필요한 모든 필수적 사항만이 분명히 기재되어야 한다. (예, “자전거”에 관한 청구범위인 경우, 바퀴의 존재에 관하여 반드시 기재할 필요는 없다.)

(3) 구성에 없어서는 아니되는 사항만의 기재 (§42④-3)

특허청구범위에 기재되어야 할 사항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항 만이다. 이 규정은 특허청구범위의 두 기능 중 구성요건적 기능을 대변하는 규정인데, 그 문헌적 의미를 파악하기가 용이하지 않다. 그 이유는, 첫째 특허청구범위에 기재하여야 할 발명의 구성은 어느 정도의 범위인가, 둘째 구성에 없어도 되는 사항을 기재한 경우에는 거절의 대상이 되는가 등이다.

본 규정의 의미는 전술한대로 구성요건적 기능에 관한 확인규정이므로 특허청구범위에 기재하는 것은 발명을 이루는 데 꼭 필요한 모든 구성요건들이다. 그리고 이 구성요건은 전부 기재되어야 한다. 왜냐하면 특허청구범위는 각 구성요건의 상호결합으로 발명의 목적을 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 하기 때문이다. 예컨대 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 완성에 필요로 하는 구성요소가 5개인데, 특허청구의 범위에 발명의 구성요소 4개만을 기재했을 때, 특히 당해 발명의 특성이 전기.전자회로 및 기계계통과 같이 각 구성요소간의 상호작용이 중요한 특징을

이루는 것일 경우에는 특허청구범위에 기재된 발명의 기술내용만으로는 권리의 범위를 확정할 수 없으므로 거절이유가 된다. 그리고 “...사항만”으로 기재하여 구성에 필요한 구성요건 외의 사항을 기재하면 규정에 위반되는 것처럼 규정하고 있다. 즉 발명의 특허청구범위에는 발명의 구성만을 기재하여야 하고 발명의 목적, 효과 등이 기재되어서는 안 된다.

특히 “...만”으로 규정한 것에 대하여 국내의 특허계에서는 특별한 설이 없고 일본에서는 다음과 같은 이유로 “만”으로 규정하고 있다고 한다.(유미특허 역, [특허법개설])

- i) 특허청구범위에 발명의 구성 외에 발명의 목적 및 작용효과 등을 기재하는 것을 방지하고,
- ii) 특허 후에 특허청구범위에 기재한 사항의 일부를 구성요건이 아니라는 취지를 주장하는 것을 방지하기 위함이다.

위와 같은 해석에도 불구하고 “만”으로 규정된 뜻은 불명확하다. 과연 현행 특허출원 등에서 살펴볼 때, 과연 상기와 같은 해석만으로 법규정의 타당성을 주장할 수 있을 까하는 의문이 생긴다. 기술의 다양화, 복잡화가 심화되어가면서 특허출원된 발명의 요지를 구성요건만을 가지고 표현한다는 것은 어쩌면 무리일지도 모른다. 그래서 현재의 추세는 각 구성요건의 기능을 설명하여 기재되는 특허청구범위의 형태를 적극적으로 인정해주고 있다. 그러나 여기에서의 “만”의 의미는 특허청구범위에 불필요한 사항을 설명하지 말고 발명을 표현하는 구성만을 기재해야 한다는 의미에는 이론이 없다.(이종일, [특허법])

이 항목은 구법시행령에 규정된 사항을 본법으로 이전시킨 것이다. 현행법이 이를 본법에서 규정하고 있는 이유는 특허청구범위의 기재방법은 특허출원인의 권리 사항일 뿐 아니라 제3자의 특허를 침해해서는 안 된다는 의무를 부담하고 있는 일반국민의 의무에 관한 사항이기 때문에 당연히 법률로서 규율되어야 한다는 이유에서였다.

이러한 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것이라 함은 발명의 목적에 따라 그 목적을 달성하기 위한 기술적 수단을 의미하는 것으로, 그 목적, 구성 및 효과로 보아 필수불가결한 구성의 모든 것을 말한다. 따라서 이들 중 일부구성이 누락된 경우 미완성발명이나 진보성이 결여된 발명으로 거절될 수 있다.

다음은 미국 특허출원을 위한 청구항 작성에 있어서의 기본 원칙들이다. 어느 원칙도 절대적인 것은 아니다. 그러나 이 원칙들은 청구항 작성에 있어서 좋은 지침이 될 것이다.

1. Jepson 타입의 청구항보다는 될수록 결합체의 발명에 관한 청구항을 작성한다. 그러나 Jepson 타입의 청구항을 작성하게 되면 도입부에서 선행기술에 관해 될수록 넓게 언급한다. 도입부에서 언급된 발명이 이미 존재하고 있었음을 분명히 인정한다.

2. 도입부는 간결하게 작성한다.

3. 택일적 표현을 삼간다.

4. 청구항에서 도면에 붙여진 번호를 인용하지 않는다.(우리 나라는 이에 대한 언급이 없지만 이를 준용한다고 볼 수 있다)

5. comprises 또는 comprising이란 말을 연결사로서 사용한다.

6. 발명의 중요부분을 모두 주장하기 위해서 충분한 수의 청구항을 작성한다.

7. 어떤 요소들을 발명에 포함시킬 것인가를 정할 때 그 발명을 위한 시장의 현실을 참작한다.

8. 결합체(composition)가 발명일 때에는 이를 구성하는 각 요소를 명세서와 도면이 분명히 구분해서 나타내야 한다.

9. 불필요한 중복은 피하되 범위가 다른 여러 개의 청구항을 기재한다. 청구항의 수가 충분한가, 청구항이 너무 많지는 않은가 등을 생각한다.

10. 청구항을 분명하고 알기 쉽게 기재한다.

11. 청구항을 문단형식으로 기재한다. 필요하면 종속문단도 이용한다.
12. 아직 언급하지 않은 요소를 인용할 필요가 생기지 않도록 발명의 요소를 적절한 순서로 언급해 나가야 한다.
13. 요소마다 명칭을 붙여서 나중에 인용하기에 편리하도록 한다.
14. 발명의 요소들이 구조적으로 또는 기능적으로 어떻게 연관되는지 설명한다. 어떤 요소도 이러한 설명없이 방치하지 않는다.
15. 전기 또는 기계에 관한 청구항에서는 Markush나 그룹을 필수로 사용하지 않는다. 어느 그룹에 속한 요소들 전체를 지칭하는 일반적 용어를 사용한다(Markush 그룹은 화학에 관한 청구항에 적합하다).
16. 불필요한 말, 중복되는 말을 피한다.
17. 청구항의 내용을 도표로 만들어 정확한 지를 검토해본다.
18. 같은 청구항에서 같은 요소를 두 번 설명하지 않는다.
19. 부정적 의미의 말을 피한다.
20. 청구항을 중복해서 기재하지 않는다. 즉, 범위가 유사해서 실질적으로 동일한 청구항으로 볼 수 있는 청구항들을 나열하지 않는다.

4) 특허청구범위 기재방법 위반의 효과

(1) 특허법 제42조 4항에 위반된 경우

특허청구범위가 1항 이상 기재되어 있지 아니한 경우 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하거나, 그 특허청구범위의 기재가 명확하고 간결하게 기재되지 아니한 경우 등에는 거절이유나 무효사유가 됨은 물론 이의 신청이유(§70)로도 된다.

- ① 무효심판청구에 의한 무효(§133.1)
- ② 소극적 권리범위확인심판청구(§135.1)에 의한 권리 범위에 속하지 않는다는 심판을 받을 염려
- ③ 출원 중에 있으면 거절이유가 된다.(§62)
- ④ 침해죄로 고소한 경우에 무혐의시에는 무고죄가 성립될 수 있다.

(2) 특허법 제42조 5항에 위반된 경우

특허청구범위 기재방법이 특허법 제42조 5항에서 정한 기재방식에 위반된 경우 거절이유가 된다. 그러나 특허이의신청이유나 무효사유로는 되지 않는다.

4. 다항제에 따른 기재방법

특허청구범위는 그 기재형식에 따라 단항제와 다항제로 구분되는데, 다항제라 함은 특허청구범위를 기재함에 있어 그 특허청구범위를 2 이상의 항으로 기재할 수 있도록 하는 것을 말한다.

우리 나라는 그간 단항제의 기재형식을 취하여 오다가 1980년 5월 4일 파리조약에 가입하면서 1981년 9월 1일부터 다항제를 도입하여 운영하여 오고 있으며, 현행 특허법 제42조 4항에서 “특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하며”라고 규정하고 특허청구범위의 기재형식의 다항제를 천명하고 있다.

1) 다항제의 장·단점

(1) 장점

① 발명보호의 적정화

다항제는 발명마다 각각 개별의 항으로 기재함으로써 출원인의 보호받고자 하는 발명의 내용이 명확할 뿐만 아니라 독립항 또는 다른 종속항을 기술적으로 ‘한정’하거나 ‘부가’하여 ‘구체화’하는 종속항을 기재할 수 있도록 함으로써 발명의 이해에 도움이 되며, 또한 출원 발명의 일부에 거절이유 또는 특허발명의 일부에 무효사유가 있는 경우 그 거절이유 또는 무효사유가 있는 항만을 삭제하거나 감축함으로써 특허출원이 거절되는 것을 방지할 수 있어 출원인·특허권자에게 권리의 취득, 유지 및 행사 등에 있어 유리하다.

② 권리범위의 명확화

다항제는 단항제에 비하여 특허발명의 기술적 범위가 보다 명확하게 되기 때문에 특허권의 권리범위가 명확하며, 또한 제3자는 자기가 실시하거나 실시하고자 하는 기술이 타인의 특허권을 침해하는지의 여부를 판단하기가 보다 용이하다.

③ 국제간의 출원이 용이

특허청구범위 기재방법의 다항제는 선진외국에 출원할 경우 기재방법이 유사하여 출원절차를 밟는데 있어 편리하다.

(2) 단점

특허청구범위를 다항제로 기재할 경우 특허청구범위의 항수가 과다하게 되어 발명의 중복기재를 초래하거나 번잡성이 뒤따르며, 특허청구범위의 기재방법이 어려워 출원인에게 불편하다. 또한 심사에 있어서는 특허청구범위에 기재되는 기술의 분야가 비교적 넓어지므로 심사에 어려움이 뒤따르고 많은 시간이 소요된다.

2) 법규정에 의한 기재

(1) 일반적인 사항 (§42④)

특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)이 1 또는 2 이상 있어야 하

며, 청구항은 ① 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하며, ② 발명이 명확하고 간결하게 기재되어야 하고, ③ 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어야 한다.

① 독립항

1특허출원의 대상이 되는 발명의 카테고리를 대상으로 타청구항을 인용하지 않고 기재한 청구항을 독립항이라 하고, 독립항을 인용하여 독립항의 기술적 내용을 더욱 구체화하기 위해서 한정시키거나 발명의 동일성 범주 내에서 내적·외적인 구성을 부가하는 것을 독립항에 대한 종속항이라 한다.

우리 나라 특허법은 특허청구범위에 관하여 다항제를 채택하고 있다는 점에 관하여는 전술한 바 있다. 그러므로 해당 법조문에서도 “특허청구범위와 청구항”으로 구별하여 규정하고 있다. 즉 특허청구범위는 1 또는 2 이상의 청구항의 집합란이다. 특허청구범위에는 독립항 또는 독립항과 종속항이 존재한다. 일반적으로 독립항은 출원인이 독점적인 권리로 하고자 하는 발명내용의 범위를 욕심껏(?) 기재한다고 볼 수 있다. 즉 가능한 한 자신의 발명에 대해서 권리로서 보호받고자 하는 범위를 넓게 기재하려 한다. 그러므로 독립항의 기재방법에서는 어떻게 하면 넓은 클레임을 확보할 수 있을 까 하는 것이 최대 해결문제이다. 그 점에서 관해서는 전술한 바 있는 원칙을 고수하면 될 것이다. 즉 첫째, 발명의 구성요건의 개수를 극소화한다. 둘째, 각 구성요건의 범위를 극대화한다.

발명내용의 전부를 특허권으로 보호받기 위해서는(물론 선행기술의 기술적 경계를 극복한 것에 대하여), 발명을 이루는 많은 구성요소를 한 묶음으로 묶어서 그 기능이 정의될 수 있다면, 그러한 넓은 영역의 묶음(블록)으로 하여 전체 발명의 구성요소를 최소화하고, 그 묶음(구성요소)의 범위가 최대한 넓은 개념으로 설명되어야 한다는 의미이다. 그 넓은 개념 역시 발명의 상세한 설명 내에서 설명된 것이어야 함은 물론이다.

특허청구범위 중 독립항의 기재방법으로 실무자들이 사용하는 기재방법에서 하나의 예를 들면,

㉠ 발명의 기술분야가 나타나는 전문(전체구성 및 종래 기술에 관한 기술적 내용을 포함한다)을 기재한다.

㉡ 출원인이 결정한 발명의 구성요소를 열거식으로 기재한다.

㉢ 상기의 열거된 구성요소를 작용가능하도록(전기·전자분야는 신호의 입력에서 출력의 순으로, 기계장치의 분야는 작동순서대로 상호결합되도록) 기재하여야 한다.

㉣ 가능하면 상호결합된 각 구성요소들의 각각의 기능과 이들 전체의 기능설명을 첨가하여 각 구성요소의 결합관계가 더욱 더 명확해지도록 해준다.

위에서 ㉡항을 생략하고, ㉢항에서 그 구성요소를 명확히 구분 지어서 기재해주는 방법도 하나의 기재방법이 될 수 있다.

② 종속항

㉠ 의의

독립항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항이며, 이에 대하여 종속항은 “독립항을 기술적으로 한정하고 부가하여 구체화하는 사항”을 말한다.

이를 다시 설명하면 종속항은 독립항의 상세한 부분을 권리로 하기 위해 기재하는 것이다. 예를 들면 볼펜에 있어서 볼펜의 구성은 본체 케이스(손잡이 부분과 뚜껑) 그리고 볼펜심을 독립항으로 하였을 경우 결이(주머니에 거는 부분)와 볼펜심의 일단을 밀봉하지 않은 것, 뚜껑의 결합 부분에 링(링은 뚜껑을 볼펜 본체 케이스와 결합할 때 망가지거나 금이 가는 것을 방지하기 위해 뚜껑 결합부분에 끼운 것을 말함)을 끼운 것을 종속항으로 기재할 수 있다. 물론 이러한 것도 독립항으로도 할 수 있으며 출원인의 자유이다.

다항제는 하나의 발명에 대하여 여러 항의 특허청구범위의 기재를 허용하는 제도이다. 즉 다항제는 독립항을 2개 이상 또는 종속항을 2개 이상 기재하는 것이며, 실용신안의 독립항은 하나로 기재하는 것이 통례이다. 발명은 물건·제조방법·제조장치에 대해서는 각각 독립항으로 기재할 수 있다. 통상 다항제는 독립항·종속항을 2개 이상 기재할 수 있는 제도라고 보면 된다.

㉠ 종속항(다항제)의 기능

다항제 채용(종속항의 기재 허용)으로 인하여 특허권자에게 권리의 취득·유지 또는 권리 행사 하는데 유리한 입장에 서게 되어 있다.

또한 제3자는 물건을 제조·판매하기 전에 특허권침해 여부를 판단하기에 편리하다. 즉, 제3자는 특허된 특허청구범위가 명확하게 기재되어 있으면 침해 여부를 용이하게 판단할 수 있기 때문에 종속항의 기능은 독립항에 못지 않게 중요한 것이라 하겠다.

㉡ 특허권자 측에서 본 기능

출원인은 특허청구범위를 넓게, 즉 종속항을 많이 기재하여야만 특허 후에 유리하고 권리행사를 하는 데 유리하다.

단항제의 경우 특허청으로부터 특허성이 없다하여 거절이유를 받은 경우에 거절이유에 대한 의견서와 보정서를 어떻게 작성하느냐에 따라 특허를 받을 수 있고 받지 못할 수 있다. 특허청에서 당해 발명에 대한 거절이유로 채택한 사항(또는 내용)에 저촉되는 내용은 삭제할 필요가 있는데 어느 정도 저촉되는 부분을 삭제해야 저촉되지 않고 특허성이 있는가를 판단하기 어려운 경우가 있다. 또 삭제 또는 감축한 정도가 적으면 그대로 거절되거나 심사관이 재차 거절이유통지서를 발송한 다음에 삭제하거나 감축해야 한다. 또 지나치게 좁다면 특허를 받았다 하더라도 원하는 만큼의 보호를 받을 수 없는 폐단이 있다.

이에 반하여 다항제에 있어서는 발명을 구성하고 있는 것 중에서 넓은 부분을 감축시켜 나갈 수 있고, 여러 항의 종속항 중에서 저촉되는 부분이 있으면 그 항을 삭제하거나 감축하면 불리하거나, 특허 받는데 별 어려움이 없을 것이다. 또 다항제에 있어서 독립항이 삭제되는 경우는 종속항이 독립항으로도 될 수(승격) 있는 성격을 가지고 있기 때문에 단항제에 비하여 매우 유리하다.

단항제는 하나의 문장으로 기재되어 있기 때문에 특허권의 일부분만을 타인이 실시하였을 경우 이것을 특허권을 침해했다고 할 수 있겠는가에 대하여 곤란한 점이 있으나, 다항제는 여러 항으로 기재되어 있어서 어느 하나의 항만을 침해하였다 하더라도(물론 사안에 따라 구체적으로 판단해야 한다.) 침해이므로 다항제는 권리행사하는 데 매우 유리하다.

㉢ 제3자적인 면에서 본 기능

단항제나 다항제의 기재는 다같이 명확성과 간결성 있게 기재하여야 하나, 단항제는 하나의 항으로만 기재하여야 하기 때문에 잘못하면 추상적이 되기 쉬우므로 다항제에 비하여 명확성과 간결성을 기대할 수 없다. 다항제는 명확성과 간결성을 더욱 기재 요소로 한다. 따라서 제3자는 청구범위가 여러 항으로 기재되어 있어서 특허권자의 권리범위를 용이하게 판단할 수 있는 기능을 가지며, 또 이에 저촉되지 않도록 사전예방기능을 가진다. 또 침해 여부를 판단하여 침해하고 판단되면 다르게 변경하여 제조·판매하면 된다. 이와 같이 다항제는 여러 가지 점에서 유리하다.

(2) 다항제 기재방법 (특허법 §42⑤, 특허법시행령 §5)

특허법 제42조 제5항에서 대통령령으로 정하도록 한 청구항의 기재요령은 특허법시행령 제5조에서 규정하고 있다.

제5조【특허청구범위의 기재방법】①법 제42조제5항의 규정에 의한 특허청구범위의 청구항 (이하 "청구항"이라 한다)의 기재에 있어서는 독립청구항 (이하 "독립항"이라 한다)을 기재하고, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항 (이하"종속항"이라 한다)으로 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.

②독립항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.

③종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는데 필요한 수로 기재하여야 한다.

④종속항은 그 종속항이 속하는 독립항과 그 독립항의 다른 종속항 중에서 1 또는 2이상의 항을 인용하여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.

⑤2이상의 항을 인용하는 종속항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.

⑥2이상의 항을 인용하는 종속항은 2이상의 항이 인용된 다른 종속항을 인용할 수 없다.

⑦독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여야서는 아니된다.

⑧각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

이러한 시행령의 규정은 특허청구범위의 청구항(독립항, 종속항)을 실질적으로 기재하는 요령을 규정한 것이다. 특허청구범위의 기재방법과 관련하여 특허청구범위에 기재될 발명의 수에 대해서는 1특허출원주의를 채택하여, 하나의 발명을 하나의 특허출원으로 하도록 하고 있다.

① 시행령 제5조 1항

특허법 시행령 제5조에서는 특허청구범위의 기재방법에 대해서 다음과 같이 규정하고 있다.

①법 제42조제5항의 규정에 의한 특허청구범위의 청구항 (이하 "청구항"이라 한다)의 기재에 있어서는 독립청구항 (이하 "독립항"이라 한다)을 기재하고, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항 (이하"종속항"이라 한다)으로 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.

“독립항”이란 독립특허청구범위로서 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 말하며, 명세서 중에서 가장 중요한 부분이다.

“종속항”이란 종속특허청구범위로서 독립항 및 다른 종속항의 호칭은 종속항이며 종의 종속항 등으로 호칭하지 않는다.

독립항의 구성부분은 구체적으로 명시한 것. 예를 들면, 각 구성부품의 수치.배열상황.형태 등등이 이에 해당한다.

② 시행령 제5조 2항

②독립항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.

예를 들면, 라면의 제조법에 있어서 “라면자체의 발명”, “라면제법 발명”, “라면제조 장치 발명”이 하나의 출원에 포함되어 있다면 이 2가지를 독립항으로 할 수 있다.

③ 시행령 제5조 3항

③종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는데 필요한 수로 기재하여야 한다.

위 적정한 수란 발명의 성질에 따라서 적정한 수를 고려하여야 한다. 그러나 발명의 적정한 수는 일률적으로 규정지을 수 없으며, 청구범위의 간결성에 관련되어야 한다. 또 방법에 관한 발명이면 청구범위의 기재는 방법에 관한 항만 청구하도록 하고 이 방법에 직접적으로 얻어지는 물에

대한 청구항을 가능하면 기재토록 한다.

권리범위는 방법에 관한 것이며, 그 물에도 적용되기 때문이다. 따라서 청구항의 기재는 중복 기재를 피해야한다. 그러나 이것은 적정한 수에 관련된 것이므로 융통성 있게 처리되어야 한다.

④ 시행령 제5조 4항 (청구항의 인용)

④종속항은 그 종속항이 속하는 독립항과 그 독립항의 다른 종속항 중에서 1 또는 2이상의 항을 인용하여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.

종속항의 인용 예로서 종속항에는 그 독립항, 종속항에는 그 독립항의 기타 종속항 중에서, 종속항에는 1 또는 2 이상의 항을 인용하고, 종속항에는 인용되는 항의 번호를 기재한다.

이 조항에 대하여 청구항을 인용할 수 있는 구체적인 형태를 구분하면 다음과 같이 나타낼 수 있다. 즉, 청구항의 인용에는 ㉠ 전부인용, ㉡ 전부를 인용하거나 대상이 달라지는 인용, ㉢ 전부를 포함하지 않는 인용, ㉣ 인용되지 않는 종속청구항, ㉤ 상이한 카테고리에 대한 인용, ㉥ 청구항 기재의 표현에 없는 내용의 인용 등으로 구분할 수 있다.

㉠ 전부인용

이 경우의 전형적인 예는 선행하는 타 청구항의 특징을 모두 포함하는 청구항을 기재하는 경우이다.(여기에 인용되는 예들은 설명을 위한 것으로 예 자체가 청구항 기재의 형식과 내용을 모두 만족시키는 것은 아니다.)

예를 들면 아래 <예1>과 같이 독립항에 의한 기재는 특정구조의 타이어 체인(A)의 구성을 양쪽의 청구항에서 중복 기재함으로써 시간이 걸리고 또 양 청구항의 차이점(양측의 로울러(B))의 구분이 명확하지 않다.

<예1> (한국 -> 가능) (일본 -> 가능)
1(독립항) 미끄럼을 방지하기 위한 횡간부(H)를 구성한 타이어 체인(A)
2(독립항) 미끄럼 방지를 위하여 횡간부(H)를 설치하고 그 횡간부의 양측에 로울러(B)를 끼운 타이어 체인(A)

대법원 판례에서는 “동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복하여 기재되어 있다고 하더라도 특허청구의 범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있어 당해 기술분야에서 통상을 지식을 가진자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식”(1995.9.26 제1부 판결 94후1558 거절사정)한다라고 하여 중복기재보다는 특허청구 범위가 명확하고 간결하게 기재될 것을 더 요구하고 있다.

<예2> (한국 -> 가능) (일본 -> 가능)
2'(종속항) 제1항에 있어서, 횡간부(H)의 양측에 로울러(B)를 끼운 타이어 체인

만약에 <예2> 처럼 제2'(종속)항으로 기재한다면 특정구조의 타이어 체인(A)의 구성의 전부를 생략 가능하고, 양 청구항의 차이가 “양측의 로울러(B)”라는 것을 명확하게 알 수 있다. 또한 제1항의 기재가 잘못되었다든지, 제1항과 제2항의 발명의 어느 것도 특허성이 없고 그 때문에 새로운 구성(예, 연결부)을 쌍방의 청구항에 추가하는 경우에는 청구항1만 보정하면 청구항 2'도 보정하는 것이 되어 보정의 시간을 절약할 수 있다. 더욱이 인용된 청구항이 특허성이 있다면 그것을 인용한 청구항도 특허성이 있는 것이 통상적인 것으로 심사관이 특허성을 판단하는 데도 훨씬 도움이 된다.

더구나, 시행령 제5조 7항에서는 “독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여야는 아니된다”고 규정하고 있고, 이는 원칙적으로 인용된 청구항의 뒤에 계속해서 기재하여야 함을 간접적으로 의미하고 있다.

왜냐하면 인용한 청구항과의 사이에 관계가 없는 청구항이 기재되면 청구범위 전체의 기재가 불명료해질 우려가 있는 경우가 있기 때문이다.

<예3>

(한국 -> 가능) (일본 -> 부적당한 예)

1. 특정구조의 볼베어링
2. 특정공정에 의한 볼베어링의 제법
3. 제1항에 있어서, 외륜의 외측에 환상완충체를 설치한 볼베어링

위의 <예3>에서, 제법의 발명인 제2항이 물건의 발명인 제1항과 제3항 사이의 중간에 개입되어 있음으로써 청구범위 전체가 명료치 않을 수 있으나, 이러한 규정은 기재상 불명료한 사항을 최대한 최소화하기 위한 것으로 굳이 위의 <예3>의 형태가 시행령 제5조 4항의 조항에 위반된다고 볼 수는 없다.

왜냐하면 심사시 보정이 있을 경우 새로운 항을 신설할 때 이러한 형태가 있고, 이를 규제할 특별한 이유는 없다고 보며, 심사관이 공고결정시에 수정도 가능하다.

그러나, 일본의 경우 특허법 시행규칙 양식 제16 [비고] 13에서 다른 청구항을 인용한 때에는 그 청구항은 원칙으로 인용하는 청구항에 계속하여 기재하도록 되어 있어, 위의 <예3>과 같은 경우에는 부적당한 것으로 설명하고 있다. 우리 나라의 법조문의 성격으로 보아서는 하나의 청구항을 2이상의 청구항에서 인용하는 경우 부득이하게 이런 상황이 발생하나, 그 인용되는 항을 연속적으로 기재하지 않는 것은 바람직하지 않다.

또한 전체적으로 불명료해서는 아니되고, 청구범위 기재형식에 있어서 부득이한 경우를 제외하고는 시행령 제5조 4항의 조항이 인용된 청구항의 뒤에 계속해서 기재하여야 함을 간접적으로 의미하는 바, 주의할 필요가 있다. 즉, 최초출원시부터 <예3>과 같이 인용에 계속성을 잃은 상태로 출원서를 작성하지 않는 것이 좋다.(아래 <예4> 참조)

<예4>

(한국 -> 가능) (일본 -> 가능)

1. 특정구조(A) + 특정구조(B) (A+B)
2. 제1항에 있어서, A는 A'인 것(A'+B)
3. 제1항에 있어서, B는 B'인 것(A+B')
- 3'. 제1 또는 제2항에 있어서, B는 B'인 것(A+B', A'+B')

위의 <예4>에서 제3'항은 그 종속항이 속하는 독립항과 그 독립항의 다른 종속항 중에서 인용된 경우로 상기 조항을 만족하지만 통상 2이상의 독립항(여기서는 종속항 관계로 기재되어 있지 않는 발명)을 하나의 종속항에 인용되는 것은 금지되고 있다.

위의 <예3>에서 제1항(물건)과 제2항(방법)을 동시에 종속항에 인용한다면 카테고리의 의문을 남긴 채 독립항들을 종속시키는 결과가 되어 그 내용이 상당히 불명료해질 우려가 있다. 따라서 상기와 같이 취급됨은 두말할 나위가 없다.

즉, 독립항 또는 종속항의 기재에 관한 선택의 자유는 출원인에게 있다. 그러나 청구범위의 간결·명료화의 관점과 청구항이라는 개념의 도입을 인지하지 못하고 종전의 일본식 관념을 깨뜨리지 못하여, 종속항으로 기재하는 것이 가능한데도 불구하고 이를 굳이 독립항으로 기재할 경우, 내용적으로 이에 대한 2이상의 독립항을 인용한다 하더라도 청구범위가 불명료해지는 것은 없다고 볼 수 있으나, 청구항은 각각 독립성을 유지하도록 되어 있고, 다만 그 형식적 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한 경우를 종속항이라는 것으로 보기 때문에 이에 대한 적용은 일단 독립 청구항으로 기재된 것에 한하여 법의 문언 그대로 해석함이 바람직하다.

㉠ 전부를 인용하거나 대상이 달라지는 인용

이 경우는 타청구항의 특징을 모두 포함하는 것으로 1출원의 요건을 만족할 경우에 한하여 출원인의 권리보호를 위해서 허용되어야 할 것이다.

<예5>

(한국 -> 가능) (일본 -> 가능)

1. 재료 X로부터 된 백열체
2. 청구항 1 기재의 백열체를 갖는 전구
3. 청구항 2 기재의 전구를 갖는 서치라이트

위의 <예5>에 있어서 백열체 이외의 부분에는 특징이 없다고 하더라도 각 청구항으로부터 보호를 받고자 하는 발명이 명료하게 파악되는 한 이와 같은 기재는 허용된다.

가령, 청구항 2와 청구항 3의 기재가 아니라도 청구항 1의 백열체를 이용한 전구나 서치라이트를 판매한다면 특허발명의 실시에 상당하는 것으로 생각된다.

또한 청구항 1만 혹은 청구항 2 또는 3만을 특허청구범위에 기재해서 특허를 취득한 경우와 비교해서, 제3자가 청구항 1~3의 어떠한 특허발명을 실시하고 있는 경우에 권리주장을 보다 직접적으로 단순 명백하게 행할 수 있다는 이점은 있으나, 만약 다른 물건에 제1항을 이용할 경우 오히려 권리자가 간접침해를 입증해야 한다는 부담이 있다는 것도 무시할 수 없는 사항이다.

EPO에 있어서도 이와 같이 인용된 청구항 모두의 특징을 포함하는 청구항은 모두 인정된다. 미국에서는 인용된 청구항에 극히 흔한 구성을 부가해서 전체 장치로 하는 경우에는 Old combination(공지조합)이라 하고 그 기재를 인정하지 않지만 그것에 대한 비판도 있다.

<예6> 다른 카테고리로서 표현된 청구항의 인용 (한국 -> 가능) (일본 -> 가능)

1. 특정 구조의 볼베어링
2. 특정공정에 의한 청구항 1 기재의 볼베어링의 제법

-
1.X X 방법 (Process)
 2. 제1항의 X X 방법에 의한 ○○ 물건 (Product)

이러한 경우는 '볼베어링의 기술이 특정공정에 의해 제한'된 것으로 판단되어질 수 있으나, 이는 물건을 생산하는 방법의 하나로 상호 독립항으로 기재함이 타당하다. 또한 이 발명의 단일성 요건은 시행령 제6조 제1항 제2호에 의하여 가능하다.

제6조【특허출원의 요건】①법 제45조제2항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 다음 각 호의 1에 해당하여야 한다.

1. 물건 또는 방법에 관한 1독립항을 기재한 출원
2. 물건에 관한 1독립항을 기재한 경우에 다음 각목의 독립항을 선택하여 기재하거나 모두 기재한 출원
 - 가. 그 물건을 생산하는 방법에 관한 1독립항
 - 나. 그 물건을 사용하는 방법에 관한 1독립항
 - 다. 그 물건을 취급하는 방법에 관한 1독립항
 - 라. 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에 관한 1독립항
 - 마. 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건에 관한 1독립항
 - 바. 그 물건을 취급하는 물건에 관한 1독립항

미국의 경우, 이러한 종속항 기재형식에 대한 거절사례는 없다고 하나, 그 대신 우리 법이나 일본법처럼 단일성에 관한 구체적인 규정이 없는 것이어서 상술한 바와 같이 취급함이 타당하다고 사료된다.

일본의 경우, 이러한 경우에는 청구항의 기재가 불명료하게 되지 않는 한 다른 청구항을 인용하여 인용형식청구항으로서 기재할 수 있다고 설명하고 있다.

반면에 화학분야의 Product-by-Process와 같은 특수한 형태의 청구항에 있어서는 비록 제2항이 물건에 관한 청구항이지만 제법으로 한정된 물건이므로 종속청구항으로 보아야 할 것으로 생각된다.

그런데, 종속항의 개념이 인용항이 신규할 경우 그 인용항을 한정하고 부가하여 구체화하는 사항은 더욱 신규한 것이어서 만약 공지된 물건(product)의 출원발명을 신규한 방법(process)의 발명으로 종속시켰다고 가정했을 때 이러한 종속청구항은 특허된다는 모순점이 나오게 되나, 통상 발명은 단순히 process로만 표현되어야 할 것이 있고, product 만으로 표현되어야 할 것이 있는 반면에, 상기 2가지를 동시에 청구범위에 기재하지 않으면 보호가 어려운 것도 많다. 특히, 상술된 Product-by-Process의 경우는 청구범위의 기재형태 중 특수한 형태로 구분하고 있고, 단순히 공지된 물건(Product)에 새로운 방법(Process)으로 한정시켰다고 해서 이것이 특허될 수 있는 사항으로 보아서는 아니 될 것이다.

즉, Product는 Article of manufacture(제조품)가 신규할 때 특허될 수 있으나, 그것이 제조되는 Process(방법)에 의한 것 이외에 특별히 규정할 수 없을 때는 이와 같은 Product Claim은 정당한 것으로 보고 있다.

따라서 Product-by-Process의 경우는 Product나 Process가 모두 신규한 경우에 한하여 출원인의 자유로운 의사에 따라 독립항으로 기재해도 좋고, 종속항으로 기재해도 좋을 것으로 여겨진다.

<예7> Sub combination의 청구항의 인용 (한국 -> 가능) (일본 -> 가능)

1. 특정구조의 나사돌기를 갖는 볼트
2. 청구항 1 기재의 볼트와 결합하는 특정구조를 가진 나사 홈을 갖는 너트

이러한 경우 특정구조의 볼트와의 관계를 하나의 항으로 포괄하여 기재할 수 있다면 '부가하여 구체화'된 것으로 판단된다.

㉔ 전부를 포함하지 않는 인용

이 경우의 전형적인 예는 선행하는 타청구항의 구성요건의 일부를 치환해서 청구항을 기재하는 경우이다. (<예8>-<예10> 참조)

<예8> 인용된 청구항의 구성요건의 일부를 치환 (한국 -> 가능) (일본 -> 가능)

1. 치차 전동기구를 구비한 특정구조의 전동장치
2. 제1항에 있어서, 치차 전동기구 대신에 벨트전동기구를 구비한 특정구조의 전동장치

이러한 경우 '한정' 또는 '구체화'의 어느 것도 해당되지 않으므로 청구항 전부가 상호 대등한 관계의 기술적 표현일 때, 즉 상호 배타적인 관계일 경우는 종속항으로 인정하는 것은 법 취지에 위반된 것으로 2개의 독립항으로 기재되어야 한다.

일본의 경우는 전술한 바와 같이 우리 나라의 종속항의 개념과는 달리 단순한 인용항의 개념으로 인용만 된다면 청구항으로 간주되어 상기와 같이 <예8>의 경우에도 기재가 가능하다고 설명되고 있다. 그러나 <예9>와 같이 청구항의 전체가 불명료해질 우려가 있는 경우에는 이를 허용하고 있지 않다. 더구나 우리의 법조문으로 보아서는 다음의 <예9>는 <예10>과 같이 2개의 독립항으로 구분하여 기재하는 것이 바람직하다.

<예9> (한국 -> 가능) (일본 -> 불가)

1. 특정구조로 된 에어컨 장치 (V+W+X+Y+Z)
2. 제1항에 있어서, X 대신에 A를 갖고, Y 대신에 B를 갖고, Z 대신에 C를 갖는 것을 특징으로 하는 에어컨 장치 (V+W+A+B+C)

<예10> (한국 -> 가능) (일본 -> 가능)

1. 특정구조로 된 에어컨 장치 (V+W+X+Y+Z)
2. 특정구조로 된 에어컨 장치 (V+W+A+B+C)

㉔ 인용되지 않는 종속청구항

이의 전형적인 예는 타청구항의 구성의 일부를 삭제하여 기재하는 경우로서 그 청구항의 기재가 불명료한 것으로 판단되어 종속청구항으로 기재할 수 없다.

<예11>	(한국 -> 불가) (일본 -> 불가)
1. 특정구조의 에어컨 장치 (X+Y)	
2. 제1항에 있어서, Y를 갖지 않는 것을 특징으로 하는 에어컨 장치 (X)	

위의 <예11>과 같이 기재된 경우, 청구항의 기재는 Y의 구성을 갖지 않는다고 하는 청구항의 표현이 소위 '부정적 표현'으로 청구항의 내용이 추후에 어떻게 변경될 지 추측이 불가능할 뿐만 아니라, '한정' 혹은 '부가하여 구체화'의 어느 것에도 해당하지 않는다고 판단되어 이의 허용이 불가하다. 오히려 종속항인 제2항의 청구범위가 넓다.

그러나 이 경우 청구항 "2"를 독립 청구항 "1"로 하고, 청구항 "1"을 종속 청구항 "2"로 해서 다음 <예12>와 같이 간결명료하게 '부가하여 구체화'할 경우는 가능하다고 보아야 할 것이다.

<예12>	(한국 -> 가능) (일본 -> 가능)
1. 특정구조의 에어컨 장치 (X)	
2. 제1항에 있어서, Y를 갖는 것을 특징으로 하는 에어컨 장치 (X+Y)	

㉕ 상이한 카테고리에 대한 종속항

<예13>	(한국 -> 가능) (일본 -> 가능)
물 1.(독립항) 특정구조의 볼베어링	
2.(종속항) 제1항에 있어서, 환상 완충체를 갖는 볼베어링	
3.(종속항) 제1항에 있어서, 흑연 볼을 갖는 볼베어링	
방법 4.(독립항) 특정공정에 의한 볼베어링의 제법	
5.(종속항) 제4항에 있어서, 검사공정을 갖는 볼베어링의 제법	

각 카테고리에 2이상의 청구항이 있을 경우 각 카테고리의 독립항을 먼저 기재하고 각각의 그룹으로 그 종속항을 순차적으로 기재하는 것이 바람직하다.

그러나 이와 달리 종속항 제2, 3항이 제4, 5항 뒤에 기재된다고 해서 거절의 사유가 된다고는 볼 수 없고, 기재의 명료성의 관점에서 보아 수십 개의 항이 복잡하게 기재되어 전체적으로 그 기재가 명료치 않을 경우는 이의 시정을 요구할 수 있다고 본다.<예3>의 설명 참조)

또한, 카테고리 중 출원발명의 가장 중심이 되는 카테고리의 발명을 먼저 기재토록 하는 것이 바람직하고, 현행 [IPC 분류체계] 및 [심사관 지정]과도 관련해 볼 때, 출원인이 가장 중심이 된다고 판단되는 카테고리를 먼저 기재함으로써 심사도 바람직하게 이루어지리라 생각된다. 이에 대한 판단은 출원인의 자유로운 의사에 맡겨도 하등의 문제는 없다고 사료된다.

그러나 하가지 유의사항은 출원공개를 위하여 출원을 먼저 분류한 후 심사 Search 과정에서 이에 관한 선행기술을 조사할 경우, 전술한 내용의 일관성이 결여되어 있다면 Search 시간을 이중적으로 낭비할 수도 있는 것이다.

EPC의 경우에는 심사편람에서 시행규칙 제30조(a)항과 (c)항에 조합에 있어서는 물(Product)에 중요성을 두고 있으며, 발명의 본질은 주로 그 물(Product)에 있어야 한다고 하고, (b)항의 조합에 있어서는 방법에 중요성을 두고 있으며, 발명의 중심은 주로 방법에 있다고 설명하고 있다.

㉖ 청구항 기재의 표현에 없는 내용의 인용

이 경우의 전형적인 예는 종속항의 기재에 없는 사항을 '한정하거나 부가하여 구체화'할 경우

소위 말해서 종속항의 기재에 있는 사항이란 '단순한 종속항의 문헌적인 기재의 내용'에 대해서만 해석하려는 경향이 있으나, 종속항이란 인용되는 청구항의 모든 것을 포함하는 것으로 되어 있어 설사 문헌적으로 표현되지 않은 기술적 내용도 종속항으로 '한정하거나 부가하여 구체화'할 수 있다고 본다.

<예14> (한국 -> 가능) (일본 -> 가능) 1.(독립항) 미끄럼 방지를 위한 횡간부(H)와 타이어에 연결하기 위한 연결부(C)를 포함하는 타이어 체인 (H+C) 2.(종속항) 제1항에 있어서, 횡간부의 양측에 로울러(B)를 부착한 타이어 체인 (H+C+B) (외적 부가) 3.(종속항) 제2항에 있어서, 연결부(C)는 고리 모양(C')으로 형성한 타이어 체인 (H+B+C') (내적 부가) 4.(종속항) 제3항에 있어서, 로울러(B)는 삼각형(B')으로 형성한 타이어 체인 (H+B'+C') (내적 부가)

위의 <예14>의 경우, 제2항의 종속항에는 횡간부(H)의 양측방에 로울러(B)에 관한 기술이 기재되어 있고, 제2항을 인용하는 제3항의 종속항에는 '제2항의 종속항에 기재되어 있지 않는 연결부(C)에 관한 사항을 종속시킨 것'으로 간주, 그 기재가 불가하다는 견해도 있지만 그 기술적 내용이 실질적으로 제2항의 종속항에 모두 포함되어 있으므로 이와 같은 형식의 인용도 가능하리라 생각된다.

또한, 종속항 제4항인 경우에는 3개의 항을 연속적으로 인용한 것으로 그 내용을 파악하려면 제1, 2, 3항의 모두를 조합하여 분석해야 되는 부담은 있지만, 이러한 경우는 단순한 하나의 항을 인용한 것이기 때문에 그 내용은 일반적으로 명확하게 파악할 수 있는 것으로 이것은 허용해도 좋을 것이다. 그 대신 청구항의 수가 조합, 분열 등에 의해 증가함으로써 청구범위가 불명료해지는 것을 근본적으로 제한할 수 있는 규정(동조 제6항 : 다수종속항의 다수종속항에의 인용금지조항)이 있는 것으로 상기와 같이 취급함이 바람직하다고 여겨진다.

<일본의 경우>

일본의 인용형식 청구항은 단순한 문언중복을 피하기 위하여 '88년에 개정된 것으로 우리의 종속항 기재형식과는 일부 다른 개념을 가지고 있다.

즉, 일본의 특허법 시행규칙 양식 16 [비고] 13에서 인용형식 청구항은 원칙적으로 인용되는 청구항의 뒤에 계속하여 기재한다.

<일본 예1> 1. 단열재를 포함한 건축용 벽재 2. 단열재가 발포스트로폴인 청구항 1 기재의 건축용 벽재
--

<일본 예2> 1. 특정구조의 가스센서 2. 방호용 케이스를 설치한 청구항 1 기재의 가스센서

<일본 예3> 1. 재질 X로 된 백열체 2. 청구항 1 기재의 백열체를 갖는 전구

위와 같은 예 이외에 선행하는 다른 청구항의 구성요건을 일부 치환하는 청구항을 기재하는 경우, 선행하는 다른 청구항 중 카테고리 표현이 다른 청구항을 기재하는 경우 등에도, 청구항의

기재가 불명료하게 되지 않는 한 다른 청구항을 인용하여 인용형식 청구항으로서 기재하여, 청구항의 기재를 간명하게 할 수 있다.

<일본 예4> 인용되는 청구항의 구성 요건의 일부를 치환하는 인용형식 청구항

1. 치차전동기구를 갖춘 특정 구조의 전동장치
2. 청구항 1 기재의 전동장치에 있어서, 치차 전동기구에 대신하여 벨트 전동기구를 갖춘 전동장치

<일본 예5> 다른 카테고리로 표현된 청구항을 인용하여 기재하는 인용형식 청구항

1. 특정구조의 볼베어링
2. 특정의 공정에 의한 청구항 1 기재의 볼베어링의 제법

<일본 예6> 서브 콤비네이션의 청구항을 인용하여 기재하는 인용형식 청구항

1. 특정구조의 나사를 갖는 볼트
2. 청구항 1 기재의 볼트와 끼워 맞추는 특정구조의 나사홈을 갖는 너트

그리고, 인용형식 청구항도 독립형식 청구항과 똑같이 각 청구항마다 독립한 존재임에는 변함이 없다.

⑤ 시행령 제5조 5항 (택일적 기재)

⑤2이상의 항을 인용하는 종속항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야한다.

인용되는 2개 이상 항의 번호는 선택적으로만 기재하여야 하는데 “선택적으로만”의 기재방식은 다음과 같다.

① “또는”, “or”, ② “A 내지 B 중에서 어느 하나”

그러나 인용되는 항간에 “ 및”, “과”, “and” 등등의 단어를 사용함으로써 인용되는 2개의 항이 동시에 존재하는 것으로 표현하지 말 것. (Markush 청구항에서는 가능)

따라서 특허청구범위의 표현으로서 적절한 표현방식은 다음과 같다.

① 제 1항에 있어서, ② 제 1항 또는 제 2항에 있어서, ③ 제 2항에 있어서, ④ 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서

반면 바람직하지 못하거나 틀린 표현의 예는 다음과 같다.

① 제 1항과 제 2항에 있어서, ② 청구범위 1, 또는 청구범위 2에 있어서, ③ 청구범위 1, 2, 또는 청구범위 4에 있어서, ④ 청구범위 1과 2에 있어서, ⑤ 청구범위 1 및 2에 있어서, ⑥ 청구범위 1과 청구범위 2에 있어서, ⑦ 독립청구범위 1에 있어서, ⑧ 청구범위 1 내지 청구범위 2에 있어서, ⑨ 독립항 1에 있어서, ⑩ 독립청구범위 1 또는 2에 있어서, ⑪ 종속청구범위 1에 있어서, ⑫ 종속청구범위 1, 2, 3 또는 4에 있어서

따라서 청구범위기재의 예는 다음과 같다.

① (독립항), ② 제 1항에 있어서, ③ 제 2항에 있어서, ④ 제 3항에 있어서, ⑤ 제 2항 또는 제 3항에 있어서, ⑥ 제 4항에 있어서, ⑦ 제 3항 또는 제 4항에 있어서, ⑧ 제 7항에 있어서, ⑨ 제 4항 또는 제 8항에 있어서, ⑩ 제 2항 또는 제 3항에 있어서

위 예시 중에서 4항 및 5항 중 “또는”이라고 표현한 것이 택일적으로 인용한 예이며 또 ○항 내지 ○항 중 어느 하나라고 표현한 것도 선택적으로 인용한 것이라 할 수 있다.

그러나 복수항을 복수항에 인용할 수는 없다. 위의 예에서 “제 2항 또는 제 5항에 있어서”, “제 5항 또는 제 7항에 있어서”와 같은 인용은 할 수 없다.

이 규정은 ‘하나의 청구항에는 하나의 발명이 기재되어야 한다는 것이 기본 원칙이기는 하나, 예외적으로 다른 복수의 청구항을 인용함으로써 그 기재가 다수의 발명을 간소하게 표현할 수 있

도록 하기 위한 방법의 하나의 청구범위 전체가 불명료해지지 않도록 하기 위하여 시행령 제5조 6항에서는 인용할 수 있는 청구항수를 제한하고, 또한 청구항의 인용방식에 있어서도 택일적인 기재형식으로 규정하고 청구범위의 불명료한 부분을 최대한 억제하는 것이기 때문에 이 조항(5항)은 '택일적'이라는 표현 문구상의 문제일 뿐 다른 문제는 없다. 따라서 상술한 택일적 용어를 사용하면 문제될 것이 하나도 없다.

따라서 종속항이 '제3항 및 제4항의 장치'라고 표현되어 있을 경우에는 2개의 항이 'and' 조건으로 연결되기 때문에 청구항의 기술적 내용이 불명료해질 수 있다고 보아진다.

여기서 청구항의 기재내용에 있어서도 용어 '및', '또는' 등으로 인한 청구범위의 거절에 대한 시비가 흔히 일어날 수 있고, 또한 흔히 일어났고 기술분야에 따라 엄격히 구분되어야만 될 것도 상당히 많은 것으로 이러한 용어를 사용했을 경우에는 청구범위의 불명료성은 필히 한번 점검해야만 한다.

⑥ 시행령 제5조 6항 (다수종속항의 이중인용 금지)

⑥2이상의 항을 인용하는 종속항은 2이상의 항이 인용된 다른 종속항을 인용할 수 없다.

- | | |
|--|-----------------------|
| <p><예15></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (독립항) 2. (독립항) 3. (종속항) 제2항에 있어서, 4. 제2항 또는 제3항에 있어서, 방법 (다수종속항) 5. 제3항 또는 제4항에 있어서, 방법 (부적합한 예) | (한국 -> 가능) (일본 -> 가능) |
|--|-----------------------|

위의 <예15>와 같이 2이상의 청구항을 인용한 항을 다수종속항이라고 하고, 이를 다수종속항에는 인용할 수 없도록 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 다수종속항이 다수종속항에 인용됨으로써 청구항의 수가 조합.분열에 의하여 증가되고, 이로 하여금 청구항이 불명료해질 우려가 있기 때문에 청구범위의 명확성을 보장하려는 것으로 보인다(PCT의 경우도 이와 같이 운용하고 있다). 그러나 이는 제한적이긴 하지만 다수항 인용형식으로 청구항을 기재하면 특허청구범위의 기재를 간결.명료하게 할 수 있다.

즉, 아래의 <예16>과 같이 4개의 항으로 기재될 수 있는 사항이 아래 <예17>과 같이 3개의 항으로 줄일 수 있는 것이다.

- | | |
|--|-----------------------|
| <p><예16></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특정구조를 갖는 에어컨 장치 (X) 2. 풍향조절기구(A)를 갖는 청구항 1 기재의 에어컨 장치 (X+A) 3. 풍량조절기구(B)를 갖는 청구항 2 기재의 에어컨 장치 (X+A+B) 4. 풍량조절기구(B)를 갖는 청구항 1 기재의 에어컨 장치 (X+B) | (한국 -> 가능) (일본 -> 가능) |
|--|-----------------------|

- | | |
|---|-----------------------|
| <p><예17></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 특정구조를 갖는 에어컨 장치 (X) 2. 풍향조절기구(A)를 갖는 청구항 1 기재의 에어컨 장치 (X+A) 3. 풍량조절기구(B)를 갖는 청구항 1 또는 청구항 2 기재의 에어컨 장치 (X+B 또는 X+A+B) | (한국 -> 가능) (일본 -> 가능) |
|---|-----------------------|

그러나 무표심판의 경우, 예를 들면 위의 <예16>의 청구항4에는 무효이유가 있고, 청구항 3에는 무효이유가 없으면, 특허는 청구항별로 무효되기 때문에 청구항 3에 대해서는 무효되지 않고 남는데 반하여, <예17>에서 다수항 인용형식 청구항으로서 기재한 청구항 3은 일부의 무효이유를 갖지 않을 지라도 특허된 청구항이 포함된 그대로 '청구항 전체가 무효'가 되어 버리는 불이익도

있다. 이 경우 특허권자는 정정심판에 의해 무효이유가 있는 청구항 1 및 2를 삭제하고, 그 일부에 무효이유를 갖는 청구항 3을 아래 <예17'>과 같이 정정하여야 할 것이다. 이 예는 단순히 청구항의 수가 적은 청구범위를 예시하여 설명하였지만, 특허출원의 경우는 통상 수십 개의 청구항이 존재하기 때문에 주의를 해야 한다.

<예17'> (정정후) 1. 풍향조절기구(A) 및 풍량조절기구(B)를 갖는 특정구조의 에어컨 장치 (X+A+B)	(한국 -> 가능) (일본 -> 가능)
--	-----------------------

<일본의 경우>

이 부분에 대한 일본의 인용형식 요건은 우리의 종속항 기재요건과는 상이하다. 즉 인용항의 택일적인 기재에 대한 취급은 동일하지만 그 기재가 명료하다고 판단되는 이상 다수종속항에 다수종속항의 인용을 허용하고 있다.

즉, 다수항 인용형식 청구항이란, 다른 2이상의 청구항(독립형식, 인용형식을 불문한다)을 인용하여 기재한 청구항을 말하며, 특허청구범위 전체의 기재를 간명하게 하는 것으로서 이용된다.

이 형식에 의한 청구항은 통상의 인용형식으로 복수의 청구항에 각각 기재하는 경우와 비교하여 기재면.요금면에서의 장점이 있다 하더라도, 파기.무효심판의 단위로서는 하나가 되기 때문에 간추려서 파기 또는 무효의 대상이 되는 등의 단점도 내포하고 있다고 할 수 있다. 이 때문에 통상의 인용형식 청구항으로 하느냐 다수항 인용형식 청구항으로 하느냐는 이러한 점을 충분히 비교.검토한 후에 결정해야 할 것이며, 그 기재의 선택은 출원인의 자유이다.

다수항 인용형식으로 청구항을 기재할 때에는, 원칙적으로 다른 2이상의 청구항을 택일적으로 인용하고, 또한 이들에 동일한 기술적 한정을 붙여서 기재하여야 한다고 설명하고 있다.

<일본 예7> 적절한 예 1. 특정의 구조를 갖는 에어컨 장치 2. 풍향조절기구를 갖는 청구항 1 기재의 에어컨 장치 3. 풍량조절기구를 갖는 청구항 1 또는 청구항 2 기재의 에어컨 장치
--

다수항 인용형식으로 기재하는 경우, 그 기재가 불명료해지지 않도록 유의한다. 다음의 같은 경우는 그 기재가 불명료하게 되어 적절하지 않다.

<일본 예8> 청구항의 인용이 택일적이 아님으로써 불명료해지는 예 1. 특정의 구조를 갖는 에어컨 장치 2. 풍향조절장치를 갖는 청구항 1 기재의 에어컨 장치 3. 풍량조절기구를 갖는 청구항 1 및 청구항 2 기재의 에어컨 장치
--

<일본 예9> 인용되는 청구항에 동일한 기술적 한정을 붙이지 않음으로써 불명료해지는 예 1. 특정의 구조를 갖는 에어컨 장치 2. 풍향조절장치를 갖는 청구항 1 기재의 에어컨 장치 3. 풍량조절기구를 갖는 청구항 1 기재의 에어컨 장치 또는 타이머 기구를 갖는 청구항 2 기재의 에어컨 장치

<일본 예10> 인용되는 청구항에 동일한 기술적 한정을 붙였더라도, 다른 대상(다른 카테고리 등)의 청구항을 포함함으로써 불명료해지는 예

1. 특정구조의 인공심장
2. 특정공정에 의한 특정구조의 인공심장의 제조방법
3. 특정의 안전장치를 갖춘 청구항 1 기재의 인공심장 또는 청구항 2 기재의 인공심장의 제조방법

다른 2이상의 청구항의 인용이 택일적이 아니고, 동일한 기술적 한정을 붙이지 않은 경우라도 다음과 같은 경우에는, 특허청구범위의 기재가 간명하게 되어, 청구항의 기재가 불명료해지지 않으므로 그 기재가 인정된다.

<일본 예11>

1. 특정구조의 나사를 갖는 보울트
2. 특정구조의 나사홈을 갖는 너트
3. 청구항 1 기재의 보울트 및 청구항 2 기재의 너트로 된 체결장치

⑦ 시행령 제5조 7항 (먼저 기재금지)

⑦독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여서는 아니된다.

인용하는 종속항은 인용되는 종속항, 독립항보다 먼저 기재하여서는 아니되고, 인용되는 항 상호간의 순서는 요구하지 않는다.

<예18> 잘못된 인용예

(한국 -> 불가) (일본 -> 불가)

1. 특정구조(A)와 특정구조(B)로 구성된 볼베어링
2. 제3항에 있어서, 특정구조(B)는 (B')로 구성된 볼베어링 (A'+B')
3. 제1항에 있어서, 특정구조(A)는 (A')로 구성된 볼베어링 (A'+B)

위의 <예18>에서 보는 바와 같이, 제3항을 인용한 제2항이 먼저 기재되어 있음으로서 제3항을 파악해야만이 제2항을 파악할 수 있는 것으로, 이렇게 기재한다면 청구범위를 명확하게 파악해야 하는 심사관이나 제3자의 입장에서 볼 때 극히 바람직하지 않다. 따라서 제2항이 제3항의 뒤에 계속하여 기재하여야만 특정구조(A)를 A'로 종속시킨 뒤 특정구조(B)를 B'로 종속시켜 그 청구항에 기재된 발명의 범위(A'+B')를 명확하게 파악할 수 있는 것이다.

일본의 경우도 전술한 바와 같이, 인용항은 인용하는 청구항에 계속하여 기재함을 원칙으로 하고 있다.

⑧ 시행령 제5조 8항 (청구항마다 일련번호 기재)

⑧각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

이 규정은 청구항의 구분을 명확하게 하고, 각 청구항으로부터 특허를 받고자 하는 발명의 파악을 용이하게 하기 위한 것으로, 청구항 내에서도 개조체 형식(a>, b>, c 등)으로 기재하는 것도 명료하고 간결하다는 관점에서 바람직하다.

또한, 청구항에 연속적인 일련번호의 기재는 심사에도 용이하고 특히 요금산정에 있어서도 상당히 필요한 것으로 인정된다.

위에서 서술한 형식적 요건에 대해서는 그것을 위반하는 경우 거절이유(특허법 제42조 제5항)는 되지만, 이의이유(특허법 제70조 단서) 혹은 무효사유(특허법 제133조)로는 되지 않는다.

이와 같은 경우는 특허청구범위 기재형식의 위반만으로는 특허권의 내용인 발명에 실체적으로 하자가 있는 것으로 보지 않는다고 하는 취지로 보아야 할 것이다.

<일본의 경우>

이 부분은 일본뿐만 아니라 PCT에서도 동일하게 취급되고 있다. 즉 특허청구범위는 각 청구항마다 행을 바꾸어 기재하고 각 청구항에는, 그 기재의 순서에 따라 1로 시작되는 연속번호(아라비아 숫자)를 붙인다고 설명하고 있다.

3) 청구항 기재시 유의사항

(1) 일반적인 기재요령

① 특허청구범위의 청구항 중 구성요소는 특정기능을 수행하기 위한 “수단” 또는 “공정”으로 기재할 수 있다.

② 특허청구 범위의 보정기재 요령은 다음과 같다.

(가) 항이 삭제되는 경우 : 최초출원명세서의 항(이미 보정된 항을 포함)의 번호를 변경하여서는 안되며 삭제되는 항의 번호 다음에 “(삭제)”라고 표기한다.

(나) 항이 정정되는 경우 : ① 최초출원명세서의 항(이하 보정된 항을 포함)의 번호를 변경하여서는 안 된다. 이는 혼동을 일으키기 않기 위한 것이다. ② 정정되는 항의 번호 다음에 “(정정)”이라 표기한다. ③ 정정되는 부분 밑에 밑줄을 쳐야 한다. ④ 항이 2회 이상 정정되는 경우에는 항의 번호 다음에 그 정정회수를 부기하여 표기한다.

(다) 항을 신설하는 경우 : ① 최초출원명세서의 항(이미 보정된 것을 포함)의 번호를 변경하여서는 안 된다. ② 신설되는 항의 번호 다음에 “(신설)”이라 표기한다. ③ 신설되는 항의 번호는 기존 청구항의 최종항의 번호에 이어 표기한다.

이처럼 보정기재된 후 특허등록이 되어 청구항의 중간부분이 삭제되거나 청구항의 번호가 섞여 있는 경우에, 심사관의 재량으로 특허등록시 청구항의 번호를 재부여할 수 있다.

(2) 독립항 기재시 유의사항

① 독립항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 하며, 실질적으로 동일한 내용을 중복기재해서는 안 된다.

② 독립항은 다른 청구항을 인용하지 않은 형식, 즉 독립형식으로 기재하여야 한다.

다만, 항 번호가 인용되어 있으나 실질적으로 독립항으로 되는 경우는 다음과 같은 것이 있다.

㉠제 ○의 방법으로 제조된 물건

㉡하여 제 ○의 물건을 제조하는 방법

㉢제 ○의 방법으로 제조된 물건을 이용하여하는 방법

③ 독립항은 그 발명의 구성에 없어서는 안될 사항만을 간결하고 명료하게 기재하여야 한다.

④ 독립항의 기재는 각 구성요건을 개조식으로 기재하는 것이 그 내용을 이해하기 용이한 경우에는 다음 예와 같이 기재할 수 있다.

(예) 1. 다음의 각 공적으로 이루어지는 금속재료가공방법

㉠ 금속재료를 800~850℃에서 가열하는 제 1공정

㉡ 가열된 중조를 은조하는 제 2공정

㉔ 은조된 재료를 600℃로 재가열하는 제 3공정

㉕ 재가열된 재료를 소입(燒入)처리하는 제 4공정

(개조식 기재에는 청구항에 붙인 번호와 구별하기 위하여 (가), (나), (다), …… , (a), (b), (c), …… 등과 같은 연부호를 붙인다.

(3) 종속항 기재시 유의사항

종속항의 기재에 있어서 특히 유의할 점은 다음과 같다.

① 독립항이나 종속항의 기재에 있어서는 동일하지만 종속항은 후에 독립항으로 승격될 것을 고려하여, 발명의 구성에는 신규사항을 전부 기재하는 것이 좋다.

종속항에 기재하기 위해서는 발명의 상세한 설명란에서 구체적으로 기재되어야 하며, 여기에 기재되지 않은 사항을 기재하게 되면 요지변경이 되어 특허를 받을 수 없게 된다.

종속항이 다수 있는데 빠뜨린 부분이 있으면 후에 보충할 기회(또는 보정기간내)에 보충하도록 하여야 한다. 그렇지 않으면 그 부분에 대해서는 권리를 주장할 수 없게 된다.

또 종속항에 기재된 사항은 선원(특허법 제36조 1항)의 효과가 있으므로 발명의 상세한 설명에만 기재한 경우와는 다르다.

② 자명한 종속항은 기재하지 않도록 하여야 한다. 누구에게든지 자명한 사실이라고 의심의 여지가 없는 사항에 대해서 기재하는 것은 불필요한 수고에 불과하기 때문이다.

③ 종속항의 효과는 발명의 상세한 설명란에서 구체적으로 기재하여야 한다. 일반적으로 종속항의 대상은 구성 중 극소부분, 미세한 부분을 기재하는 것이 통례이며, 이 부분을 상세한 설명란에서 제외하거나 소홀히 다루기 쉬우므로 후일을 생각해서 상세하게 기재하는 것이 좋다.

작용효과 중에서 특유한 작용효과가 있는 것이 있으므로, 이를 기재함으로써 그 종속항의 의의가 명확하여지고 제3자에게도 새롭게 느껴지는 것이라면 종속항에 기재하여도 무방하다고 본다. 만약 이를 상세한 설명에 기재하지 않거나 대강 기재할 경우 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하지 않았다고 하여 거절될 염려가 있다. 이러한 특유효과를 당초에 기재하지 않고 후일에 보충하게 되면 요지변경의 문제가 발생하게 됨으로 거절을 당하게 된다.

4) 다항제에 따른 특허법상 타제도와와의 관계

(1) 다항제와 1특허출원의 원칙(§45)과의 관계

특허청구범위의 기재형식이 다항제라 하여 그것이 2 이상의 발명까지도 1출원으로 할 수 있는 것을 의미하는 것은 아니며, 다만 1출원으로 할 수 있는 발명의 단일성이 인정되는 범위(1군의 발명) 내에서 그 특허청구범위를 1 또는 2 이상의 항으로 기재할 수 있음을 의미한다. 1군의 발명을 하나의 출원으로 할 수 있도록 1발명의 범위를 1군의 발명까지 확대하고 그 발명을 보호받기 위한 특허청구범위의 기재방식을 다항제의 형식으로 취함으로써 발명자와 출원인 보호에 적정을 기할 수 있으며 1발명 1출원의 원칙은 다항제에 의하여 보다 효율적으로 운용될 수 있다 할 것이다.

(2) 일부보정

특허청구범위가 다항제로 기재되어 있는 경우 전체 뿐만 아니라 청구항마다 보정할 수 있다.

(3) 보상금청구권 또는 임시보호권리의 일부소멸

특허청구범위가 다항제로 기재되어 있는 경우 보상금청구권 또는 임시보호권리를 행사한 후 일부 청구항이 삭제보정되거나 보정각하에 의하여 보상금청구권 또는 임시보호권리의 일부가 소멸될 수 있다(§215).

(4) 일부무과실배상책임

보상금청구권 또는 임시보호권리가 일부 소멸된 경우 그 일부에 대하여 무과실배상책임을 져야 한다(§215).

(5) 일부이의신청

특허청구범위가 다항제로 기재되어 있는 경우 전체항에 대해서 뿐만 아니라 일부 청구항에 대해서 이의신청할 수 있다. 이의결정은 각 항별로 이의를 기재하여야 하며, 그 중 하나라도 이의가 성립되는 경우에는 그 출원은 전체가 거절되는데 이때 출원인은 그 항을 삭제함으로써 거절을 면할 수 있다.

(6) 일부무효심판청구

단항제하에서는 특허권에 일부무효사유가 있는 경우 그 특허권의 무효여부의 판단을 전체적으로 함으로써 그 특허권이 무효될 수도 있으나, 다항제하에서는 그 무효사유가 있는 항만을 무효시킬 수 있는 일부무효를 인정함으로써 특허권자는 그 특허권 전체가 무효로 되는 것을 면할 수 있으며, 무효심판을 청구하는 청구인도 필요한 항에 대하여만 무효심판을 청구할 수 있고, 또 그 청구의 기각을 면할 수 있어 유리하다(§133①).

(7) 일부무효와 정정심판과의 관계

① 일부무효에 해당하는 경우 반드시 정정심판에 의하여 일부무효에 해당하는 청구항을 삭제하지 않아도 된다.

② 따라서 특허권자의 입장에서는 정정심판의 비용을 절감할 수 있고, 특허청의 입장에서는 정정심판청구의 남발을 방지하고 정정심판 적체의 해소를 기할 수 있게 되었다.

(8) 일부권리범위확인심판청구

특허청구범위가 2 이상의 항으로 기재된 경우 어느 하나의 청구항만을 대상으로 하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다(§135①).

(9) 심판청구의 일부취하

심판청구는 심결이 확정될 때까지 이를 취하할 수 있다. 다만, 답변서의 제출이 있는 때에는

상대방의 동의를 얻어야 한다(§161①).

또한 2 이상의 청구항에 관하여 무효심판 또는 권리범위확인심판을 청구한 때에는 청구항마다 이를 취하할 수 있으며, 심판청구의 취하가 있는 때에는 그 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다(§161②).

(10) 특허권의 일부포기

① 특허청구범위가 다항제로 기재되어 있는 경우 과거에는 특허료를 절감하기 위해서는 정정심판을 청구하여 특허청구범위를 감축하였으나, 현행 개정법에서는 청구항의 일부포기로서 특허청구범위를 감축하여 특허료를 절감할 수 있다(§215). (3항 초과시부터 가산료있음)

② 따라서 특허권자의 입장에서는 정정심판의 비용을 절감하고 절차의 신속을 기할 수 있으며, 특허청의 입장에서는 정정심판청구의 남발을 방지하고 정정심판의 적체 해소를 기할 수 있게 되었다.

(11) 일부중용권

특허청구범위가 다항제로 기재되어 있는 경우 그 일부청구항이 착오로 특허되어 일부무효로 된 때에는 일부중용권(一部中用權)이 발생한다(§215).

(12) 특허권의 일부이전

특허청구범위가 다항제로 기재되어 있는 경우 청구항마다 일부이전할 수 있다(§215).

(13) 특허권의 일부질권

특허청구범위가 다항제로 기재되어 있는 경우 청구항마다 일부질권설정이 가능하다(§215).

5) 실용신안법상 다항제와의 비교

(1) 실용신안법에서는 1군의 고안개념이 없다.

(2) 따라서 등록청구범위에 1 독립항만으로 기재하는 것이 원칙이지만, 1 독립항만으로 기재하는 것이 부적법한 경우에는 2 이상의 독립항으로 기재가 가능하다.

5. 특허청구범위의 해석

1) 해석의 필요성

해석이란 ‘의사표시의 의미를 탐구하는 것’으로, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지나, 발명이란 추상적인 관념이기 때문에 문장으로 표현하더라도 모든 경우에 명백히 적용될 수 있을 만큼 명료하지 못하고, 문언의 의미를 확장하더라도 특허발명의 보호범위라는 법률적 가치판단이 행하여져야 하므로, 권리범위의 한계를 명확히 하기 위하여 특허청구범위를 해석할 필요성이 생긴다.

즉, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로 순수이론적으로는 특허청구범위에 기재된 문언이 객관적으로 명백하여 의문의 여지가 없다면 권리범위 판단을 위하여 그 해석은 불필요하다 하겠다. 그러나 구체적 사안에 있어서 청구범위를 그 해석에 의문이 없을 정도로 일의적으로 기재한다는 것은 발명의 속성상 거의 불가능한 것이라 하겠고, 그와 같은 실예도 발견하기 어렵다. 더욱 청구범위에 기재된 용어가 동일한 발명들에 있어서도 그 용어들은 각각의 상세한 발명에 기재된 내용이나 각각의 출원시의 기술수준에 따라서 다른 의미로 해석될 여지가 있어 일의적으로 명백히 할 수는 없는 것이다. 이에 따라 청구범위의 해석 필요성이 대두하게 되는 것이다.

2) 해석의 일반원칙

(1) 권리일체의 원칙

특허청구범위에 복수의 구성이 기재되어 있는 경우 이들이 결합된 전체가 하나로써 보호되는 것이며 결코 각각의 구성이 보호되는 것이 아니므로 복수의 구성이 결합된 전체로서 권리를 파악 해석한다.

(2) 다기재 협범위의 원칙

다한정 협범위(多限定 狹範圍)의 원칙이라고도 한다. 특허청구의 범위는 기재하는 사항이 많으면 많을수록 보호의 범위는 좁게 해석된다.

따라서 청구범위의 기재에는 필요요건이 아닌 부수적 사항의 기재나 무용의 한정이 되지 않도록 세심한 주의가 필요하다. 그리고 극히 당연한 것이긴 하나 상위적 표현 보다 하위적인 표현일수록 보호의 범위는 좁게 해석된다.

(3) 청구범위 기준의 원칙과 상세한 설명 참작의 원칙

상세한 설명 또는 도면에는 기재되어 있으나 특허청구범위에 기재되어 있지 않은 발명은 권리범위에 속하지 않는다(청구범위 기준의 원칙).

그러나, 명세서에 개시되어 있는 기술의미보다 청구범위의 기재가 확대되어 있는 경우에는 명세서를 근거로 하여 제한적으로 해석하며 이는 청구범위의 해석에 있어서는 명세서의 상세한 설

명 및 도면을 참고하되 출원당시의 기술수준과 출원의 경우 등에 비추어 그 기술적 의미를 한정하여야 한다(상세한 설명 참조의 원칙).

3) 제반 학설

권리범위해석에 있어서, 일반적으로 용인되고 있다고 인정되는 기준은 일반적 기준으로 하고, 반대론도 있으나 제법 유력하던가 또는 주목하여야 할 견해로 인정되어 지는 기준을 참고적 기준으로 하여 해설한다.

(1) 일반적 기준

일반적 기준을 다시 둘로 나누어서 원칙적 기준과 구체적 기준으로 한다. 전자는 원칙적 내지는 기본적으로 인정되는 것이고, 후자는 그것에 의거한 구체적 기준이다.

(가) 원칙적 기준

① 청구범위 기준의 원칙

특허청구범위에 기재되어 있는 발명만이 권리범위의 판단기준이 되어야 한다. 바꾸어 말하면, 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 발명, 즉 발명의 상세한 설명 또는 도면에만 기재되어 있는 발명은 특허발명의 권리범위판단기준으로 해서는 안 된다.

② 상세한 설명 참작의 원칙

특허청구범위에 기재는 명세서 중 발명의 상세한 설명에 기재한 발명의 구성에 없어서는 아니 될 사항만을 간결하게 나타낸 것이므로, 일반적으로 그 기재만으로써 특허청구범위의 의의를 명확하게 이해할 수가 없다. 따라서 특허청구범위의 의미를 해석하는데는 발명의 상세한 설명을 검토하여 참작하여야 한다.

③ 출원의 경과 참작의 원칙

특허청구범위의 의미를 명확하게 이해하기 위해서는 출원으로부터 특허될 때까지의 경과를 통해서 출원인이 나타낸 의도 또는 특허청이 나타낸 견해를 참작하여야 한다.

* 미국의 특허법상 출원서류의 금반언 원칙

④ 공지사실 참작설

특허청구범위의 의미를 명확하게 이해하기 위해서는 출원시의 기술수준(공지사실)을 참작하여야 한다.

* 공지사실제외설

⑤ 의식적 제외설, 의식적 한정설

명세서 등의 기재에서 출원인이 특허청구범위에서 의식적으로 제외한 사항은 그 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

다시 말하면 출원인이 의식적으로 특허청구범위를 특정한 것에 한정시키고 다른 것을 배제하고 있는 경우에는 한정된 사항만이 권리범위에 속한다.

(나) 구체적 기준

① 인식한도설

발명자가 인식한 발명의 한도 이상에 걸쳐서 권리범위를 정해서는 아니 된다. 즉, 발명하지 아니한 사항에 대해서는 권리로 인정할 수 없다.

② 작용효과 중시설

특허청구범위 중 기술적 사항에 대하여 그 작용효과를 발명의 상세한 설명, 기타 서류(의견서, 심판청구서 등)에서 특기하고 있을 때, 그 기술적 사항은 발명 구성상 필수요건으로 해석하여야 하므로 이것을 구비하지 아니한 것은 권리범위에 속하지 아니한다.

③ 실시태양불구속의 원칙 / 실시태양요지설

발명의 상세한 설명 또는 도면에 기재된 실시태양만으로 한정하여 권리범위를 정해서는 안 된다.(실시태양불구속의 원칙)

그러나 특허청구범위에 기재한 발명범위가 발명의 상세한 설명에 기재한 발명범위 보다 넓은 경우(대부분의 화학발명) 등에서는 실시태양(실시예)에 한정하여 구성범위를 정하여야 한다.(실시태양요지설)

④ 진보성판단 제외설

특허발명에서 용이하게 생각되는 것(진보성이 없는 것)은 그 발명의 구성범위에 속하지 아니한다.

권리범위에 속하는가의 여부는 발명의 동일성 판단의 문제인 만큼 동일성을 갖지 아니하는 것까지 권리범위를 미치게 하는 것은 부당한 발명보호가 되기 때문이다.

⑤ 이용발명

이용발명은 피이용발명의 권리범위에 속한다.

⑥ 구성요건의 일부를 빠뜨린 것에 관한 기준

특허청구범위에 기재된 사항(구성요건)이 다수 있는 경우에 그 중 하나라도 빠진 것은 타요건의 구비 여부를 논할 것도 없이 권리범위에 속하지 아니한다.

⑦ 균등발명

특허청구범위에 기재된 발명과 균등한 것은 그 권리범위에 속한다.

⑧ Jepson Type Claim의 전제부분(Preamble Clause) 해석

특허청구범위의 기재로서 Jepson Type Claim 표시형식을 채택한 경우, 전제부분에 기재된 사항을 무시하고 권리범위를 정해서는 아니 된다.

(2) 참고적 기준

① 요부설

특허청구범위 중의 구성요건을 요부와 비요부(부수적 요건)로 구분하고 요부를 구비하는 기술은 비요부의 유무 또는 상위에 관계없이 권리범위에 속한다고 하고, 역으로 요부를 구비하지 아니하는 기술은 비요부의 유무 등에 관계없이 권리범위에 속하지 아니하는 것으로 한다.

② 일반적 발명사상론

일반적 발명사상론은 독일에서 1920년의 판결이래, 독일에서 점차적으로 유력해지고 오랜 기간 학설, 판례상의 정설적 지위를 보유하게 된 설이다.

일반적 발명사상론은 특허청구범위의 기재는 권리범위 판단상 일응(一應)의 기준(가이드 라인)으로 하면 족하고, 기재 문언 그 자체에 구애될 필요는 조금도 없으며, 특허청구범위의 기재에서 추출된 것과 발명사상에서 동일(또는 공통)하다고 보는 한 모두 권리범위에 속한다고 하는 것으로, 소위 중심한정주의의 전형적인 것으로 소위 주변한정주의와 서로 대립하는 설이다.

③ 공지사실 제외설

특허청구범위 중 일부가 공지인 경우 그 공지 부분에는 권리의 효력이 미치지 아니한다.

④ 공유재산권, 자유로운 기술수준의 항변

특허청구범위의 전부가 공지인 경우 그 공지발명의 무효심결 확정에 관계없이 그 공지기술에는 권리의 효력이 미치지 아니한다. 즉, 공지기술은 공유재산이기 때문이다.

4) 주변한정주의와 중심한정주의

(1) 주변한정주의(Peripheral Definition) (전체 정의 방법)

영미법계의 주변한정주의와 대륙법계의 중심한정주의에 의한 특허청구범위의 해석의 차이가 특허청구범위의 기재형식을 결정지었다. 특허청구범위의 기재형식은 적극적으로 권리를 획득하기 위한 기능과 소극적으로 권리의 다툼이 있을 때에 이에 대응하는 권리의 해석의 기준을 위한 기

능을 발휘하는데 적당해야 한다. 두 기능이 상호 저촉되는 듯하지만 실은 상호보완역할을 한다. 왜냐하면 특허청구범위의 기재는 법원에서의 해석의 결과에 따라 변하고 그 작성도 해석의 의도 대로 바뀌어지기 때문에 위의 양 기능은 상호 보완적일 수밖에 없다. 특허제도의 선진국인 영미법 계통의 국가에서는 일반적으로 특허청구범위를 해석하는 기준으로서, 소위 주변한정주의를 채용하고 있다.

주변한정주의는 용어의 의미대로 “특허청구범위에서 출원인 스스로가 한계를 정한 보호영역에만 충실하게 보호해준다는 해석방법”이다. 즉 특허청구범위에 기재된 문언에 충실하게 권리범위를 해석하는 것이다. 다시 말하면 출원인의 발명내용 중 스스로가 정한 권리영역(영역의 광범을 출원인이 인지함이 없이 기재했다하여도)외에 이를 확대해석하지 않는다는 해석방법이다.

그러므로 특허청구범위의 해석에 관해서 주변한정주의를 택하고 있는 제도하에서는 특허청구범위의 작성은 출원인이 소망하는 최대의 넓은 청구범위로 기재할 수밖에 없다. 즉 특허청구범위가 가장 상위개념의 구성요소의 결합으로 기재되어야 제대로 된 권리를 얻을 수 있다. 그러나 당해 발명의 기술적인 영역을 출원인이 쉽게 정할 수 없으므로 자칫 그 영역을 벗어나서 특허청구범위가 특정되지 않았고 명확하지 않다는 이유로 거절되는 경우가 많이 있을 수 있다.

주변한정주의에 의한 권리범위가 넓은 특허청구범위의 기재에 따른 장단점에 관하여 고찰해보면, 출원인이 발명의 영역을 특허청구범위에 명확하게 한계지어 기재하므로 일반 제3자가 발명의 기술내용과 그 권리범위를 명확하게 파악할 수 있는 이점이 있다. 반면에 특허청구의 문언에 충실하게 해석함으로써 출원인이 잘못 확정한 영역에 의해서 거절될 확률이 높다. 그러므로 출원인은 특허청구범위를 작성하는데 많은 노력을 기울여야 하는 단점이 있다. 또 출원인(발명자)의 발명을 실질적으로 충분히 보호해주지 못하는 결함이 있다.

미국은 그 대표적인 나라로 되어 있다.

여기서 주변한정주의와 균등론을 비교해보자. 미국이 과거 특허청구범위 해석의 중심한정주의를 택하고 있던 때(1836년 미국 특허법)에 판례로 탄생한 “균등론”은 중심한정주의의 권리의 경계(영역)의 불명확성을 보충해주는 역할을 충실히 했지만, 주변한정주의를 택하고 있는 현재에도 균등이론은 주변한정주의의 구성요소의 균등론에까지의 확대해석으로 인한 발명의 실질적인 보호를 통해서 특허청구범위의 해석과 작성에 있어서 중요한 역할을 다하고 있다.

(2) 중심한정주의(Central Definition) (요점 정의 방법)

특허청구범위의 작성과 해석에 있어서 좁은 특허청구범위(중심한정주의) 및 넓은 특허청구범위(주변한정주의)라는 용어는 특허법상의 용어가 아니고, 특허청구범위의 해석 및 작성에 있어서 그 방법을 상호 대비 설명하기 위한 용어이다.

이는 서독이 그 대표적인 나라이다.

주변한정주의하의 특허청구범위는 발명을 실질적으로 보호한다는 측면보다는 권리범위를 명확하게 확정지어 기재함으로써 제3자에게 불측의 손실을 주지 않고, 또한 그 발명의 권리실체를 용이하게 파악할 수 있도록 하는 측면이 강했다고 볼 수 있다. 반면에 독일을 중심으로 하는 대륙법계 유럽국가들이 택하고 있는 중심한정주의는 “청구범위에 기재한 발명의 기술적 사상인 기술요부가 출원인이 구현한 가장 적합한 모델로 인정하고, 그 밖의 동일목적·동일효과를 구현하는 모델까지도 출원인의 발명내용에 포함되는 것으로 확장해석을 허용”하고 있다. 그러므로 중심한정주의하에서의 특허청구범위의 기재에 대해서는 다음과 같은 특징을 가지고 있다.

첫째, 출원인의 발명의 내용에서 그 구성요소를 최대한까지 넓혀서 기재할 이유가 없다.

둘째, 균등물에 의한 실시예를 일일이 기재하지 않아도 그에 대한 보호가 보장된다.

셋째, 출원인이 특허청구범위를 기재함에 있어서 보호받을 권리범위의 광범에 대하여 고민하지

않고 본인이 적당하다고 여기는 발명의 실시예 하나 정도만 기재해도 된다.

그러므로 주변한정주의하에서의 특허청구범위와 비교해 볼 때 보호받고자 하는 권리범위가 좁게 기재되어도 그 해석은 최대한 넓은 범위로 해석해주므로 출원인 특허청구범위를 기재하는데 대한 노력을 경감시켜주는 이점이 있다. 그러므로 명세서 상에 나타나는 발명의 실시예 하나 정도만 특허청구범위로 기재하면 충분하다.

그러나 중심한정주의하의 특허청구범위는 특허청구범위에 기재된 사항만으로는 일반공중이 그 특허권을 인식할 수 없으므로 불측의 피해를 입을 수도 있다. 그 결과 특허권의 권리범위에 대한 다툼이 특허권자와 일반공중 사이의 끊이지 않는 중대한 문제점이 있다. 이러한 이유로 미국이 당초의 중심한정주의에서 현재의 주변한정주의로 돌아섰다.

그러나 중심한정주의의 상기와 같은 결함을 방지할 방안이 나타났다. 즉 특허청구범위를 작성하는 방법에 있어서 그 해석이 명확하게 인식될 수 있도록 하는 방법이 채택되었다. 그 대표적인 것이 현재 유럽국가에서 널리 사용되고 있는 "Jepson-type"의 특허청구범위의 기재형식이라 볼 수 있다. 그 이유는 특허청구범위의 기재내용으로부터 발명의 요부를 쉽게 파악할 수 있도록 기재하는데 적합한 형식이기 때문이다. (Jepson-type의 한계는 '6-2) 청구항의 도입부' 참조)

5) 균등론과 금반언의 원칙

(1) 균등론

균등론이란 발명의 본질을 해석하는 방법으로써, 보호받고자 하는 사항에 의하여 발명의 상세한 설명의 뒷받침에 따라 청구범위를 해석하는 것을 말한다.

청구범위의 해석수단에는 문리해석론과 논리해석론이 있고, 논리해석론에는 확장해석론과 축소해석론이 있는 데, 확장해석론을 균등론이라 한다. 상술한 바와 같은 기타 여러 가지 해석원칙이 상존하는 데, 대부분 목적, 구성, 효과를 대비한다. 우리법 제97조(특허발명의 보호범위)는 "청구범위에 기재된 사항에 '의하여' 특허발명의 보호범위가 정하여진다"고 보고 있다. 이때 '의하여'의 문구의 영향을 해석하는 것이 균등론의 기능이다.

(2) 균등론의 필요성

① 문리해석론의 주장 근거

첫째, 청구범위 기능에 따른 해석 강조

청구범위의 보호범위적 기능에서, 특허청구범위는 보호받고자 하는 사항을 기재한 항(청구항)으로써 이는 금지구역을 의미한다. 그래서 청구항에 의한 금지구역을 침해하면 특허권의 침해가 되는 것이고, 구역이탈시에는 침해가 되지 않는다.

그리고 청구범위의 구성요건적 기능에서, 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 청구항을 기재할 것을 요구하고 있고, 이를 위반하면 거절이나 무효사유에 해당한다.

또한 특허법 제97조의 '~에 의하여'는 청구범위의 확장해석을 금지하는 것으로 파악하여 법적 안정성을 도모하고자 한 것이 문리해석론의 입장이다.

둘째, 확장 해석론의 경우 제도적 보완 규정 확보

완전한 명세서의 작성은 본래적으로 곤란하기 때문에 보정제도를 채택하였는데, 이러한 보정에 의해 명세서를 보완하게 된다. 그러므로 문리해석론의 입장에서는 확장해석론은 있을 수 없다고

본다.

② 문리해석론의 문제점 대두

첫째, 제97조의 ‘~에 의하여’를 엄격하게 해석하는 것은 실질적으로 동일한 발명을 표현상의 상위로 청구범위를 달리 작성하게 되면 권리침해가 아니라고 판단해야만 한다. 그러면 실질적으로 동일한 발명이 침해되기 때문에 특허권자의 보호가 미흡해지고, 발명의 보호가 유명무실해지는 문제점이 대두되었다.

둘째, 너무 확장해석 하면 제3자의 권리도 피해가 발생하므로, 양자를 조화시킨 균등론이 대두된 것이다.

(3) 균등론의 내용

① 일반적 균등론

한 발명이 $[A+B+C]$ 이고, 다른 발명이 $[A+B+C']$ 일 때, C와 C'을 비교하여 치환이 자명하면, 일반적 균등론에서는 이를 자명한 기술이고 단순한 설계변경일 뿐이므로 사상으로서의 발명과 동일한다고 판단하여 구성의 약간의 차이에도 불구하고 목적/효과가 동일하다고 본다.

② 예외적 균등론 (특별한 사정이 있는 경우)

가. 청구범위 문헌적 해석의 폐단 방지.

나. 장래 발생 가능한 모방 방지

동일 발명사상에 의거하여 개변(改變)(모방)이 용이하면 특허권자가 희생된다. 따라서 용이의 범위를 특별한 사정에 따라 제한적으로 설정하고, 명세서 전체를 합리적으로 이해한 결과에 따라 청구범위를 해석한다.

③ 원칙적 균등론 (3가지 이유) ----- 당연히 침해로 판단

가. 사상으로서의 발명이 동일한 것 : 청구범위 문언의 참뜻 (보충해석론)

* [의하여] : 단순한 문리해석론을 배제하는 것

나. 경험적으로 인정되어 확립된 법리 (경험칙론)

다. 발명의 본질을 보호 (보호범위론)

* 청구범위로부터 추출되는 발명의 본질 -> 보호대상

④ 균등론의 국제적 경향

EPC 제69조에는 “보호범위는 클레임의 문언으로써 결정되지 않으면 안 된다. 단, 명세서의 기재, 도면은 클레임을 해석하기 위하여 사용”한다고 하여 단순한 문리해석을 배제하고, 균등론을 용인하고 있다.

미국은 침해자가 발명이익을 훔치는 것을 방지하기 위하여 균등론을 채택하고 있다.

특히 미국에서 있어서는 ‘그레이버 탱크’ 사건의 대법원의 판결이 근대적인 균등이론의 출발점이 되고 있다. 만일 대상 물건이 본질적으로 동일한 방법으로 본질적으로 동일한 기능을 달성하

고 동일한 효과를 얻는 것이라면, 그 대상 물건은 침해하고 있다고 판단된다. 이것이 미국에 있어서 균등의 원칙이다. 특허발명과 대상물건이 본질적으로 동일한 방법으로 동일하게 실시되고 본질적으로 동일한 효과를 얻는 것이라면, 그것들은 예를 들어 명칭이나 형상 등이 달라도 동일한 것이라고 해석하는 것이다.

균등의 판단 시점은 일본에서는 출원시만으로 제한되어 있지만 미국에서는 침해시에 되는 경우도 있다. 또 특허성이 있는 개량발명이라도 균등의 범위안에 들어가는 경우가 있다.

미국에서는 균등의 원칙은 Claim의 범위를 확장시키기 위한 것으로만 사용되는 것이 아니고 Claim을 축소시키기 위해서도 사용된다. 미국에서 있어서는, 명세서에 구체적으로 개시된 내용 및 그것과 균등한 것에 특허의 범위가 미친다고 생각할 수 있다.

서독에 있어서는, Claim을 축소 해석하는 것(주변한정주의)이 아니고, "Claim의 범위를 최소의 것"(중심한정주의)으로 본다. 특허출원시에 장래의 모든 사태를 예측해서 완전한 Claim을 작성하는 것은 실제로 불가능하다는 것을 고려하고, 침해소송시에 법원이 독자적인 입장으로 특허 발명의 객관적인 범위를 확정해서 발명을 확보해야 한다고 하는 견해가 서독에서는 강하다.

(4) 균등론 적용상의 제외사항

- ① 자유기술(공지기술) -> 누구든지 실시할 수 있는 자유제한
- ② 선행사항 -> 권리를 요구하지 않아서 공고후 자유기술이 되는 것을 제한
- ③ 의식적 제외사항 -> 권리자가 의식적으로 청구범위에 분명히 제외

(5) 금반언(禁反言)의 원칙

균등의 원칙에 관련해서 늘 고려되는 것이 출원기록(출원경과기록 또는 출원포대) 금반언의 원칙(file wrapper estoppel)이다.

이것은 특허를 취득할 때에 Claim을 한정보정하고, Claim의 범위로부터 제외한 사항을 특허 후에 특허 발명과 균등하다고 주장하는 것을 금지하는 원칙이다. 일반적으로 ① 우선 선행기술에 의거하는 거절이 있고, ② 그것에 응답해서 Claim을 한정 보정했다고 하는 두 가지 요소가 금반언의 원칙의 적용에는 필요하다고 되어 있다.

그것이 전통적이면서 고전적인 금반언의 원칙의 견해이다. 그러나 현실에는 선행기술에 의거하지 않고 단지 기재불비를 이유로 하는 거절에 대해서 응답하고 Claim을 보정한 경우에 금반언의 원칙이 적용된 경우도 있다.

또 서독에 있어서는 미국과 마찬가지로 Claim의 확장해석에는 금반언의 원칙이 적용된다.

6) 해석의 기준

(1) 원칙적 기준

특허청구범위에 기재된 사항만을 기준으로 해석

(2) 참고적 기준

- ① 발명의 상세한 설명 및 도면 참작
- ② 공지사실 제외의 원칙
- ③ 출원경과 참작의 원칙
- ④ 의식적 제외사실의 참작

7) 미국 특허법 해석상의 균등론과 금반언의 원칙

(이는 [미국 특허법 실무] pp88~97의 내용을 전제한 것임.)

(1) 미국 특허법 해석상의 균등론 (Equivalents)

① 서 (Introduction)

원고의 특허에 대해서 피고에 의한 문헌적 침해가 없다면 원고가 균등론을 성공적으로 적용할 수 있는지를 검토한다. 한 법원에서는 균등론을 “특허된 발명과 단순히 명칭, 형상 혹은 모양에서 다른 장치로부터 특허권자를 보호함으로써” 그 내용보다 형식을 향상시키는 것을 방지하기 위한 것으로 기술했다. 예를 들어 피고가 원고의 청구항에 기재된 하나 혹은 그 이상의 구성요소를 생략하고 하나 혹은 그 이상의 다른 구성요소를 치환하였다면 균등론이 적용될 수 있을 것이다.

② 균등론에 대한 기준 (Test for the Doctrine of Equivalents)

“Graver Tank & Manufacturing co., v. Linde Air Products Co.”(이하 언급된 모든 미국의 판례자료는 인터넷상에서 구할 수 있음)에서 공표된 균등론의 기준은 피고의 구성요소의 치환이 “(실질적으로) 같은 결과를 얻기 위해서 실질적으로 같은 방법에 의해 실질적으로 같은 기능을 수행하는” 지의 여부이다.

Graver Tank 판결에서, 발행된 특허에 기재된 조성물은 칼슘 플루오라이드, 칼슘 실리케이트 그리고 마그네슘 실리케이트를 포함하고 있다. 마그네슘 실리케이트에서 마그네슘은 알칼리토류 금속이다. 피고의 조성물은 칼슘 플루오라이드, 칼슘 실리케이트 그리고 망간 실리케이트를 포함하고 있다. 망간 실리케이트에서 망간은 알칼리토류 금속이 아니다.

대법원은 피고가 그 조성물로부터 마그네슘 실리케이트를 생략했기 때문에(생략의 규칙), 문헌적 침해는 없다고 하였다. 계속하여 대법원은 마그네슘 실리케이트를 망간 실리케이트로 치환한 것을 근거로 하여 균등론을 검토하였다. 대법원에 따르면 “용접 조성물(welding composition)에 대한 문제를 알고 있는 전문가들은 망간이 특허된 플렉스 조성물에 있는 마그네슘과 균등하거나 치환될 수 있다는 것을 알았으며, 그들의 소견은 문헌에 의하여 확인되었다”고 균등론을 적용하여 대법원은 피고의 조성물이 특허를 침해했다고 판결했다.

균등론이 적용되면 출원기록 금반언의 원칙도 검토된다. Graver Tank 법정 이전에서 출원기록 금반언의 원칙이 관계된 사실이 없었다.

③ 균등론에 대한 설명 (Illustration of the Doctrine of Equivalents)

Graver Tank 사건에서 문헌적 침해와 균등론에 대한 논의가 다음의 <표1>에 설명되어 있다.

<표1>

1. 발행된 특허	칼슘 플루오라이드	칼슘 실리케이트	마그네슘 실리케이트
2. 피고 항목	칼슘 플루오라이드	칼슘 실리케이트	망간 실리케이트
3. 문헌적 침해	YES	YES	NO
4. 균등론	N/A	N/A	YES
5. 출원기록 금반언의 원칙	N/A	N/A	NO
6. 직접침해	YES	YES	YES

원고(특허권자)는 6번째란(직접침해)에 더 많은 "YES"를 갖게 되면 더 강력한 위치를 갖는다. 피고(추정된 침해자)는 6번째란(직접침해)에 "NO"가 많을수록 더 강력한 위치를 갖는다.

㉔ <표1>의 1번에서 5번째란 (Column 1 Through 5 in Table 1)

1번째란(발행된 청구항)에는 특허된 Graver Tank 조성물의 각 화합물, 즉 칼슘 플루오라이드, 칼슘 실리케이트 그리고 마그네슘 실리케이트를 각 예로 나누어 기재한다.

다음에 2번째란(피고 항목)에는 피고의 조성물의 각 화합물, 즉 칼슘 플루오라이드, 칼슘 실리케이트, 망간 실리케이트를 각각 1번란의 유사 혹은 동일한 화합물과 같은 열에 나란히 기재한다.

3번째란(문헌적 침해)으로 가서, 1번과 2번란의 같은 열에 있는 화합물들이 같은 지 다른 지의 여부에 따라 "YES" 혹은 "NO"를 기재한다. Graver Tank에서는 칼슘 플루오라이드는 동일하기 때문에 "YES"라고 적고, 칼슘 실리케이트도 동일하기 때문에 "YES"라고 적는다. 그러나 마그네슘 실리케이트와 망간 실리케이트는 다르기 때문에 "NO"라고 적는다.

4번째란(균등론)에서는 3번째(문헌적 침해)의 같은 열이 "YES"라고 되어 있으면 "적용할 수 없음(N/A)(not applicable)"로 기재하고, 3번란이 "NO"라고 기재되어 있으면 균등론이 적용될 지를 결정하여 "YES" 혹은 "NO"라고 기재한다. Graver Tank 사건에서는 칼슘 플루오라이드에 대한 문헌적 침해가 "YES"이기 때문에 "N/A"로 적는다. 청구된 마그네슘 실리케이트 화합물에 대해서 치환된 망간 실리케이트 화합물에 의한 문헌적 침해는 없다. 이 상황에서는 균등론이 검토되고 Graver Tank 법정은 이 균등론을 적용하였다. 균등론란에는 "YES"라고 기재한다.

5번째란(출원기록 금반언의 원칙)으로 가서는, 4번란(균등론)의 같은 열이 "N/A"이면 "N/A"라고 기재하고 4번란의 같은 열이 "YES"이면 출원기록 금반언의 원칙이 적용되는지 여부를 결정하여 "YES" 혹은 "NO"를 기재한다. Graver Tank 사건에서는 칼슘 플루오라이드와 칼슘 실리케이트에 대해서는 균등론을 적용할 수 없기 때문에 이에 대한 각각의 출원기록 금반언의 원칙란에는 "N/A"로 기재한다. 그러나 마그네슘 실리케이트와 망간 실리케이트에 대해서는 균등론을 적용하였기 때문에 금반언의 원칙이 검토되었다. 그러나 출원기록 금반언의 원칙에 관계된 사실은 분명히 존재하지 않았다. 그러므로 금반언의 원칙란의 마지막 열은 "NO"라고 기재한다.

㉕ <표1>의 6번째란 (Column 6 in Table 1)

6번째란(직접침해)으로 가서는, 다음에 기술된 네 가지 상황을 고려하여 완성한다. 이때는 3번, 4번 그리고 5번란에 기재된 자료를 기초로 한다.

<첫번째 상황>

3번란에서 문헌적 침해에 대해 같은 열에 "YES"라고 되어 있고, 4번란에서 균등론에 대해서는 "N/A", 5번란에서 출원기록 금반언의 원칙에 대해서도 "N/A"이면 6번란에서 직접침해에 대해서는 "YES"라고 기재한다. Graver Tank 사건에서는 이 첫 번째 상황에 기초하여 칼슘 실리케이트와 칼슘 플루오라이드에 대하여 직접침해가 있다. 그러므로 <표1>의 6번란의 직접침해의 1, 2번째 열에 "YES"라고 기재한다.

<두번째 상황>

문헌적 침해에 대해 "NO"이고, 균등론에 대해서도 "NO"이며, 그리고 출원기록 금반언의 원칙에 대해서는 "N/A"이면 6번란의 직접침해에는 "NO"라고 기재한다. 이 두 번째 상황은 Graver Tank 사건에서는 볼 수 없다.

<세번째 상황>

문헌적 침해에 대해 "NO"이고, 균등론에 대해 "YES"이며, 출원기록 금반언의 원칙에 대해서도 "NO"라면, 6번란의 직접침해에는 "YES"라고 기재한다. Graver Tank에서는 이 세 번째 상황으로 마그네슘 실리케이트에 대한 직접침해가 있다. 그러므로 6번란의 직접침해의 3번째 열에 "YES"라고 기재한다.

<네번째 상황>

문헌적 침해에 대해 "NO"이고, 균등론에 대해서는 "YES"이며, 출원기록 금반언의 원칙에 대해서도 "YES"라고 하면, 6번란의 직접침해에는 "NO"라고 적는다. 그러나 이 네 번째 상황도 Graver Tank 판결에서는 볼 수 없다.

㉞ <표1>의 판정을 해석하는 방법

요약하면, 직접침해(6번란)에 있는 모든 각각의 화합물에 대해 "YES"라는 대답을 갓으면 원고(특허권자)는 소송에서 이길 수 있는 가장 유리한 상황을 갓으며 이는 Graver Tank 판결에서 볼 수 있다. 피고(추정된 침해자)는 직접침해(6번란)에서 어떤 화합물이 "NO"라는 대답을 갓을 때마다 소송에서 이길 수 있는 더 유리한 상황을 갓는다.

(2) 미국 특허법 해석상의 출원기록 금반언의 원칙 (File Wrapper Estoppel)

① 서 (Introduction)

원고가 균등론을 적용할 수 없다면 직접침해는 없다. 그러나 원고가 균등론을 성공적으로 적용할 수 있다면 출원기록 금반언의 원칙을 검토한다.

"출원기록(File Wrapper)"이란 특허 심사절차 중에 특허청에 제출된 서류 등, 예를 들면 보정서 등을 말한다. "금반언(Estoppel)"이란 특허권자가 특허 심사절차 중에 특허청에 대해 보정 혹은 의견에 의해 이미 포기한 어떤 청구항의 범위를 소송에서 되찾으려는 것은 금지된다는 것을 의미한다.

② 금반언의 원칙의 사법적인 적용 (Judicial Application of File Wrapper Estoppel)

출원기록 금반언의 원칙을 확립하기 위한 요건에 대해서 세 가지 견해가 법정들에 의해 발전되어 왔다.

<첫번째 견해> : 특허 심사절차 중에 인용된 종래 기술 참증에 기초한 거절을 피하기 위하여 청구범위를 좁히려는 실질적인 보정이 있어야 한다. 종래 기술을 피하기 위한 이 실질적인 보정이 출원기록 금반언의 원칙을 확립하기 위하여 요구된다.

<두번째 견해> : 좁히려는 보정에 대한 이유는 아무런 관련성이 없다. 그러므로 좁히려는 보정은 인용된 종래 기술 참증에 기초한 실제거절을 피하기 위하여 혹은 형식에 관한 문제에 기초한 방식거절을 극복하기 위해서 일어날 수 있다. 이 관점에서는 둘 중의 한 형태의 보정이 출원기록 금반언의 원칙을 확립하기 위해 요구된다.

<세번째 견해> : 특허 심사절차 중에 출원인은 청구항의 범위를 좁히려 하는 진술을 하거나 의

견을 낼 수 있다. 이것은 실제로 보정된 청구항이 없이도 출원기록 금반언의 원칙을 확립할 수 있다는 것을 의미한다.

과거에는 이해관계인이 출원기록 금반언의 원칙에 대해 가장 유리한 견해를 갖는 법정에 민사소송을 제기하였다. 결국 연방항소재판소는 그 견해 중의 하나 혹은 그 이상을 채택할 것이고, 법정은 그 견해들을 똑같이 따를 것이다.

③ Exhibit Supply 판결(Exhibit Supply Decision)

출원기록 금반언의 원칙의 첫 번째 견해는 Exhibit Supply Co., v. Ace Patent Co.의 판결로 설명될 수 있다. 특허가 특허청에 계속 중이었을 때, 최초의 청구항은 핀볼 게임에서 도전(導電)수단(conductor means)이 테이블에 의해 "지지되어(carried by)"진다고 기재되어 있었다. 종래 기술 참증을 피하기 위하여 최초 출원은 심사절차 중에 도전수단은 테이블에 "매설되어(embedded in)" 진다고 보정되었다. 더 좁아진 이 청구항이 특허로 발행되었다.

Exhibit Supply 판결에서 피고의 장치는 테이블 위에 "설치되는(resting on)" 도전수단을 가졌다. "Resting on"이란 특징은 최초의 넓은 청구항에서의 "carried by"에 의한 제한의 범위 내에 포함된다. 그러나 "resting on"이란 특징은 발행된 특허된 더 좁아진 청구항에 있는 "embedded in"을 문헌적으로 침해하지 않았다. 분명히 "embedded in"과 "resting on"은 균등론에 의해 균등한 것으로 검토되었다. 그러나 대법원은 특허권자는 그가 특허 심사절차 중에 출원인으로써 보정에 의해 포기하였던 청구항을 다시 찾을 수 없다고 명시하였다. 게다가 대법원은 "그가 그 두 문구 사이의 차이를 인정하고 강조한 그리고 그 차이에 포함된 모든 것을 포기한다고 공표한 보정서"를 인용하여 명시하였다. 따라서 대법원은 출원기록 금반언의 원칙을 적용하였다. 이 상황에서 특허의 직접침해는 없었다.

문헌적 침해, 균등론, 그리고 출원기록 금반언의 원칙에 대한 Exhibit Supply 논의는 <표2>에 나타나 있다. <표2>는 Graver Tank의 <표1>과 같은 항목을 갖는다. 다만, 맨 위의 1번란에 "최초의 청구항"이라는 여분의 항목을 두어 출원기록 금반언의 원칙을 검토하도록 한 것이 다르다.

<표2>

1. 최초의 청구항	Carried by (지지되어)
2. 발행된 특허	Embedded in (매설되어)
3. 피고 항목	Resting on (설치하여)
4. 문헌적 침해	NO
5. 균등론	YES
6. 출원기록 금반언의 원칙	YES
7. 직접침해	NO

<표2>를 보면 "최초의 청구항"이란 항목에 "carried by"가 기재되어 있고, "발행된 청구항"에는 "embedded in", "피고 항목"에는 "resting on"이 각각 기재되어 있다. "문헌적 침해"에는 "NO", "균등론"에는 "YES", "출원기록 금반언의 원칙"에는 "YES"라고 각각 기재되어 있다. 그러므로 직접침해에는 "NO"라고 기재한다.

출원기록 금반언의 원칙의 두 번째와 세 번째 견해도 적용할 수 있다면 Exhibit Supply 판결에서 설명된 첫 번째 견해와 유사한 법적 결과를 갖는다. <표2>에 사용된 항목은 두 번째 견해에 대해서도 적절하다.

그러나 세 번째 견해에 있어서는 "최초의 청구항"이라는 항목은 "의견(Remarks)"이라는 항목으로 대체될 수 있다. 의견이란 항목에는 청구항의 범위를 좁히려고 의도한 진술이나 의견이 기재될 것이다.

제 5 장. 청구항 작성시 유의사항

제 1 절. 신규성과 진보성

(1) 신규성

특허법상 ‘새롭다’고 하는 것은 상식적인 의미에서의 ‘새로움’과는 다르다. 특허법에서 말하는 ‘신규성’은 각국의 산업 정책에 의해 정해져 있어서 상대적인 것이다. 주의해야 하는 것은 누구에게 있어서 새로운가, 또한 어느 장소에서 새로운가라고 하는 것이다.

특허법은 신규성을 다음의 세가지 사항으로 나누어 규정하고 있다. 즉, 발명이 다음과 같은 것일 때 신규성이 없다고 하고 있다.(§29)

- ㉠ 특허출원 전에 국내에서 공공연히 알려진 것
- ㉡ 특허출원 전에 국내에서 공공연히 실시된 것
- ㉢ 특허출원 전에 국내 또는 외국에서 반포(頒布)된 간행물에 기재된 것

이것들은 각각 공지(公知), 공용(公用), 문헌공지로 약칭되기도 한다. 이들 가운데 공지, 공용은 국내에 국한되어 있다. 문헌공지는 외국의 것도 포함된다. 미국도 공지, 공용은 미국 내에 국한되어 있다.

따라서 장소의 상위(相違)에 의해 특허법에서는 공지, 공용으로 인해 신규성이 없는 발명이라도 미국의 특허법에서는 공지, 공용이 되지 않기 때문에 신규성 있는 발명이라 하는 경우도 있다.

미국에서는 선발명주의를 채용하고 있어서 신규성 판단은 출원시뿐만 아니라 발명시점에서도 행하여 매우 복잡하게 되어 있다.

(2) 진보성

특허법 제42조 제3항은 출원명세서에 그 발명의 목적, 구성, 효과를 기재하도록 규정하고 있는데, 이는 발명이 목적, 구성, 효과의 3요소에 의하여 표현되는 것임을 의미하고, 동법 제42조 제4항 및 제5항의 규정에 의하여 발명은 특허청구범위에 기재된 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항, 즉 기술적 사상을 구현하는 구체적인 구성에 의해 목적 및 효과를 파악할 수 있는 것이라고 할 수 있다.

여기서 특허법 제42조 제3항에 대한 대법원 판례를 보면, “특허출원서의 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 한다라고 되어 있는 바, 위 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자에게 공표하여 그 기술적 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기

술능력을 가진 자가 당해 발명을 명세서 자체의 기재에 의하여 출원당시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 그 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 정도로 기재하는 것을 말한다고 할 것이므로, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수만 있다면, 그 효과를 입증하기에 충분한 실험데이터가 기재되어 있지 않다고 하여도 그 명세서의 기재는 적법하다”(94후654판결, 대법원 1995.7.14 선고)

그리고 발명의 목적, 구성, 효과의 3요소에 의하여 표현되는 것에 대한 대법원 판례를 보면, 경금속 피스톤의 팽창제어 삽입체에 관한 본원 발명이 인용발명과 비교해 볼 때, 목적, 기술적 구성, 효과가 서로 다르다는 이유로 진보성을 인정한 사례가 있다(94후1388 판결, 대법원 1996.7.12 선고). “각 발명들은 그 구체적인 목적이 서로 다르며……, 양 발명들은 그 구체적인 구성이 서로 다르고……, 그렇다면 본원발명은 공지된 선행 기술로부터 예측되는 효과 이상의 향상 진보된 작용 효과가 인정될 뿐 아니라, 그 기술적 구성의 차이로 말미암아 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명들로부터 본원발명을 용이하게 도출할 수 없으므로 진보성을 인정……”하고 있다.

또한 기술적 사상을 구현하는 구체적인 구성에 대한 대법원 판례를 보면, “본원발명의 특징은 서미스터의 단선여부를 판별하기 전에 조리기기를 일정시간 동안 예열하는 것이고, 그 예열수단은 도면 제2도에 나타난 종래의 구성에 단순히 삽입할 수 있는 것으로서 이는 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것이므로 구태여 그 구성이나 기능실현수단에 대하여 구체적으로 기재할 필요가 없다(84후54 판결, 대법원 1987.9.29 선고)”라고 하고 있다.

여기서 기능실현수단(means plus function claim)으로 작성된 청구범위나 상세한 설명이 때때로 심사실무상 장벽에 부딪칠 경우가 있다. 기능으로 작성된 장치 발명(이것을 “기능청구범위”라고도 한다)인 경우 그 보호범위를 측정하기가 쉽지 않은 이유에서다.

기능실현수단이란 용어의 어원은 미국의 특허법 제112조에서 유래된다. “조합 청구항에 있어서 구조, 재료 또는 동작을 기재하지 않고, 특정의 기능을 달성하기 위한 수단 또는 공정으로서 요소를 표현할 수 있다.”

이러한 기능실현수단은 출원인 입장에서 보면, 명세서에 기재된 구조 또는 균등물을 포함한다. 물론 이러한 기능실현수단은 단언적으로 청구범위를 넓게 표현하기 쉽다.

특히 택일적인 표현을 피하고 포괄적인 표현을 할 수 있다는 데 그 매력이 있다. 또한 기계나 장치는 구조로 이루어진 기능으로 표현하는 것이 발명의 본질을 표현하기 쉽다는 장점이 있다.

따라서 미국 특허명세서의 작성시 기계나 전지 분야에서는 이러한 기능표현수단이 많이 사용되고 있다. 그러나 출원인의 의도와는 달리 미국 심사관들은 이러한 기능표현수단은 넓은 청구범위를 나타내고 있기에 진보성에 대한 특허검색건수가 다량 나올

수 있다는 데 매력을 느낀다. 결국 기능실현수단으로 작성은 청구범위는 무엇이 균등물에 상당하는지 불명확하게 되는 단점이 있게 된다.

(3) 신규성과 비자명성(진보성)의 거절은 어느 때 하는가?

이에 대하여 미국법원은 다음과 같은 견해를 밝혔다. 즉, 신규성에 의한 거절은 선행기술이 특허출원 발명을 똑같이 묘사하고 있을 때 적합하며, 비자명성에 의한 거절은 선행기술이 특허출원된 발명을 똑같이 묘사하고 있지 않을 때 적합하다고 판단한다.

그러나 구성과 효과의 관련성에서 구성이 발명의 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서 기능(작용)을 수반하는 것이고, 효과는 구성이 목적에 따라 작용함으로써 초래되는 성과이기 때문에 작용은 구성 및 효과와 상호 밀접하게 결부되는 관계에 있으므로, 발명의 비교에 있어서 효과를 고찰할 경우 이들을 별도로 파악해서 별도로 비교하는 것이 아니고, 이들을 일체적인 것으로서 파악하고 대비함으로서 보다 정확한 고찰이 가능하다고 보여지므로 가급적 효과를 일체적인 것으로서 다룬다.

구성은 특허청구범위의 필요요건으로서 기재되어야 하므로 발명의 3요소 중 가장 구체적으로 파악하기 쉽고, 공지발명과 대비에 있어서도 그 구성의 차이는 개인의 견해차가 없이 발견할 수 있는 객관적인 발견을 요하는 것이다.

따라서 진보성의 판단은 주로 구성의 곤란성(결합의 곤란성 등)에 대하여 판단하는 것이 가장 타당하다.

발명3요소	진보성의 초점	세부 척도
목적	기술적 과제의 특이성	발명이 해결하려는 문제점, 산업상의 이용분야의 기재로부터 해당발명이 자연현상 또는 자연법칙에 대하여 새롭게 인식되는 발견이나, 해당발명이 속하는 기술분야에서 선행기술이 가지는 문제점에 대한 미지의 원인설명 또는 이용분야간의 격차 등을 고려함
구성	채택 결합의 곤란성	기술을 풍부하게 하고, 기술진보의 근원이 되는 것이면서, 발명의 중핵으로 발명의 주된 창작력은 구성의 채택결합에 경주되고 있기 때문에 판단의 중심이 됨
효과	기술적 효과의 현저성	산업의 발달에 기여하는 실체라고도 할 수 있으므로 판단의 중요한 수단

목적과 효과의 관계를 보면, 효과는 목적의 달성을 위한 척도라 할 수 있고, 또한 명세서에 기재된 목적과 효과는 발명의 주관적 요소에 따르는 것이기 때문에 그 판별이 어렵다.

따라서 목적과 효과에 대한 판단에 있어서는 객관적으로 파악해서 공지발명과 대비할 필요가 있다. 여기서 대법원의 진보성에 관한 판결에 따르면, 특허는 탁월한 또는 현저한 상승적 효과나 각별한 상승적 효과를, 실용신안은 새로운 상승적 효과를 진보성의 효과 비교시 자주 관찰된다.

미국 특허청은 효과면에서 새롭거나 색다른 기능, 상승효과 등의 용어를 확인하기 위해서는 Graham 판결의 3가지 내용을 적용할 것을 M.P.E.P.(Manual of

Patent Examining Procedure)에서 규정한다. 3가지 내용이란 다음을 뜻한다.

◇ 선행 기술의 내용

◇ 선행 기술과 출원인의 청구범위와의 차이점

◇ 해당 기술분야의 당업자(보편적) 기술 수준

발명의 자명성이 심사관에 의해 통지서로서 증명이 된 후, 이를 부정하는 다른 증거가 제출되지 않으면, 그 발명은 자명한 것으로 인정되므로, 결국 자명성이 입증되면, 출원인에게 반증 내지 반박할 수 있는 입증책임의 전환이 발생하게 된다.

여기서 심사관이 진보성을 판단할 때 가끔 언급하는 주지관용기술이란 현저할 것을 요구한다. ‘현저하다’함은 인용참증에 대하여 유무를 가릴 필요가 없을 정도로 객관적으로 보장되어 있는 기술을 뜻한다.

물론 민사소송법 제261조에서 주장하는 현저한 사실과 유사한 점이 발견된다. 현저한 사실이란 “증거에 의하여 그 존부를 인정할 필요도 없을 정도로 객관성이 보장되어 있는 사실”을 말하며, 현저한 사실은 공지의 사실과 법원에 현저한 사실이 있다. 또한 현저한 사실은 증명을 요하지 않는다.

민사소송에서의 현저한 사실은 주장이 필요한가, 필요 없는가, 즉 주장필요설과 주장불요설로 나누어진다. 현저한 사실은 당사자도 알고 있는 것으로 전제되고 있으므로 의외의 재판을 방지하기 위하여 주장을 요한다는 논거는 설득력이 약하다. 결국 현저한 사실은 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 고려할 수 있다고 본다.

공지의 사실은 일반인에게 널리 알려져 있는 사실을 뜻하며, 불요증 사실로 한 것은 불특정 다수인이 진실이라고 믿고 있으므로, 필요가 있으면 언제든지 그 진부를 조사할 수 있는 보장이 있기 때문이다. 공지의 사실은 어떠한 경위로 일반인에게 널리 알려졌는가는 문제가 되지 않는다.

어느 정도로 알려졌을 때 공지라고 할 수 있는가는 그 존재가 확실히 보장되고 일반인들이 널리 믿어 의심하지 않을 정도에 이르렀는가를 기준으로 한다.

따라서 공지의 여부는 때와 장소에 따라 다르다. 공지라고 인정하기에 이른 경로는 보통 사람이 납득할 수 있어야 하므로 그렇지 아니한 경우에는 그 한도 내에서 상고심의 심사를 받아야 할 것이다. 그러나 공지의 사실에 대하여는 그것이 공지라는 점에 대한 반증 및 그 공지사실이 진실이 아니라는 증명이 허용된다.

법원에 현저한 사실은 그 직무활동을 통하여 명백히 알고 있는 사실이다. 직무상 현저한 사실이라고도 한다. 따라서 직무활동을 통해 알고 있는 사실이므로 법관의 개인적 지식은 이에 해당되지 않는다. 법원에 현저한 사실을 불요증 사실로 한 것은 언제든지 기록을 조사하면 그 사실의 진부를 조사할 수 있기 때문이다.

여기서 증명은 요증 사실의 존재에 관하여 법관에게 확신을 심어준 상태 또는 그러한 확신을 얻게 하기 위하여 증거를 제출하는 당사자의 노력(증거제출행위)을 말한다.

확신이란 어느 사실의 존재에 관하여 합리적 의심을 가지지 않을 정도의 심증을 말한다. 여기서의 증명은, 절대성을 불가결로 하는 자연과학사의 논리적 증명과 진실에

대한 고도의 개연성을 뜻하는 이른바 역사적인 증명으로 나뉘어 판단한다.

따라서 해당 발명에 대한 진보성 유무를 판단할 때는 우선 공지발명과 목적, 구성, 효과를 종합적으로 대비 검토하여 그 구성의 차이를 발견하고, 그 구성의 차이 부분에 대한 곤란성의 정도에 따라서 다음의 표와 같이 판단한다.

진보성의 3경우 판단	판단결과	주요 사례
*구성 -곤란성 *목적,효과-각별하지 않음	진보성 있음	1. 구성이 신규의 기능을 가지는 경우 2. 기능이 완전히 상이한 경우 3. 기술수단이 완전히 상이한 경우
*목적,효과-특이, 현저함 *구성 -채택 결합	진보성 있음	1. 신규한 작용 효과가 현저한 경우 2. 목적과 특이성에 따라 작용 효과가 현저한 경우 3. 새로운 발견에 따라 작용 효과가 현저한 경우 4. 질적으로신규한 작용효과가 예측불가하였다고 인정... 5. 유효한 양적 효과의 증대가 예측불가하였다고 인정... 6. 상당히 거리가 먼 용도에 사용되어서 당업자가 예측불가하였다고 인정되는 경우
*목적,효과-특이,현저않함 *구성 -채택 결합	진보성 없음	1. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 종합에 상당한 경우 2. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 전용에 상당한 경우 3. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 치환에 상당한 경우 4. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 용도 변경에 상당... 5. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 배열 변경에 상당... 6. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 형상 변경에 상당... 7. 용이하게 할 수 있는 공지기술의 수치 한정에 상당...

이러한 도표에서 진보성이 없는 발명은 어떠한 결과를 초래하는가? 특허출원한 발명이 진보성이 없는 경우는 특허법 제62조(거절이유), 특허법 제70조(이의신청이유), 특허법 제133조 제1항(무효사유)에 의해, 이러한 발명이 산업발전을 저해하지 못하도록 조치한다.

(4) 퇴보발명과 성공 예의 진보성

진보성에 관해서는 실무선에서 부딪칠 수 있는 문제를 보자. 즉, 여러 가지 관점에서 진보성을 판단해도 결정하기 힘든 경우에는 특허해야할 것인가의 여부, 이른바 의심스러운 경우의 이익은 특허출원인에게 부여할 것인가의 여부이다. 이는 특허발명의 질적 저하(퇴보발명)를 방지하여 특허발명이 독점권에 걸맞는다는 평가를 받는 것이 진보성 규정의 취지에 합치하는 것이므로, 특허발명과 출원시의 기술수준 사이에 명백한 선을 긋는 것이 필요하기에 거절하는 것이 타당하다.

어떠한 발명이 실패로 돌아갔고, 이후 성공 예의 진보성의 거절로 사용할 수 있는가? 일반적으로 진보성의 근거로 해서는 안 된다. 즉, 발명이라고 인정할 수 없는 사항일지라도 자연법칙 또는 어떤 유의 미완성발명처럼 그 자신이 직접발명의 기초가 될 수 있는 사항, 또는 그 기초가 될 개연성이 극히 높은 사항, 진보성 부정의 근거로 하는 것은 타당하나 실패 예처럼 그 자신이 직접발명의 기초가 될 수 없는 것 또

는 그 기초가 될 개연성이 극히 낮은 것을 근거로 하는 것은 타당하지 않다.

여기서 미완성 발명의 경우에, 미완성 발명이라고 하더라도 진보성 판단의 대비 자료가 될 수 없는 것은 아니므로, 미완성 발명에 대한 거절사정이 확정되었다고 할지라도 이와 대비하여 본원발명의 진보성을 부인할 수도 있는 사례가 있다(95후1302 판결, 대법원 1996.10.29 선고).

그리고 실패 예의 원인 및 이것을 성공으로 이끌기 위한 수단이 당업자에게 쉽게 예측되는 경우는 실패 예를 가지고 성공 예의 진보성의 근거로 하는 것은 타당하다.

기재가 잘못되어 있고, 이 잘못에 대한 기재를 당업자의 입장에서 알 수 없는 오기인 경우, 또는 당업자의 상식에서 사실에 반하는 기재임이 분명한 경우 이 같은 기재를 가지고, 공지사실이라 하여 진보성 부정의 근거로는 할 수 없다. 불충분한 기재불비를 신규성 부정의 근거로 하지 못함은 물론, 진보성 부정의 근거로 하는 것은 타당성이 없다고 인정되기 때문이다.

(5) 일본의 진보성과 미국의 비자명성(non-obviousness) 비교

우리 나라의 특허법은 일본의 특허법과 매우 유사하기 때문에, 일본의 사례를 검토하면 우리 나라의 진보성과 미국의 비자명성을 유사 비교할 수도 있다.

다음은 일본과 미국의 판례에 나타난 진보성과 비자명성의 유사점이다.

㉠ 넓은 선행기술 범위 내에 좁은 범위를 선택해서 달성할 수 있는 예상치 못한 결과를 포함하여 예기치 못한 결과

㉡ 상업적인 성공

덧붙여 미국실무에서 공통적으로 나타나는 형태인 오랫동안 갈구해온 필요 욕구, 주지의 문제를 해결하는 데 대한 타인의 실패, 비자명성한 문제에 대한 자명한 해답, 여타 다른 명령 또는 지시에도 능숙한 이동, 전문가에 의한 발명 내용에 대한 불신 또는 성공의 회의감, 선행기술보다 앞선 발명의 복제 등은 법관이 진보성의 판단시 참고하는 하나의 방편이 된다.

일본과 미국의 제도에서 상당수의 유사성이 발견됨에도 불구하고 차이점은 어디에서 나타나는가?

미국의 출원인은 미국 심사관이 비자명성에 관한 명백한 증거를 찾을 때까지 비자명성의 객관적인 증거를 표시하지 않는다. 이것을 미국의 출원인들은 반박(보정)하기 위한 합리적이며 명확한 의견서로 작성한다.

이와는 대조적으로, 일본의 출원인은 일본 심사관이 거절이유를 통지할 것으로 알고 가능한 의견서를 예견하여야 한다. 발명의 효과를 확인시키기 위해서 사전에 효과면을 충분히 검토해 두고, 보정서를 꾸밀 때 출원서의 일부에 이를 강조한다. 그 만큼 효과에 대한 비중을 더 두어야 한다는 의미이다.

또 하나의 차이는 비자명성의 주요부가 일치하는 객관적인 증거에 있다. 일본의 출원서에서 효과는 특허성의 주요 요건이며, 상당히 중요하므로 일본 특허법 제36조

제3항에 의해 반드시 요구되어진다. 심사 진행 중에 이를 확인하기 위해 효과를 명세서 내에 현시하도록 명세서를 보정할 것이 요구되기도 한다. 이와는 대조적으로 미국의 출원서는 미국 심사관이 비자명성의 명백한 증거를 찾게된 때만 비자명성의 객관적인 증거를 나타내면 된다.

일본의 심사기준은 발명의 목적을 달성함으로써 발생하는 효과를 현시하도록 명확하게 요구한다. 이 효과는 선행기술보다 뛰어난 최소한의 새로운 상승효과를 가져야 한다. 그리고 발명의 목적에 따른 효과가 일치하지 않는다면, 일본 심사관은 일본 특허법 제36조 제4항(특유의 효과)에 의해 거절할 수 있다. 더 나아가, 발명의 요지에 따른 효과의 관계가 중요한 것은 일본 특허의 유효성에 중대하게 고려되기 때문이다.

효과에 대한 증거는 일본의 명세서 내의 일부로서 제출될 수 있고, 이는 소송대리인이 훗날에 특허성의 지지를 받는 데 이용되기도 하며, 미국의 출원서에 의해 지지받는 그 이상의 역할을 한다. 미국의 실무에서 37C.F.R 제1.132조에 따라 제출된 선언서와 같은 맥락으로 일본 출원서의 심사 진행 중에도 데이터가 제출될 수 있다.

일반적으로 공무원의 검정(test)으로부터 발생하는 증거는 가장 중요한 비중을 차지하고, 제3자에 의한 검정은 비중이 전자보다 덜 하고, 출원인에 의한 검정은 가장 비중이 낮다. 양국간 비자명성과 관련한 처리를 한 가지 더 들면, 일본 출원서 내 장치 발명에 따라 진보성을 발견하는 것은 장치의 이용과 제조의 방법에 대한 진보성을 발견하는 것도 포함된다.(일본 심사기준 제2장)

전형적인 미국 실무상 미국 심사관은 In re Durden("비자명한 초기의 발명의 이용이 반드시 다른 비자명한 방법을 반드시 부여하는 것은 아니다")에 따라서 전기의 의견서를 거절한다. 미국 의회에서는 최소한 비자명성이 있는 조성물이라든지 비자명성이 있지 아니한 조성물의 이용과 제조의 방법의 경우에 대해서 추정을 할 수 있도록 한 법안을 고려하고 있다.

2) 청구항의 도입부

(1) 청구항의 작성 주체?

미국 출원시 각각의 청구항은 "I(or We) claim:", "What is claimed is:" 또는 이와 등가의 문구로 시작되어 마침표(".")로 끝나는 단일 문장이다. 이는 첫 번째 청구항이 등장하기 전에 기재되는 것으로 반복되지 않는다.

그리고 "What is claimed is"를 쓰는 것이 "I" 또는 "We"와 같은 대명사를 쓰는 것 보다 낫다. 왜냐하면 출원진행 중에 한 명의 발명자가 복수로 바뀌거나 그 반대의 경우가 발생할 수 있기 때문이다. 즉, "We" 또는 "I"를 청구항에 사용하면 발명자의 수가 바뀔 때 청구항을 수정해야할 필요가 생기기 때문이다.

영어 논문 작성시 저자의 경험이나 사고방식 등을 기술하는 데 주어로 we(저자가

혼자인 경우라면 I)를 사용하는 것이 경원시 되기 쉬운 것은 동사의 수동태(예를 들어, An experiment *was conducted* on... It *is considered* that...)로 하는 것이 보다 논문다운 문체라고 여겨지는 점에서 유래되고 있다. 그러나 명세서의 본문에서는, 부자연스러운 구문으로 하면서까지 무리하게 we를 피할 필요는 없다.

(2) 청구항의 구성요소는 복수개인가?

드문 경우에 발명은 단일 요소로 구성될 수 있다. 이러한 경우, 청구항의 특징부(body)는 단일 요소로 기술될 수 있다. 예를 들면 다음과 같다.

1. A process for treating the surface of a polyethylene article to increase its receptivity to printing ink, the process comprising the step of:

exposing the surface of the article to a saturated solution of sodium dichromate and concentrated sulfuric acid.

1. 인쇄잉크의 수용성을 증가시키기 위해 폴리에틸렌 물품의 표면을 처리하기 위한 방법에 있어서, 상기 처리 방법은, 중크롬산 나트륨과 농축된 황산의 포화용액으로 물품의 표면을 노출시키는 것을 특징으로 하는 처리방법.

(3) 도입부(또는 전제부)의 해석

흔히 청구항 부분은 선행기술을 이루는 요소 또는 공정에 관하여 일반적으로 요약해서 언급한 후 해당 발명의 요소 또는 공정을 구체적으로 명시하게 된다. 이 일반적인 표현이 전제부(Preamble)이고 구체적으로 요소 또는 공정을 열거한 부분이 본문이다.

① 미국 특허출원에서 모든 청구항은 전제부(Preamble)를 갖는다.

전제부는 모든 청구항의 특징부(body)에 우선하는 간략한 소개이다. 독립항의 전제부는 ① 발명의 범주를 개괄하고, ② 본 발명과 종래기술간의 관계를 확인해주며, ③ 본 발명이 외부 물건 상에서 어떻게 동작하는 지를 기술하고, ④ 본 발명의 목적을 정의한다. 종속항의 전제부는 독립항의 전제부와 구별되는 것으로, 단지 인용하는 독립항을 언급하기 위해서만 통상 사용된다.

전제부에 의해 발명의 범주가 구별될 수 있다(반드시 전제부에 의해 구별되어지는 것은 아님). 즉, 물, 방법, 장치 등의 구별이 그것이다.(미국의 경우는 process, machine, article of manufacture, or composition of matter) 예를 들어 전제부는 "a machine for making felt(펠트를 형성하는 장치)" 또는 "a method for

making felt(펠트를 형성하는 방법)"와 같이 기술할 수 있다. "apparatus", "device" 또는 "circuit"와 같은 단어는 기계류(machine)의 대체가능한 표현들로 사용될 수 있다. 법령에 의거한 범주(class or category)는 발명의 통상적이고 일반적인 이름으로부터 유도될 수 있다. 예를 들어, "a binary computer for calculating ...(...계산을 위한 이진컴퓨터)", "a self-propelled lawn sprinkler(자체추진의 잔디 살수기)", "a carburetor(기화기)"와 같은 것은 기계류(machine)의 청구항이고, "a fertilizer composition(비료 합성)"은 조성물(또는 결합체)(composition of matter) 청구항의 예이다.

전제부는 "A process", "An apparatus" 또는 "A composition"과 같은 넓은 범위의 전제부를 사용할 수 있다. 전제부는 통상적으로 발명이 의도하는 기능을 포함한다. 이 기능은 직접적으로 또는 간접적으로 규정될 수 있다. 직접적인 예는 "A process for purifying water(물을 정화하는 방법)", "A device for generating synchronous signal(동기신호를 생성하는 장치)", 또는 "A composition for promoting the conversion of water to hydrogen(물의 수소로의 변환을 촉진시키는 조성)"과 같은 것이고, 간접적인 예는 기능적인 명사를 사용하는 것으로 "A distillation(증류기)", "A hand hammer(손 망치)", 또는 "A catalyst(촉매제)"와 같은 것이 있다.

미국 출원에서 전제부의 예는 다음과 같다:

- ◎ A composition... (...조성물)
- ◎ A composition for fertilizing soil... (...토질을 비옥하게 하는 조성물)
- ◎ Apparatus (기구 또는 장치)
- ◎ Apparatus for transferring fertilizer from a first conveyor belt to a second conveyor belt parallel to the first belt but in an opposite direction... (...제1 컨베이어 벨트에서 제2 컨베이어 벨트로 상기 제1 벨트와 평행하면서 반대 방향으로 비료를 이동시키는 장치)
- ◎ A device for fertilizing soil... (...토질을 비옥하게 하는 장치)
- ◎ A method... (...방법)
- ◎ A method for fertilizing soil... (...토질을 비옥하게 하는 방법)
- ◎ A circuit for detecting discontinuities in the insulation of an insulated wire... (...절연전선의 절연체에서 불연속성을 검출하기 위한 회로)

출원된 발명이 범주가 다른 청구항을 포함하고 있을 때, 다른 범주 청구항의 전제부는 당연히 달라야 한다. 출원된 발명이 동일 범주의 다른 독립항을 갖고 있을 때, 다른 전제부를 사용하는 것이 때때로 유익하다. 예를 들면, "A heater(가열기)", "A composite heater(혼합 가열기)", "A heating assembly(가열 조립품)"와 같다.

전제부가 하나의 명사(예를 들면, "method(방법)" 또는 "device(장치)") 또는 여

러 개의 명사로 이루어져 있을 때, 전제부의 마지막에 첫 번째 명사를 반복하는 것이 종종 유용하게 사용된다. 예를 들면, “Apparatus for shaking articles to dislodge impurities comprising...(불순물을 제거하기 위해 흔들는 장치에 있어서)”에서 예문의 “comprising”이 “apparatus”를 언급하는 지 또는 “impurities”를 언급하는 지 불명확하다. 따라서 “Apparatus for shaking articles to dislodge impurities, the apparatus comprising...(불순물을 제거하기 위해 흔들는 장치에 있어서, 상기 장치는...)”으로 기술하면 “comprising”이 “apparatus”를 지칭함을 명확히 할 수 있다. 비록 반복하는 것은 불필요하지만, 매우 복잡한 전제부에 의해 모호해지는 것 보다는 낫다.

종속항의 전제부는 인용한 독립항의 전제부를 내용상 전제하는 것으로 보기 때문에 간단하게 작성할 수 있다.

우리 나라의 경우에 청구항은 “전제부(또는 도입부), 특징부, 연결부, 종결부”로 이루어지는 것이 통상적이다. 미국은 “preamble(전제부), transition(이행구), body(본문 또는 특징부)”로 구성된다. 미국의 전제부 내용은 우리 나라의 전제부 또는 종결부에 기재된다. 따라서 우리 나라의 전제부가 명칭을 그대로 전제하고 있을 경우, 종결부에도 명칭이 기재되기 때문에 전제부를 기재하지 않을 수도 있다고 본다. 즉, 우리 나라의 청구항이 “특징부, 연결부, 종결부”로 이루어져도 이를 미국 명세서로 번역할 시 미국 청구항의 전제부는 우리 나라의 종결부에 의해 발명의 명칭을 기재할 수 있기 때문이다. 그러나 발명의 범위를 확정하거나 청구범위의 모호함을 제거하고자 할 경우에는 우리 나라의 청구항에도 전제부를 기재하고, 이 때는 발명의 명칭만을 전제하거나 또는 발명이 속하는 범위 또는 기능을 추가하여, 발명이 속하는 범위를 기능적으로 특정하는 것이 필요하다.

② 전제부가 청구항의 범위를 제한하는가?

규칙1 : 만약 청구항 전제부의 제한사항이 청구범위를 제한하는 경향이 있다면, 이 제한사항은 청구항의 본문(body)에서 반복되어야 한다.

규칙2 : 만약 전제부의 제한사항이 청구범위를 제한하는 경향을 갖지 않는다면, 이 제한사항은 전제부에서 삭제되어야 한다.

명세서 작성자가 청구범위를 제한하고자 하지 않는다면, 전제부가 청구범위를 제한하지 않도록 충분히 넓게 전제부를 작성하는 것이 필요하다. 전제부에 작성된 제한사항이 청구범위를 실질적으로 제한하는가 그렇지 않는가 하는 문제는 특히 소송이나 권리범위 확인심판 등의 심판 과정에서 등장하는 문제이다. 아래의 예와 같이, 전제부에 작성된 “optical wave guide(광파 지시기)”란 말은 종래기술인 도포된 실리카 코어(doped silica core) 및 실리카 외장(sheath of silica)에 의해 기술된 청구항이 아니고, 따라서 “optical wave guide”에 의한 제한을 받지 않는다.(Corning

1. An optical wave guide comprising:

(a) A cladding layer formed of a material selected from the group consisting of pure fused silica and fused silica to which a dopant material on at least an elemental basis has been added, and

(b) a core formed of fused silica to which a dopant material...

1. 광파 지시기에 있어서,

(a) 순수한 플즈를 단 실리카로 구성된 그룹으로부터 선택된 물질로 형성되고, 상기 실리카는 기본 계층이 추가된 도핑물로 플즈를 단 것을 특징으로 하는 클래딩 계층과;

(b) ... 도핑물로 플즈를 단 실리카로 형성된 코어로 구성된 것을 특징으로 하는 광파 지시기.

법원은 명세서 전체에 의해 특허를 판단할 때 “optical wave guide”란 말은 단순히 코아/클래딩 조합이 아닌 선택된 코아 및 클래딩의 조합으로 청구항을 제한한다고 판시했다. 이와 유사하게 “Apparatus for shaking articles to dislodge impurities(불순물을 제거하기 위해 흔드는 장치)”는 열을 분산하거나 혼합물을 효과적으로 섞는 등의 다른 목적을 위한 흔드는 물품에 대한 모든 발명을 제외한다는 것을 의미한다.

그러나 만약 전제부가 단지 목적이나 발명의 용도만을 언급한다면, 전제부는 청구범위를 제한하지 않고 발명은 청구항의 나머지 부분에 의해서만 정의된다.(Marston v. J.C. Penney Co., 1966) Marston v. J.C. Penney 사건에서, 발명은 공기를 일정한 간격으로 담은 포켓 형태로 봉인된 플라스틱 배관으로 만들어진 쿠션, 매트리스 및 삶에 필요한 기구에 사용되는 방수되고 유연한 구조로 구성된다. 이것의 전제부는 “a buoyant, flexible filler pad comprising a plurality of strip portions arranged in naturally disposed relation...(자연스럽게 배치된 관계에 따라 배열된 복수개의 가는 부분으로 구성된 탄력있고 유연하게 채울 수 있는 패드)”이다. 혐의 받은 피고의 침해 물품은 유사한 플라스틱 튜브 구조로부터 제작된 가죽끈 표면으로 이루어진 긴의자였다. 법원은 전제부가 단순히 사용분야를 언급하고 있고 청구항의 나머지 부분에서 발명이 완전하게 정의되었기 때문에, 이 전제부가 탄력구조에 대한 청구항을 제한하지 않는다는 것을 발견했다.

모호함을 피하기 위하여 작성된 전제부의 어떤 제한사항은 청구항 자체의 본문(body)에 포함된 청구 대상 물질을 제한하고자 하는 의도를 갖는 것으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 섬유 광파 지시기에 대한 청구항을 보자:

3. An optical wave guide comprising:

(a) A cladding layer formed of fused silica to which a dopant material on at least an elemental basis has been added, and

(b) a core formed of fused silica to which a dopant material... such that the combination of the core and cladding acts as an optical wave guide.

3. 광파 지시기에 있어서,

(a) 기본 계층이 추가된 도핑물로 퓨즈를 실리카로 형성된 클래딩 계층과;

(b) 광파 지시기와 같은 코어와 클래딩의 조합과 같이 ... 도핑물로 퓨즈를 단 실리카로 형성된 코어로 구성된 것을 특징으로 하는 광파 지시기.

청구항의 대상 물질을 제한하는 경향을 갖는 전제부에서, 이러한 청구항은 전제부의 제한을 제거할 수 있게 되는 것이다.

이에 따라, 만약 전제부의 제한사항이 청구범위를 제한하지 않는 경향을 갖게 되면, 제한은 삭제되어야 한다. 만약 명확함을 위해 전제부의 “(nonlimiting)비제한”적인 용어를 반드시 인용할 필요가 있다면, 이때는 “suitable for(...에 적용되는)”와 같은 용어를 사용할 수 있다. 예를 들면:

1. A structure suitable for use as an optical wave guide, the structure comprising: ...

1. 광파 지시기에 적용되는 기구에 있어서, 상기 기구는, ...

한편, 도입부의 법적 효력에 관해서는 청구항의 효력범위와 관련하여 자주 다투어졌다. 여기서는 미국의 결합체에 관한 청구항과 Jepson 청구항의 경우로 나누어 설명한다.

(3) 결합체(Composition)에 관한 청구항

청구항이 결합체에 관한 것일 때 도입부도 그 발명인 결합체를 한정하는 효력을 갖는 것인가는 도입부가 청구항의 본문과 얼마만큼 긴밀하게 연결되어 있는가에 달린 문제이다. CCPA는 이 문제를 다음과 같이 분석했다.

“이 문제를 검토한 37개의 사건에서 이 법원은 청구항이 구조에 관한 것이고, 청구항의 도입부를 제외한 본문에 의해서만 그 구조를 충분히 설명한 경우에는 도입부의 발명을 한정하는 효력을 부인했다. 청구항이 다른 상품에 관하여 기술하고 도입부는 단지 선행기술이 지녔던 특성만을 언급했을 경우에도 도입부의 한정하는 효력을 부인했다. 그러한 경우에는 청구항의 본문이 발명의 주제를 충분히 설명하고, 도입부는 단지 발명의 목적, 용도에 관해 언급할

뿐이다. 한편 도입부가 명백히 또는 필연적으로 발명을 한정하는 효과를 가진 때에는 도입부가 발명을 정의하는데 있어 불가결한 부분으로 인정된다. 이런 경우 도입부는 청구항에 의미와 효력을 부여한다 할 것이다. 이 경우 도입부는 기존 기술자에게 알려지고 그 해결책이 아직 강구되지 않은 문제를 구체적으로 명시한다. 그 문제의 성격에 따라 청구항 본문에 언급된 요소들의 성격이 규정되고 그 발명을 선행기술로부터 구별할 수 있게 된다.”(Kropa v. Robie, CCPA 1951)

Kropa 사건은 특허출원의 저촉에 관한 사건이었는데 발명의 설명은 “다음의 요소로 구성된 연마제”라는 말로 시작되어 있었다. 문제는 저촉된 두 개의 출원이 모두 이 구절을 뒷받침하고 있는가 하는 것이었다. 법원은 도입부 다음에 기재된 본문이 도입부의 도입없이도 문제의 연마제를 충분히 묘사하고 있다고 보았다. 그래서 도입부는 청구항을 한정하는 효력이 없고 또 출원서에서 명시적으로 해당 발명이 연마제로 사용될 수 있다는 말을 하지 않은 출원도 위의 구절을 뒷받침하고 있는 것이 된다.

같은 법리가 In re Higbee(CCPA 1977)에도 적용되어 전문이 본문과 긴밀한 관계에 있으므로 발명을 한정하는 효력을 갖는다고 판시했다.

Higbee 사건에서 특허출원인은 다른 특허의 일부 청구항을 그대로 사용함으로써 저촉문제가 제기되었다. 출원인은 녹이 슬지 않는 얇은 판을 발명했다고 주장했고, 기존 특허는 이런 판을 사용하여 만든 변압기 상자에 관한 것이었다. 위 출원서에는 변압기 상자에 대해서는 언급이 없었다. 위 특허의 청구항 도입부에서는 재래식 변압기 상자와 그 도전요소 및 액체처리에 대해 언급하고 청구항 본문에서는 그 상자를 만든 재료, 즉 위 출원서에서 주장한 발명품에 대해서 기재했다. 출원인은 기존 특허의 전문이 재래식 변압기 상자에 대해 언급하고, 본문은 그 상자를 만든 재료에 관하여 선행기술과 구별하기 위한 설명을 기록했다고 보았다. 그러나 CCPA는 청구항 본문에서 전문이 있는 요소를 여러 번 인용함으로써 전문에 있는 재래식 변압기에 관한 요소도 발명을 한정하는 것으로 보아야 하며, 따라서 여기서 신규 특허출원의 청구항과 기존 특허의 청구항은 일치하지 않는다.

Waldbaum 사건에서 청구항은 재래식 형태에 따라 전문이 “다음의 공정으로 구성된 것”이라는 말로 끝나고 이어서 청구항 본문이 기재되었다. 그러나 전문이 본문보다 더 길었고 본문에서는 여러 차례 전문을 인용했다. 이런 경우에는 전문도 청구항을 한정하는 것으로 본다. Waldbaum 사건에서 문제는 청구항 본문이 단순히 연산 방식에 관해서 언급했으므로 미국 특허법 제101조에 의거 특허를 거절할 것인가에 있었다. 청구항 전문은 그 연산방식의 구체적 적용에 관해 언급했다. 그러므로 청구항 전문을 원용해서 제101조를 충족시킬 수 있는가가 문제였다. 법원은 전문과 본문이 긴밀히 연관지어져 있으므로 전문도 청구항을 한정하는 기능을 한다고 보았다. 그러나 (지금은 변경된) 그 당시의 법에 의하여 아무리 전문이 한정하는 기능을 한다 하더라도 이 사건에서의 청구항은 특허를 받을 수 있는 사항을 내용으로 한다고 인정

되지 않았다. 목적을 기재한 전문이 청구항을 한정하는 기능을 하는가는 건마다 발명을 전체적으로 보아 결정할 문제이다. In re Stencel, Perkin-Elmer Corp. v. Computervision Corp(1984) 사건에서는 법원이 전문의 청구항을 한정하는 기능을 인정했다. 법원에 의하면 “전문에 있는 한정사항이 청구항 본문에 의미를 부여하고, 발명을 적절히 표현하는데 필요하다”고 했다.

청구항 전문이 청구항을 한정하는 기능을 하는가는 사실문제이므로 지방법원 판사가 이 결정을 할 때 명백한 실수를 하지 않았으면 고등법원은 그 결정을 뒤집을 수 없다.(Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc, 1988)

(4) Jepson 청구항

유효여부 또는 침해여부와 관련하여 Jepson 청구항의 효력 범위를 정할 때 전문도 청구항을 한정하는 것으로 볼 것인가? 이 문제에 대해서 결정적인 해답을 주는 판례는 아직 없다. 위의 Kropa 사건에서 인용한 문단 중 마지막 두 문장은 Jepson 청구항에 대해 말하는 듯하고, 청구항 전문의 한정하는 효력을 인정하는 듯하다. 그러나 Kropa 사건에서는 결합체에 관한 청구항이 문제되었다. 유효여부 또는 침해여부와 관련하여 Jepson 청구항의 효력범위를 정할 때 현재로서는 불확실성이 존재한다고 밖에 말할 수 없다.

이것이 Jepson 청구항이 바람직하지 못하다고 말하는 주요 이유 중의 하나이다. 또 하나의 이유는 Jepson 청구항의 전문은 그 내용이 다른 자료와 합해서 특허권 무효의 원인이 될 수 있는 선행기술임을 시인한다는 것이다. 그 이유는 청구항 작성상의 불확실성에 관한 문제이다. Jepson 청구항 이외의 청구항이 출원서에 포함되어 있는 한 Jepson 청구항이 나중에 특허권자에게 불리하게 해석되어서 생기는 문제가 심각하지 않다고 볼 지 모른다. 그러나 Jepson 청구항의 전문은 그 내용이 선행기술임을 출원인이 자인하는 것으로 보는 해석은 Jepson 청구항뿐만 아니라 출원서에 있는 다른 청구항 모두에 영향을 미친다. 만일 그 전문의 내용이 사실은 선행기술이 아니라면 이러한 해석이 주는 불이익은 적지 않을 것이다. 그러므로 출원서에 잘못 작성된 Jepson 청구항이 있으면 그것이 후에 특허권에 의한 보호를 그르치게 할 가능성이 있다. 이러한 위험은 만일 결합체에 관한 청구항으로 작성했다면 부담하지 않아도 될 것이었다.

원칙적으로 Jepson 청구항의 전문 내용은 선행기술로 추정한다. 그러나 이러한 추정은 극히 예외적인 경우에 뒤집힐 수 있다.

“변호인은 제1 및 제12 청구항이 Jepson 청구항임을 지적하고, 따라서 항소인은 이 청구항 전문에 기재된 결합체가 선행기술임을 인정했다고 주장한다. 우리는 Jepson 청구항의 전문에 기재된 요소가 선행기술로 추정됨을 인정한다.(In re Aldrich, 1968) 그러나 이것은 어디까지나 추정이다. 항소인은 이 출원에서 Jepson 청구항을 기재한 것은 일부를 선행기술로 시인하기

위해서가 아니고, 동시에 계류중인 다른 특허출원과 관련하여 이중특허출원이라는 오해를 받아 거절되는 일이 없도록 하기 위해서였다고 한다. 심사관이 참고한 그 어느 선행기술도 전문에 기재된 결합체와는 달랐다는 사실은 항소인의 이 주장의 신빙성을 높여준다. 이와 같은 선행기술에 관한 오판에 근거를 두고 제103조의 자명성을 인정할 수는 없다. 우리는 여기서 항소인의 청구항 전문 내용을 선행기술로 인정하지 않는다.”(In re Ehrreich, CCPA 1979)

Ehrreich 사건에서 출원인들은 특허가 출원된 발명들을 서로 구별할 수 있게 하기 위해서 Jepson 청구항이 필요했다고 했고, CCPA는 이 주장을 받아들여 이 사건의 Jepson 청구항 전문은 선행기술을 인정하기 위한 것이 아니었다고 판시했다.

Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy, 1984 사건에서 발명자는 자신이 발명하고 그를 위한 특허출원을 한 후 이 발명을 개선하는 내용의 발명에 대해 추가로 특허출원을 했다. 특허법 제102조 (b)항, (c)항 그리고 (d)항을 적용해도 먼저 한 발명이 나중에 한 발명의 선행기술이 되지는 않았다. 나중의 특허출원에서는 나중에 한 발명을 청구항 전문에서 언급하고 청구항은 Jepson 청구항의 형식으로 기재하였다. 특허침해의 혐의를 받은 당사자는 먼저 한 발명이 선행기술임을 나중의 특허출원의 청구항 전문에서 인정했으므로 그에 관한 특허는 무효라고 주장했다.

법원은 출원인이 먼저 발명한 사항을 선행기술로는 볼 수 없다고 판시했다.

“이 사건이 Ehrreich 사건과 유사한 것은 사실이다. 두 사건에서 모두 동시에 두 개의 특허가 출원되어 있었다. 이 사건에서는 출원인이 Ehrreich 사건에서처럼 Jepson 형식의 청구항이 이중특허출원을 이유로 한 거절을 예방하기 위한 것이었다고 말하지 않았다. 그러나 Ehrreich 판례의 정신을 이 사건에 적용하면 자신이 먼저 한 발명이 선행기술로 인정될 수는 없다는 결론에 도달하게 된다. ‘선행기술에 관한 오판에 근거를 두고 제103조의 자명성을 인정할 수는 없다.’ Fout 사건과 Ehrreich 사건에서 지적된 바와 같이 발명자가 자신의 발명을 개선하는 경우와 다른 사람의 발명을 개선하는 것 사이에는 분명히 차이가 있다. 자신의 발명을 개선하는 경우에는 법에 다른 규정이 없는 한 발명자가 그 기초가 되는 발명에 대해 알고 있다고 해서 그것을 선행기술로 인정할 수는 없다. 발명자가 명시적으로 시인하든 안 하든 자신의 발명에 대해 알고 있다는 것은 당연한 것이다.” (748 F.2d 649~50, 223 USPQ 1171~72)

In re Fout, CCPA, 1982 사건에서는 같은 법원칙을 적용하여 Jepson 청구항의 전문이 선행기술을 인정하고 있다는 결론을 내렸다. CCPA는 Jepson 청구항이 Ehrreich에서는 같은 발명자의 특허출원들을 서로 구별하기 위해 이용되었다는 사실에 주목했다. Fout 사건에서 두 개의 특허출원이 동일인에게 양도되었지만 각각 다른 사람에 의해 발명된 것이었다. 발명자가 각기 다르므로 Fout 사건에서는 이중특

허출원으로 인정받아 거절당할 위험이 없다고 법원이 지적했다. 법원은 두 사건의 상황이 현저히 다르고, Fout에서는 청구항 전문은 선행기술을 시인한다는 추정을 뒤집을 만한 증거가 없다고 했다.

그러므로 Jepson 청구항의 이용을 될수록 피하는 것이 좋을 것이다. Jepson 청구항은 청구항의 효력범위가 불분명하고 선행기술을 시인했다는 추정이 있기 때문이다. 원칙적으로 Jepson 청구항을 이용할 때에는 같은 출원서에 결합체 청구항을 전체 범위에 걸쳐 같이 기재하는 것이 필요하다. Jepson 청구항을 출원서에 기재할 때에는 그 전문이 실제로 선행기술이 아닌 것을 선행기술로 시인하는 일이 없도록 각별히 유의해야 한다.

(5) 청구항의 구별

청구항의 효력범위를 정하는데 있어서 다른 청구항을 참고하는 것이 도움이 될 적이 많다. 물론 이것은 똑같은 범위를 위해 두 개의 청구항이 존재할 리 없다는 대전제 때문이다. 그러므로 청구항의 구별은 당연한 것을 행하고 있는 셈이다. 요컨대 같은 특허에 기재된 다른 청구항을 보아가며 어느 청구항의 범위를 논리적으로 정하는 것이다. 예컨대 하나의 독립청구항과 이에 종속된 여러 개의 종속청구항 등 넓고 좁은 청구항들이 함께 있을 때 좁은 청구항 안의 한정사항을 넓은 청구항에도 적용시켜 특허의 무효나 침해를 모면할 수는 없다.

Markey 법원장에 의하면 청구항의 비교에 의한 그 효력범위의 판별은, “항상 변치 않고 어느 경우에도 적용될 수 있는 원칙이다. 이 원칙이 없으면 청구항의 작성, 제출, 심사, 허가와 보호를 지배하는 법규가 무너지고 말 것이다”(DMI, Inc. v. Deere & Co., 1985)

Kalman v. Kimberly-Clarke Corp., 1983에서 피고는 문제된 특허의 명세서에 적혀 있는 한정사항을 청구항에 적용하여 특허의 침해가 없는 것으로 해석하려고 노력했다. 구체적으로 피고는 청구항들이 “변화하는 수압”에 따라 움직이는 여과기가 들어있는 장치에 관해서만 언급한 것이라고 주장했다. 그러나 피고의 노력은 수포로 돌아갔다. 왜냐하면 독립된 청구항에서는 “여과기를 움직이게 하는”이라고만 기재하고, “변화하는 수압에 따라” 움직인다는 말은 종속청구항에서만 언급하고 있기 때문이다.

“KC[피고]는 Kalman이 공개한 내용을 볼 때 여기의 독립된 청구항은 변화하는 수압에 따라 여과기의 띠나 리본이 움직이게 하는 장치에 관한 것으로 해석해야 한다고 주장했다. 그러나 지방법원이 이러한 해석을 받아들이지 않은 것은 적절했다. 왜냐하면 제2 및 제33 종속청구항이 위의 한정사항을 포함하고 있으나 넓고 좁은 청구항이 함께 있을 때 좁은 청구항에 있는 한정사항을 넓은 청구항에 적용해서 특허의 무효나 침해를 모면할 수는 없기 때문이다.”(Deere & Co. v. International Harvester Co., 1981) (비슷한 결론을 내린 Fromson v. Advance Offset Plate, Inc., 1983)도 참조)

청구항 구별론은 청구항을 작성할 때 청구항의 효력범위를 명확히 하는데 도움이 된다. 예컨대 특별한 종류에 속하는 발명을 종속청구항의 형식으로 언급하면 독립청구항의 일반적 성격을 드러낼 수 있다. 여러 종류의 발명이 언급되어야 하지만 종속청구항을 두면 독립청구항이 어느 특정의 발명 또는 어느 특정 부류의 발명에 대해서만 언급한 것으로 해석되는 것을 막을 수 있다.

때때로 청구항에서 사용하는 용어가 일반적 의미와 특별한 의미의 어느 쪽으로도 해석될 수 있는 경우가 있다. 이런 때 특별한 종류의 발명에 관하여 종속청구항을 두면 독립청구항의 용어는 일반적 의미로 해석되어야 한다는 뜻이 된다. 예컨대 두 개의 연결된 부분으로 이루어진 서류집게가 있다고 하자. 이것을 분리된 두 개의 부분을 나사로 연결하여 만들기도 하고, 두 개의 부분을 처음부터 한 덩어리로 만들기도 한다고 하자. 여기서 이러한 제품들을 모두 포함하는 독립청구항을 “첫 번째 부분과 이에 부착된 두 번째 부분”이라는 말을 꼭 넣어서 만들어야 한다고 하자. 이러한 청구항은 원래 분리된 두 부분을 이용해서 만든 제품만을 포함하는 것으로 해석되기 쉽다. 그러나 종속청구항을 두고 거기서 첫 번째 부분과 두 번째 부분이 실제로 분리된 제품이라고 언급하면 독립청구항은 보다 넓은 범위를 포함하는 것으로 해석될 것이다.

이러한 청구항 구별론은 그 적용에 한계가 있다. 예컨대 어떤 기능을 수행하는 구조에 관한 특허가 있다고 하자. 이 특허에는 두 개의 독립청구항이 있는데 하나는 일정한 기능을 수행하는 수단이라고 언급하고 또 하나는 그 기능을 수행하는 구조에 관해 언급했다고 하자. 이 차이점을 제외하면 두 개의 청구항이 똑같다고 하자.

이런 경우에는 청구항 구별론을 적용하여 두 개의 청구항 중 하나의 효과범위를 보다 넓게 해석할 수 없을 것이다. 즉, 첫 번째 청구항은 수단과 기능에 관한 청구항이므로 제112조에 의거 명세서에 명시된 구조 및 그 등가의 것을 포함하는 것으로 해석될 것이고, 두 번째 청구항은 구체적으로 언급된 구조만을 포함하는 것으로 해석될 것이다. 그러나 판례에 의해서 인정된 균등론에 따라 두 번째 청구항은 구체적으로 언급된 구조뿐만 아니라 그 등가물까지로 포함하는 것으로 해석될 것이다. 수단 및 기능에 관한 청구항에서 인정하는 등가물의 범위와 균등론에서 인정하는 등가물의 범위가 별도의 판례가 없는 한 같다고 보아야 하므로 결국 위의 두 청구항의 효력범위는 기본적으로 같다고 해석될 것이다. 만일 또 하나의 청구항이 또 하나의 구조에 대해 언급했다고 하면, 수단 및 기능에 관한 청구항은 두 개의 구조를 모두 포함하는 것으로 해석되겠지만 구조에 대해 언급한 첫 번째 청구항은 그 언급된 구조만을 포함하는 것으로 볼 것이다.

3) 특허침해에서의 청구항 해석

(1) 문언(文言)상 침해

미국 내 문언(또는 문리)상 침해의 여부는 특허청구범위 내 구성요소가 본원발명과 침해품을 비교하여 얼마나 존재하는지 적정한 청구범위의 해석을 통하여 결정하는 것이다.

문언상의 침해 여부를 판단하기 위한 첫 단계는 청구범위를 해석하는 것이다. 여기서 청구범위를 해석한다는 것은 청구범위 내 문언이 본원발명의 보호범위를 나타내기 위해 명백하게 사용된 의미를 파악하는 것이다. 명세서와 청구범위 내 작성된 문언의 사용과 진정한 의미로 파악한다.

이와 같이 사용된 문언의 의미를 출원서 내에서 파악하고, 후에 이것을 청구범위 내 용어의 이용이 어떻게 당업자의 견지에서 사용되어지는 지를 증거들과 함께 상호 비교해 보는 것이다.

예를 들면, 청구범위 내 각 구성요소에서 하나의 구성요소가 유연성이 있으나 다른 구성요소들은 유연성 있다는 적용을 받을 특성의 수단이 아니라면, 특허청구범위 내에 침해품이 유연성을 갖는 것이라고 증명해야 한다.

이러한 문언상 침해에서 명백한 것은 특허사건의 경우 배심원 재판에 앞서서 법원은 변론을 들어야만 하고, 자유 재량으로 필요한 증거를 선택해야만 하며, 당해 청구범위의 의미 및 보호범위에 대하여 결정을 내려야 한다는 것이다.

그리고 문언상의 침해 여부를 결정하기 위한 두 번째 단계는 적절하게 작성된 청구범위들의 각각의 한계를 조사하여 침해품 내에서 찾아보는 것이다. 일반적으로 이와 같은 한계를 찾는 것은 청구범위의 구성요소를 하나씩 침해품의 각 특징과 1:1 대응 방식으로 비교해보는 것이다.

청구범위 내 각 구성요소가 중대하며, 본질적인 증거라면 법원에서 문언상 침해 여부를 결정하기 위해서 특허권자는 침해품 내 각 구성요소가 존재함을 증명해야 한다. 미국 특허법 제112조 제6항에 나온 기능실현수단(means plus function) 형식으로 작성된 구성요소들로 이루어진 청구범위는 침해품과 대응되는 구성요소가 청구범위 내에서는 기능실현수단으로 작성되었을 지라도 명세서 내에서는 등가의 구현된 구조 또는 구성요소로 나타나야 한다.

따라서 기능실현수단으로 작성되어진 청구범위의 효과는 상세한 설명에 의해 뒷받침되어진 구성요소로 대비되는 바, 특정한 구성요소로 작성되어진 청구범위보다 훨씬 좁게 해석된다.

기능실현수단에 대한 하나의 예를 들면, “어떤 장치를 가열시키는 수단(means for heating the article)” 또는 “가열시키는 수단(heating means)”은 특허 명세서 내 공개된 특정한 가열장치(heater)와 대응되므로 가열장치만이 문언상 증거로서 결정이 될 것이다. 그러나 청구범위 내에서 가열기라는 구성요소로 작성되어졌다면, 명세서 내 가열기라고 공개되어졌든 아니든 간에 모든 가열시키는 장치는 포괄적으로 문언상 포함된다.

지방법원에서의 소송 종결 후에 해석된 청구범위가 제소된 구조를 포괄하는지의 여

부에 대한 CAFC(the Court of Appeals of Federal Circuit, 연방순회항소 법원)의 재검토 기준은 복심의 대상이 아니라는 것이다. 즉 합의체에 의한 초심의 판결에 대한 항고에 있어서 CAFC는 적절하게 해석된 청구항이 제소된 구조를 포함하는지 여부에 대한 지방법원의 결정에 대해 명확한 오류가 있었는지 재검토한다. 배심원에 의한 초심 판결에 대한 항고에 있어서, CAFC는 적절하게 해석된 청구범위가 제소된 구조를 포함하는지 여부에 대한 배심원의 판결을 재검토하고 그 배심원의 판결이 실질적으로 증거에 의해 지지되는지의 여부도 결정한다.

여기서 절취하기 위한 천공수단이라는 청구범위 내 하나의 구성요소는 절취기능, 즉 구멍 뚫는 기능을 지지하는 구조를 기재하고 있기 때문에 법정 요건을 만족하지 않는다. 상기의 청구범위는 절취기능을 지지하는 구조뿐만 아니라, 구조의 위치도 나타낸 것이다. 이것의 기능과 상반되는 구조에 대한 법정요건을 만족시킬 수 없다. 청구범위의 작성자가 기계적으로 부가시키는 수단(means)이라는 용어는 이 구성요소의 정확한 구조적인 특징을 나타내는 데 불과하다.

따라서 이러한 청구범위의 작성방법은 이 구성요소를 미국 특허법 제112조 제6항의 기능실현수단(means plus function)의 청구범위와 동일하게 다루지 않는다.(Cole v. Kimberly v. Clark Corp., 1996)

당해 특허 청구범위의 언어가 침해 또는 무효결정과 연관되어 해석된다면, 기능실현수단 청구범위는 명세서의 상세한 설명에 의해 뒷받침되는 구조·물질·작용 및 이러한 것의 균등물을 포괄한다(Fonar Corp. v. General Electric Co., 1995).

그래서 기능실현수단을 통상 알려진 청구범위 작성방법에 대해 문언상 침해여부를 결정할 때, 즉 넓은 청구범위화 시키기 위한 방편으로 알려진 기능실현수단이 명세서 내 공개된 균등물과 동일성을 이루는 특정한 구성요소만으로 제한되어 훨씬 좁은 청구범위를 만들 수도 있게 된다.

(2) 균등론에 대한 침해

침해자는 위의 문언상에 의한 침해 여부에서 빠져나와 침해품이 청구범위 내 문언 이외에서 보여지는 구성요소로 이루어지도록 특허발명의 필수 구성요소를 적당하게 문언 이외로 형성된 물품을 만들 것이다.

균등론의 원칙이란 청구범위 내 문언 이외의 것으로 포장하여 만들어진 침해품에 대해 청구범위 내 해석의 폭을 확장한 개념에 의해 만들어진다는 것이다.

한 장치가 특허청구범위 내 문언상 침해되지 않을 경우, 만일 침해품이 청구된 발명의 본질과 관련성이 있다면 균등론의 원칙 하에 침해로 인정될 수 있다. 즉, 침해의 의심이 가는 한 장치가 주요한 기술적 수단이 아닌 곳만이 다르다고 인정될 경우, 동일한 결과(result)를 달성하기 위해 동일한 방식(way)으로 동작되는 경우 균등론의 원칙으로 침해가 증명될 수 있다.

균등론의 원칙은 형평법상의 개념이다. 역사적으로 미국 법은 관습법(common

law)의 결점을 공정과 정의로 보완하는 영미법에 의한 제정, 즉 형평법(equity)과 법령(common law)에 의한 법원으로 크게 나눌 수 있다. 법령에 의한 법원은 손해 배상을 부여할 수 있고, 형평법에 의한 법원은 금지 처분 따위의 다른 유형으로 배상을 해 줄 수 있다. 이러한 다른 유형의 배상은 해당 사건의 특정한 환경에 비추어 공정하게 다루기 위한 법원에 의해 처리되며, 이것은 형평성 있는 배상으로 인식된다. 이러한 사실에 따라 형평성에 대한 믿음이 관습적으로 될 경우, 법원은 그러한 사실을 고려하기 위한 선택권을 가지며 이로써 가장 공정하고 적절한 결과를 보장할 수 있다.

따라서 균등론의 원칙과 같은 형평성의 개념과 연관지어 보면, 아무도 해당 사건을 결정적으로 말할 수는 없게 된다. 물론 이러한 사건은 다른 사실(다른 기술적 수단 등)을 포함하지만, 동일한 결과를 초래한다고 인용하기 위해 동일한 수단임을 인정하기 위한 법원에 좀 더 유연성을 주게 된다.

균등론의 원칙의 적용은 두 요소의 적용을 의미한다. 첫 번째 요소로는, 특허가 허여될 수 있다는 균등론의 보호범위는 발명의 중대성과 해당 기술 내 기여의 정도를 평가하여 결정된다. 두 번째 요소로는, 허여된 균등론의 범위가 당해 발명과 비교된다는 것이다.

이러한 균등론의 적용범위를 살펴보자. 균등론의 발견은 사실과 이러한 사실과 관련하여 어떤 유형으로 발생하게 될 사실을 증명하여 결정하는 것이다.

전체적으로 발명이 균등하다고 해야 할 지, 본원발명의 각 구성요소가 침해품 내 구성요소와 대응되는 균등물이라고 해야 할 지에 대해서는 아직 과제로 남아 있다. CAFC의 심결에 대한 비교적 최근의 판례에 의하면, 균등론의 원칙은 전체적인 발명의 비교보다는 구성요소대 구성요소(element by element)에 의해 적용되어진다.

이러한 시도 하에 균등론의 원칙이 지지 받기 위해서 각 청구범위의 한계에 대해 파악해야 한다. 특히 균등론은 균등한 결과(result)와 기능(function) 뿐만 아니라, 균등한 수단(way)을 포함해야 지지를 받을 수 있다.

균등론의 원칙 하에 주장되어진 청구범위의 보호범위를 분석할 때, 그 선행 기술의 보호범위를 넘어설 수는 없다. 균등성의 여부를 판단할 때, 만일 침해품이 당해 발명의 주요한 균등부분과 대비될 지라도 그 주요한 균등 부분이 선행 기술의 보호범위의 경계를 뛰어 넘을 수 없다면 균등하다고 할 수 없다.

법원은 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates 사건에서 상기의 선행 기술과 균등론의 원칙을 강력하게 지지하였다. 즉 법원은, 이러한 사건은 균등론의 원칙 하에서 법적으로 보장받을 수 있는 보호범위라고 볼 수 없으며, 특허권자는 문언상 청구범위에 의하여 미국 특허청으로부터 허여된 범위의 외부에 있다고 한다.

결국 발명자의 입장에서 보면 선행 기술의 경계까지 자신의 발명의 내부에 포함시키는 것은 가능하며, 청구범위 내 허용되는 균등론의 보호범위를 한계 짓는 경계를

상징한다.

Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates 사건을 다른 법원은 균등론의 원칙 하에 청구범위를 균등의 보호범위인지, 아닌지 결정짓기 위한 판단과 미국 특허청에 의해 허용되는 보호범위의 외부에 있는 지 결정하는 도구의 역할을 한다. 이로써 가설적인 특허의 청구범위를 보다 가시화 시키며, 문언상으로도 침해품과 비교하여 그 보호범위 여부를 판단할 수 있는 한가지 방안을 제공한다.

만일 이러한 선행 기술과 관련한 균등의 보호범위 여부에 대한 안내자가 없다면, 특허권자에게 침해소송에서 균등론의 원칙 하에 그 보호범위를 부적당하게 선을 긋는 우를 범할 수 있게 된다.

① 출원경과기록

금반언의 개념은 균등론의 원칙의 적용에 대하여 제한을 가한다. 기본적으로 금반언의 원칙은 출원 명세서의 진행 동안 포기되었던 발명의 내용(일부 기술적 수단)을 특허권자가 균등론의 원칙 하에 다시 포획 못하도록 방지하는 역할을 한다.

즉, 출원경과기록에서 야기된 청구범위들의 수정 부분을 후에 침해 소송에서 청구범위의 보호범위 내로 확장시키려고 균등론의 원칙을 이용하려는 것을 방지하며, 이러한 예로 Hughes Aircraft Co. v. U.S. 사건에서 살펴볼 수 있다.

출원경과기록에 대한 논쟁을 분석할 때, 법원은 발명이 수정하고, 수정한 그 이유를 간파하여 해당 청구범위 수정의 목적과 본질을 명확하게 심사할 것을 요구한다.

청구범위의 수정 후 침해품의 보호범위를 포괄하기 위해 균등론의 원칙으로 확장하여 적용할 필요가 없는 청구범위의 구성요소나 형식과 직결된다면, 출원경과 동안에 수정이 된 청구범위라고 할지라도 균등론의 원칙으로 침해는 발견할 수 있다.

출원경과기록의 원칙으로 특허권자는 선행 기술을 극복하기 위한 출원경과 기간 동안에 제외된 발명(또는 기술적 수단)을 후에 청구범위 내에 포함시키기 위해 균등론의 원칙에 호소할 수 없다.

청구범위의 보호범위는 청구범위의 허여를 얻기 위해 선행 기술과 다른 부분 또는 추월하는 것을 특징으로 하는 때, 특허권자는 특허를 허여받기 위해 포기되었던 균등론의 원칙에 의한 기술적인 수단을 다시 포획할 수 없다.

출원경과기록의 원칙은 특허권자가 특허 명세서의 출원경과 기간 동안에 포기된 발명을 재복귀시키기 위해 청구범위에 변화시키려는 시도를 막는 역할을 한다. 금반언은 선행 기술에 기초를 둔 거절을 극복하기 위한 보정서와 의견서에도 적용된다.

또한 Hughes Aircraft Co. 사건에서 특허권자는 청구범위의 해석상 미국 특허청에 사전에 제출한 선행기술을 고려한 위치에서 벗어난 대립된 위치에 설 수 없다.

② 균등의 결정

일단 당해 특허가 균등론의 보호범위 내로 허여될 수 있다고 결정이 된다면, 상기 두 가지 요소의 두 번째 단계를 밟게 된다. 두 번째 단계에서 당해 침해품은 허여된 균등의 보호범위와 비교된다. 만일 허여된 균등의 보호범위 내에 서게 된다면, 침해로 결정된다.

균등여부의 결정을 위한 안내자는 Graver Tank의 심결에서 찾게 된다.(본 글의 '5-7) 미국 특허법 해석상의 균등론과 금반언의 원칙' 참조)

균등물을 구성하는 것은 선행 기술·사건의 특별한 환경·특허의 내용에 따라서 결정되어야 한다. 이 균등물은 모든 목적이나 모든 면에서 완전한 동일성을 요구하는 것이 아니다. 중요한 조건은 당업자의 수준에서 합리적으로 해당 기술적 수단으로 치환이 가능한가에 따라서 당해 특허의 보호범위 내부인가, 아닌가를 갈음하게 된다. 또한 고려사항으로 당해 특허 내에 이용된 성분의 목적과 다른 성분과 결합되었을 때 가지는 성질에 따라서 수행되어지는 기능이 주어져야 한다.

비록 Graver Tank 사건이 성분과 관련하여 조성물과 직결된 심결이 되었을지라도, 그 기준은 기계적인 장치나 그 구성요소에도 적용될 수 있음을 물론이다.

그러나 어떤 장치나 방법이 근본적으로 특허기술로부터 크게 변경되어 실질적으로 다른 방법으로 동일하거나, 유사한 기능을 수행할 때에는 문언적으로 청구범위 내에 속하더라도 오히려 균등의 원칙으로 인해, 당해 특허의 청구범위를 제한하게 되는 역균등(reverse doctrine of equivalents)의 법칙이 성립된다.

(3) 균등론에 대한 미국 판례

만일 청구항이 특허침해의 혐의를 받고 있는 방법, 조성물 또는 제품을 정확하게 그대로 묘사하고 있으면 그 방법, 조성물 또는 제품은 그 청구항을 침해한 것이 된다. 청구항의 구절들이 혐의 받은 물건 또는 방법을 묘사하고 있으면 그 청구항은 문언적으로 침해된 것이다. 만일 청구항의 어느 구절에 묘사된 요소가 혐의 받은 물건 또는 방법에 없으면 문언적 침해는 존재하지 않는 것이다.

비록 청구항이 문언적으로는 침해되지 않았더라도 균등론에 의거해서 그 침해를 인정할 수 있다. 균등론은 특허의 침해를 문언적 침해에 국한하는데서 오는 불합리한 결과를 막기 위해 법원에 의해 정립되었다. 발명가가 고용한 변호사가 해당 발명을 실시하는 여러 방법을 모두 특허출원서에 기재할 만큼 유능하지 못했다고 해서 발명가에게 불이익이 돌아간다면 이는 불합리한 것이다.

연방고등법원(모든 연방지방법원 또는 특허청의 심판에 대한 항소를 심판하는 법원)에 의하면:

“균등론은 문언적 침해가 없는 경우에 적용된다. 균등론에 의하면 혐의 받은 물건이나 방법이 문언적으로는 특허 받은 물건 또는 방법을 침해하지 않더라도 그와 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행함으로써 같은 결과

를 성취하는 경우에는 역시 특허의 침해를 인정할 수 있다.(Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 1950) 이 이론은 공평을 실현하기 위한 것이다. 특허된 물건을 완전히 똑같이만 만들지 않으면 얼마든지 특허권자의 허가 없이 유사한 물건을 만들 수 있다고 할 경우 특허권의 보호는 유명무실해진다는 것이 법원의 견해이다. 그리고 이 이론의 핵심은 특허에 관해 기만(欺瞞)행위를 해서는 안 된다는 데 있다.” (Hughes Aircraft Co. v. U.S., 1983)

연방고등법원은 이 이론의 적용범위를 대법원보다 약간 더 넓게 보아 “같은 결과”를 성취하는 경우뿐만 아니라 “현저히 같은 결과”를 성취하는 경우에도 특허의 침해로 인정하였다.(Perkin-Elmer Corp. v. Computervision Corp., 1984)

균등론에 의해서 특허권의 효력의 범위를 어디까지 인정할 것인가는 그 특허권의 해당 기술분야의 성격과 관련된 문제이다. 균등론에 의해 특허권의 효력을 선행기술에까지 미치게 할 수 없음은 물론이다. 해당 기술분야에서 개척자적 위치에 있는 발명에 대해서는 균등론이 넓은 범위의 효력을 인정할 것이다.(Hughes, 1983) 한편 조금씩 다른 발명이 몰려 있는 분야에서는 균등론에 의해 인정되는 특허권의 효력의 범위가 아주 좁을 것이다.

선행기술과 관련하여 특허권의 효력이 어느 정도까지 넓게 인정될 수 있는가를 연방고등법원이 심리하였다.(Wilson Sporting Foods Co. v. David Geofrey and Associates, 1942) Rich 판사에 의하면 특허를 문언적으로 침해하지 않는 물건이 특허된 물건과 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행하여 현저히 같은 결과를 성취한다 하더라도 이와 같이 균등론에 의해 주장되는 특허권의 범위가 선행기술을 포함하는 경우에는 특허의 침해를 인정할 수 없다고 한다. 균등론에 의해 확장되는 특허권의 범위는 선행기술까지를 포함시키지 못한다. 왜냐하면 특허출원인이 출원 당시에 특허청으로부터 특허 받을 수 없었던 권리를 추후에 균등론에 의해 주장할 수는 없기 때문이다.

균등론은 특허에 관련된 기만행위를 방지하려는 이론이다.(Graver Tank) 균등론은 특허권자가 출원 당시에 특허청으로부터 부여받을 수 없었던 권리를 부여하려는 이론이 아니다. 그러므로 발명가의 특허권의 범위를 한정하는 선행 기술은 균등론에 의한 특허권의 범위도 한정한다. (Hughes Aircraft Co. v. U.S., 1983)

Rich 판사는 청구항에서 언급한 권리의 범위가 넓어서 특허권 침해의 혐의를 받은 물건에까지 미치는 특허권을 가상해서 설명한다. 이 경우 균등론을 적용하려면 이 가상적 발명이 선행 기술로부터 예견되었거나 자명하지 않아야 한다. 이 가상적 발명이 선행 기술로부터 예견되었거나 자명한 사항이면 균등론을 적용하여 특허의 침해를 인

정할 수 없다.

Key Manufacturing Group, Inc. v. Micro Inc., 1991에서 연방고등법원은 선행기술과의 관련하여 인정되는 특허권의 효력의 범위를 다시 논의했다.

균등론의 적용범위를 논할 때 반드시 Wilson Sporting Goods 사건에서 가상적 발명에 관한 분석을 원용할 필요는 없으나 법원은 이 분석방법을 써서 선행 기술에 의한 균등론 적용범위의 한계를 인정했다.

위와 같은 평범한 이론이던 균등론을 연방고등법원은 더욱 난해한 문제로 만들었다. 문제의 난점은 균등론을 적용할 때 청구항을 어떻게 파악할 것인가에 있다. 특허 침해의 혐의를 받은 물건이 특허된 물건과 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행하여 현저히 같은 결과를 성취하면 특허의 침해가 인정된다. 그러나 위의 판단을 할 때 청구항을 전체적으로 파악할 것인지 또는 요소 하나 하나를 개별적으로 분석하여 파악할 것인지가 문제된 것이다.

연방고등법원이 전원합의부에서 문제에 관해 심판한 내용이 Pennwalt Corp. v. Durand Wayland, Inc., 1987에 담겨있다. Pennwalt 사건은 많은 반대의견을 불러 일으켰다. Bissell 판사는 Markey 법원장, Rich 판사, Davis 판사, Freedman 판사 등이 동조한 다수의견을 제시했다. Bennett 판사는 위와는 다른 세 판사가 동조한 반대의견을 내놓았다. Nies 판사는 다수의견을 지지하는 견해를 개별적으로 제출했으며, Newman 판사는 반대의견을 지지하는 논문을 제출했다.

다수 의견이 내린 결론은 균등론을 적용할 때 청구항의 요소 하나 하나를 개별적으로 검토해야 한다는 것이다. 어떤 요소가 혐의 받은 물건에 포함되어 있지 않으면 균등론에 의거한 분석이 시작되어 그 혐의 받은 물건이 문제된 요소와 등가의 요소를 포함하고 있는지를 검토한다. 만일 포함하고 있으면 혐의 받은 물건이 문제의 요소를 내포한 것으로 인정된다. 이 분석은 개별적으로 모든 요소에 대해 행해지게 된다. 혐의 받은 물건이 특허된 물건의 요소를 모두 갖추고 있으면 문언적 침해가 인정된다. 혐의 받은 물건이 특허된 물건의 요소를 일부는 그대로 나머지는 등가의 것으로 갖추고 있으면 균등론에 의거해서 특허의 침해가 인정된다.

단 하나의 요소라도 혐의 받은 물건에 전혀 포함되어 있지 않으면, 즉 그 자체든 등가의 것이든 모두 결여되어 있으면 특허의 침해를 인정할 수 없다. 그러므로 이와 같이 하나의 요소라도 혐의 받은 물건에 전혀 포함되어 있지 않으면 혐의 받은 물건이 설혹 전체적으로 보아 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행함으로써 현저히 같은 결과를 성취하여도 특허의 침해를 인정할 수 없다는 것이다.

이 원칙이 어떻게 작용되는가를 보기 위해서 Pennwalt 사건을 살펴보자. 이 사건에서 문제된 발명품은 선별기로서 과일 등을 선별하는 데 쓰는 기계이다. 해당 특허의 청구항은 다른 여러 요소와 함께 “위치를 알리는 장치”를 열거하였다. 혐의 받은 기계는 특허 받은 기계의 요소 중 이 요소를 제외하고는 모두 갖추었다는 것이 법원에 의해 인정되었다.

법원은 또 혐의 받은 기계가 위치를 알리는 기능 또는 그에 해당하는 기능의 어느

것도 수행하지 않는다는 사실을 확인했다. 그리하여 먼저 지방법원이 특허의 침해가 없다는 결론을 내렸다. 균등론을 적용하여 특허의 침해를 인정하려면 혐의 받은 기계에 특허 받은 물건의 요소 중 하나라도 결여되었으면 그에 해당하는 등가의 요소라도 있어야 한다고 지방법원은 심판했다. 그렇지 않으면 균등론에 의해서도 특허의 침해를 인정할 수 없기 때문이다.

고등법원은 이 재판을 지지하면서 다음과 같이 심판했다:

지방법원이 요소 하나 하나를 개별적으로 검토하는 방식을 채택하고 이 사건에서 균등론을 적용해도 특허의 침해를 인정할 수 없다고 심판한 것은 옳았다. 왜냐하면 혐의 받은 기계는 Pennwalt의 발명품과 현저히 같은 기능을 수행하지 않기 때문이다. 여기서 Durand-Wayland의 선별기가 문제된 특허의 청구항에 기재된 하나의 기능 또는 그와 등가의 기능을 수행하지 않는다는 사실을 확인하는데 있어서 지방법원이 명백히 오진을 범하지 않은 이상 지방법원이 특허의 침해를 부인한 심판은 인용되어야 한다.(Pennwalt, 1987)

연방고등법원의 다수의견이 균등론을 적용함에 있어 요소별 검토방식 쪽으로 기울고 있다는 조짐은 Perkin-Elmer v. Westinghouse, 1987)에서도 볼 수 있다. 이 사건에서도 요소별 검토방식이 채택되었다. 혐의 받은 물건이 특허 받은 물건의 한 요소를 가지고 있지 않으므로 문언적 침해는 없었다. 또한 혐의 받은 물건이 이 요소와 등가의 요소조차 갖추고 있지 못하므로 균등론을 적용하더라도 특허의 침해를 인정할 수 없었다. 그럼에도 불구하고 Markey 법원장은 다수 의견에 가담하면서 각주 5에서 자신은 특허된 물건과 혐의 받은 물건이 특허 받은 물건의 요소를 등가에 해당하는 것조차 가지고 있지 않음으로 말미암아 전체적으로 특허 받은 물건과 등가의 것이 될 수 없게 되는 경우에만 옳고 주장했다. Markey 법원장은 Pennwalt에서 다수의견에 가담하고 나서도 Allied Corp. v. U.S. ITC and Hitachi Metals, 1988에서 이 견해를 분명히 재확인하고, 그 법적 근거를 Perkin-Elmer와 Pennwalt에서 들고 있다.

Pennwalt 사건에서는 재판부의 반대의견도 만만치 않았다. 반대의견은 청구항을 전체적으로 비교하는 방식을 주장했다. 이 견해에 의하면 이 사건에서는 혐의 받은 기계가 위치를 알리는 장치에 해당하는 것을 갖추었는가를 볼 것이 아니라 두 기계가 전체적으로 보아 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행함으로써 현저히 같은 결과를 성취하는가를 보아야 한다고 한다.

Pennwalt는 종래의 연방고등법원 판례와 어긋나는 셈이어서 균등론의 적용에 관하여 적지 않은 혼란을 초래했다. 전술한 Hughes는 균등론의 적용시 두 개의 물건을 전체적으로 비교하는 방식을 주장한다. 만일 어느 특허의 청구항이 구멍 뚫린 두 개의 철판과 그 구멍을 통과하여 이들 철판을 조이는 나사를 묘사하고 있다고 하자. 또 이 특허를 침해한 혐의를 받은 물건은 두 개의 철판을 용접에 의해 부착시켰다고

하자. 이 경우 혐의 받은 물건이 특허 받은 물건과 등가의 것이어서 특허를 침해했다고 볼 것인가가 문제되면, 요소별 비교방식을 택하는 Pennwalt는 위 용접이 나사못과 등가의 것인가를 묻게 될 것이며, 전체적 비교 방식을 취하는 Hughes는 혐의 받은 물건이 전체적으로 보아 특허 받은 물건과 등가의 것인가를 묻게 될 것이다. 그리하여 Hughes에 의하면 혐의 받은 물건이 비록 특허 받은 물건의 어느 요소와 결정적으로 다른 요소를 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행하여 현저히 같은 결과를 성취했다고 볼 수 있는 경우가 있는 것이다.

Hughes 식으로 혐의 받은 물건이 전체적으로 보아 특허 받은 물건과 등가의 것인가를 가리려면 혐의 받은 물건을 특허 받은 물건과 아울러 선행기술과도 비교해야 한다. 이 방식은 특허출원 내역에 의한 금반언의 원칙이 적용되는 경우에도 이용되었다. 혐의 받은 물건이 선행기술에 가까우면 그것은 특허 받은 물건과 등가의 것이라고 할 수 없다. 혐의 받은 물건이 특허 받은 물건에 더 가까우면 그것과 등가의 것으로 인정된 것이다.

이들 Pennwalt 이전에 적용되던 원칙들이 Hughes 사건에서 어떻게 적용되었는가를 보기로 하자. 1950년대에서 1960년대 초에 이르기까지 지구상의 특정지점의 상공에 정지궤도 통신위성을 띄우려는 노력이 있었다.

완전한 통신을 위해서는 안테나가 항상 지구 쪽을 가리키고 있는 위성이 필요했다. Hughes를 위해서 일하는 발명가 Williams는 회전에 의해 안정시킨 위성의 방향을 조정하는 방법을 고안하여 이 문제를 해결하였다. Williams의 방식에 의하면 지상요원이 보낸 신호에 의해 위성에 분출물이 생겨서 위성이 자전하면서 일정한 위치에 왔을 때 일정한 선택된 방향으로 압력을 주게 된다. 위성에 있는 감지기가 태양의 위치에 관한 자료를 탐지해서 지상요원에게 보내면 지상요원은 이를 통해 위성의 방위를 파악한다.

이러한 자료를 기초로 하여 지상요원은 위성에 신호를 보내고 분출물을 발생시켜 위성이 지구의 축과 평행한 축을 중심으로 자전하게 하며, 그리하여 위성의 안테나가 보내는 전파가 항상 지구를 향하게 한다.

이 발명에 관하여 특허출원이 있었으나 McLean 특허로부터 분명히 짐작될 수 있는 것이라 하여 거절되었다. McLean은 회전에 의해 안정되고 주위로 분출물을 발사함으로써 목표에 접근할 수 있는 우주선이다. 그 분출물은 적외선 감지기에 의해 작동한다. 그러나 McLean은 지구에서 위성의 위치를 조정하는 기능은 포함하고 있지 않았다. 지상에서 조정하는 장치를 추가하는 출원서 변경이 있는 후 특허가 부여되었다. 왜냐하면 McLean에는 이러한 장치가 결여되었기 때문이다.

Hughes 사건에서 특허침해의 혐의를 받은 위성은 S/E(저장후 작동) 우주선이었다. 이 우주선은 Williams가 발명한 위성과 아주 흡사한데, 다만 Williams 위성처럼 자료를 지상으로 보내서 분출물을 분사하는 횟수를 계산하게 하는 장치는 없었다. 또한 S/E 우주선은 지상에서 분사횟수를 계산해서 신호를 보내는데 따라 분출물을 발사하지도 않았다. 그 대신 S/E 우주선은 Williams 위성을 발명할 때에는 존재하

지 않았던 컴퓨터를 내부에 설치하고 정확한 분출물 분사횟수를 계산했다. 컴퓨터는 필요한 자료를 지상으로 보내지만 분출물은 지상에서 보내오는 신호에 따라 분사되지 않고 직접적으로 컴퓨터가 계산해 놓은 적합한 분사횟수에 따라 지상으로부터의 작동 명령을 받아 분사되었다.

그러므로 S/E 우주선은 분명히 Williams 특허를 문언적으로는 침해하지 않았다.

그러나 법원은 S/E 우주선이 Williams 위성과 등가의 것이라고 심판했다. 이러한 결론에 도달하기 위해 Williams 위성 S/E 우주선의 유사성을 선행기술인 McLean 우주선과의 관련에서 검토하였다. 법원은 Williams 위성이 S/E 우주선과는 7개의 공통점을 가졌고 McLean 우주선과는 2개의 공통점만 있는 것을 확인했다. 그리하여 S/E 우주선은 McLean 우주선보다는 Williams 위성에 훨씬 가깝다는 것이 확인되었다.

S/E 우주선과 Williams 위성의 유일한 차이점은 전자가 기본적으로 후자가 사용했던 우주선 조정방법을 컴퓨터를 이용해서 사용했다는 점뿐이라는 결론을 법원은 내렸다. 법원은 Williams 위성발명 후 개발된 컴퓨터는 Williams 발명에서 지상관제소가 하던 일을 우주선 내에서 처리할 수 있게 했다고 하며 Williams 발명 후 개발된 기술에 의해 이를 각색한다고 해서 특허의 침해가 되지 않는 것은 아니라고 판시하였다. 그래서 연방고등법원은 균등론을 적용함에 있어 혐의 받은 우주선을 전체적으로 Williams 위성과 선행 기술에 의한 우주선에 모두 비교했으며, 전체적으로 보아 혐의 받은 우주선이 특허된 우주선과 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행했다는 것뿐만 아니라 혐의 받은 우주선이 선행 기술에 의한 우주선보다는 특허된 우주선에 훨씬 흡사하다는 결론을 내렸다.

Pennwalt 사건에서의 다수의견은 지금쯤은 아마도 연방고등법원 판사들간의 소수의견으로 변했을지도 모른다. Pennwalt의 다수의견에 가담했던 Davis 판사는 작고했으며, 역시 다수의견에 가담했던 Markey 법원장의 요소를 개별적으로 검토한 결과 등가의 요소가 혐의 받은 물건에 없다고 인정되는 경우에는 그로 인해 혐의 받은 물건이 전체적으로 보아도 특허 받은 물건과 등가의 것으로 인정될 수 없는 경우라고 말한 바 있기 때문이다.

Pennwalt 때 다수의견에 가담했던 Rich 판사는 W. L. Gore & Associates v. Garlock, 1988 사건에서 “균등론을 적용하려면 혐의 받은 과정에 전체적으로 보아 현저히 같은 기능을 현저히 같은 방법으로 수행하여 현저히 같은 결과를 가져온다는 것을 증명하여야 한다”라고 말하고, 그 법적 근거로서 Pennwalt를 인용했다.

연방고등법원은 Corning Glass Works v. Sumitomo, 1989 사건에서 광선유도체에 관한 문제를 다루었다. 특허된 광선유도체는 첨가제를 렌즈의 중심부에 투여하여 렌즈 중심부의 굴절력을 높임으로써 렌즈 중심부의 굴절력이 가장자리의 굴절력보다 높게 만든 것이었으며, 특허 침해의 혐의를 받은 광선유도체는 렌즈의 가장자리 부분에 다른 종류의 첨가를 투여하여 렌즈 가장자리 부분의 굴절력을 낮춤으로써 렌즈 중심부의 굴절력이 가장자리의 굴절력보다 높게 만든 것이었다.

특허된 광선유도체의 요소는 첨가제를 렌즈의 중심부에 투여하는 것인데 혐의 받은 광선유도체는 렌즈의 중심부에는 아무 것도 투여하지 않았으므로 Pennwalt의 요소별 검토방식에 의하면 하나의 요소가 완전히 결여되어 있다고 피고는 주장했다.

Pennwalt에서 다수의견을 지지했던 Nies 판사는 균등론을 적용하면서 특허의 침해를 인정하였다. Nies 판사는 이른바 발명의 “요소”는 발명의 구조적인 요소뿐만 아니라 발명의 어떤 특징을 의미하며, 발명의 특징이 혐의 받은 물건에서 문자 그대로 또는 등가에 해당하는 것으로 발견되어야 하나 혐의 받은 물건에서 찾아지면 되고 반드시 똑같은 부분에서 찾아져야 하는 것은 아니라고 판시하였다. 법원은 그리하여 가장자리의 굴절력을 첨가제를 사용하여 낮추거나 중심부의 굴절력을 첨가제를 사용하여 높이는 것이 결국 균등한 방식에 해당하므로 특허의 침해가 있다고 하였다.

그렇지만 사건을 심판하는 재판부의 구성원이 누구냐에 따라 심판내용이 크게 달라질 수 있다. Julien v. Zeringue, 1989 사건에서 Bissell 판사(Pennwalt 사건에서 다수 의견을 직접 집필하였고 Archer 판사와 Michel 판사의 동조를 얻을 바 있는)는 Pennwalt 재판을 인용하면서 다음과 같이 말했다.

만일 청구항의 한정사항이 똑같이 또는 등가의 것으로서 혐의 받은 물건에 존재하지 않으면 침해가 있었다고 볼 수 없다.(Julien, 1989)

또한 Pennwalt 사건에서 소수의견에 가담했던 판사들이 재판부를 구성하면 청구항을 전체적으로 검토하는 방식이 채택될 가능성이 높다.

특허된 발명이 부품들의 결합으로 이루어진 어떤 장치일 때 특허의 침해가 있으려면 그 개개의 부품의 기능이 침해하는 장치에서도 따로따로 분리된 부속에 의해 수행되어야 하는 것은 아니다. 특허된 장치와 특허침해의 혐의를 받은 장치는 전체적으로 비교되어야 한다. (Sun Studs, Inc. v. ATA Equipment Leasing Inc., 1989)

Newman 판사는 이 원칙을 제시하기 위해 Hughes를 인용했고 Pennwalt에 대해서는 전혀 언급하지 않았다. Sun Studs 사건의 재판부를 구성하는 3명의 판사 중 Newman 판사가 Pennwalt 소수파 중 가장 그 의견을 강력히 주장하는 판사일 것이다. Bennett 판사도 Pennwalt의 소수파 중의 한 사람이었다. 다만, Friedman 판사만 Pennwalt에서 다수파 중의 한 사람이었다. 그러면 Sun Studs 재판은 Friedman 판사가 이 문제에 관해 입장을 바꾼 것을 뜻하는가? 시간이 해답을 제공해 줄 것이다. 지금으로서는 연방고등법원이 어느 범위에서 균등론을 적용하고 어떠한 사실관계가 있을 등가간계를 인정할 지 예측하기가 어렵다.

어떤 법이 타당할 것인가? 균등론은 형평의 이념을 달성하기 위해서 생겼다. 그러므로 균등론은 관련된 모든 사람에게 공평한 결과를 가져와야 한다. 이를 위해 관련

된 이해관계를 저울질 해 보아야 한다. 일반 공중은 어느 특허의 효력이 어디까지 미치는지 정확히 알 권리가 있다. 한편 발명가를 정당하게 보호하기 위해서는 특허의 범위를 이를 묘사한 언어에 구애됨이 없이 해당 분야의 기술적 측면을 고려해서 정해야 한다.

어떤 발명이 20개의 요소로 구성되었다고 하자. 이 발명특허를 침해한 혐의를 받는 물건이 이 중 19개의 요소를 그대로 갖추고 있다고 하자. 그렇지만 마지막 한 개의 요소는 그 자체를 물론 그와 등가의 관계에 있는 것도 갖추고 있지 않다고 하자. 그러나 특허 받은 물건과 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행하여 현저히 같은 결과를 성취한다고 하자. 이것이 그 특허된 발명에 속하는 것일까 아닐까? 아마도 대부분의 사람들은 이것이 그 특허된 발명에 속하는 것이라고 생각할 것이다. Hughes의 원칙에 따르면 특허침해가 있다는 결론에 도달할 것이다. Pennwalt의 원칙을 적용하면 균등론을 적용해도 특허침해가 없다는 결론에 도달할 것이다. Pennwalt에서 다수파에 속했던 Markey 법원장과 Rich 판사가 Allied Corp. 사건과 W. L. Core 사건에서 이 점을 분명히 하지 않았지만, Pennwalt가 특허침해 여부를 가리는데 있어 어느 정도의 영향력을 발휘할 지 가까운 장래에 밝혀져야 할 것이다.

균등론의 적용범위가 불분명하기 때문에 청구항을 기재할 때 발명과 더욱 긴밀히 협의하여 유사한 기술을 모두 생각해내고 그것들에 대해 구체적으로, 그렇지 않으면 일반적으로라도 기재해 놓을 필요가 있다. Williams 특허에서도 선행기술과 구별되는 발명내용이 보다 넓게 기재할 수 있었다. 발명내용을 넓게 기재하지 않았기 때문에 균등론을 주장할 수밖에 없었고, 소송이 더욱 복잡해졌던 것이다. 이 점은 Pennwalt 사건을 상기할 때 더욱 유의해야 할 점이다.

청구항을 새로이 기재하거나 넓은 범위의 청구항을 보정할 때에는 불필요하게 한정하는 일이 없도록 주의해야 한다. 될수록 넓은 범위의 청구항을 작성하려면 청구항의 어휘 하나 하나가 선행 기술로부터 구별하기 위하여 꼭 필요한 것인가를 점검해야 한다. 넓은 청구항을 작성하는 다른 방법도 궁리해 봄으로써 특허침해자가 그 다른 방법을 악용하는 일이 없도록 한다. 청구항을 작성하거나 보정할 때 깊이 주의함으로써 연방지방법원이나 특허기술사용의 허가를 받은 사람에게 나중에 특허침해 여부에 관한 어렵고 복잡한 문제를 제기하는 일이 없도록 해야 한다.

(4) 균등론의 적용

미국 내에서 침해의 증명은 특허소송의 복잡하고 불확실한 영역 중의 하나를 차지한다. 그 이유는 사안별(case by case)로 찾게되는 예외와 형평법을 가진 원칙이기 때문이다. 법원은 그 불확실성에 대해서 다음과 같이 언급하였다.

침해자가 중요한 변화를 초래하기 위해 당해 발명을 하는 대신에 단지 중요하지 아니한 변화를 만드는 일은 특허 발명의 절도(theft)나 악용에 해당되고, 균등론의

원칙을 적용하여 침해가 성립된다.

균등론의 원칙을 적용하는 것은 법칙이 아니라, 만일 대중이 특허 청구범위 내의 문언상으로 침해여부를 가릴 수 없고, 결코 의지할 수 없다고 판단될 때 적용되는 예외적인 사항이다.

균등론의 원칙은 침해 여부를 가리는 두 번째 수단의 역할을 하며, 청구범위의 보호범위 이상을 보호하기 위한 확장 도구로써 역할을 한다. 이때의 청구범위는 본래의 의도된 목적으로 나타나지 아니한다. 따라서 경쟁자 또는 침해자들은 그들의 침해행위가 당해 특허를 침해하는지 여부를 가리기가 어려울 것이다.

Slimfold Mfg Co. v. Kin Kepo, Inc. 사건을 다룬 법원은 유사하게 다음과 같이 말했다. 균등론의 원칙이 적용되길 바라는 당해 발명에 사기를 초래할 수 있다는 점에 따라서 중요하지 아니한 변화일 때만 적용된다. Read Corp. v. Portec, Inc. 사건을 다룬 법원에 의해 인식된 점을 다음과 같다. 선행 기술과 구별된다고 출원경과 기간 동안 특허권자에 의해 작성된 진술은 별개의 금반언을 만들지는 않는다.

균등론 원칙하의 침해와 관련된 법은 과도기적인 법칙이라고 다수가 방향을 제시한다. 균등론의 원칙 하에 침해여부를 가리기 위한 것은 사실적인 증거와 함께 3가지 동일 시도는 Grave Tank에서 나온 바와 같이 동일한 기능(function), 수단(way), 결과(result)가 필수적으로 동일하다고 할 때 침해를 인정하게 된다. 그 후에 두 번째로 해당 사건의 환경에 따라서 법원이 직권으로 균등론의 적용 여부를 가린다. 그리고 나서 세 번째로 문언상 침해가 아니며 균등론의 원칙에 대한 법원의 결정으로 형평성 있는 배상이 안 된다면, 배심원의 결정에 따른 사실의 논점에 따라 결정된다.

법원의 이 분야에 대한 해법은 균등론의 적용에 명확히 중요한 파장을 불러일으킬 수 있다.

* <참고자료>

(참고로 「특허와상표」 455호(1998.7.20)와 456호(1998.8.5)에 실린 “균등론 침해, 다시 혼돈의 시대로…”의 내용을 그대로 전제하면 다음과 같다.)

균등론침해에 관한 워너.젠킨슨 미국대법원결정(CAFC에서는 힐튼.데이비스사건)이 내려진 이후, 한때는 1천억엔의 손해배상평결이 나온 “리톤 vs 하니웰 사건”을 대법원에서, CAFC로 균등론 침해를 재심리하도록 환송했다. 그리고 CAFC는 최근, 설령 클레임의 보정에 금반언이 있을지라도, 그 부분에 또 균등론침해 여지가 있을지의 여부를 심리해야한다고 지법(地法)에 재차 환송하였다.(Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc., CAFC No. 95-1242, 1311, 1998.4.7결정)

사건의 경위는 다음과 같다.

리톤(Litton)사는 항공기의 오토자이로에 쓰이는 반사미러(鏡)를 제조하는데 쓰이는 빔.소스의 특허를 갖고 있었으나, 1985년 7월 2일에 특허재발행의 출원을 하여, 82건의 선행기술을 開示했다. 그 직후에 재발행절차에 대해 제3자가 항의하여, 프로테스트는 그것들 안에도 Laznovsky논문을 포함하는 2건의 문헌에 의해 동 특허는 무효라고 주장했다. 그리고 심사관은 이들 문헌을 기초로 거절이유를 통지하였다.

Litton사는 클레임을 보정하고, 일부의 종속클레임에서 이온.빔을 「카우후만타이프의 이온.빔」으로 하고, 다시 82건과 Laznovsky 논문 등 함께 83건의 문헌을 분석하고, 특허성이 있다고 주장했다.

그러나 심사관은 최종거절을 내렸는데, Litton사는 카우푸만타이프를 쓰는 것으로 「예기치 않은 효과가 있다」고 주장하고, 계속출원을 했으나 심사관은 최종 거절하였다. Litton사는 모든 클레임은 카우프만타이프라고 해석해야한다고 주장하고, 다시 3개의 宣言書(declaration)를 제출하여 예기치 않은 효과가 있다고 하였다.

그러나 심사관은 또 거절을 유지하였으므로, Litton사는 다시 83건의 문헌의 상세한 분석을 제출(3번째)하고, 또 선언서도 제출하였다. 심사관은 전화 인터뷰를 하여 모든 클레임을 카우프만타이프라고 해석하는 것으로 하여 허가하겠다고 전했다.

이에 대하여 1987년에 Litton사는, 심사관의 판시를 특허법 제 112조의 클레임 기재불비의 문제라고 해석하여, 가장 넓은 클레임 1에 카우프만타이프의 한정을 추가하여, 재발행특허 32,849(이하 849특허)가 허여 되었다.

Litton사는 이 849재발행특허를 갖고 Honeywell사를 특허침해소송으로 제소하였다. 지법에서는 배심원은 균등론 침해를 인정하고, 손해배상은 약 1천억엔, 다시 고의침해까지도 인정하는 평결을 냈다. 그러나 법관은 불공정행위에 의한 특허권 행사불가라고 판결했다. Litton사가 CAFC(연방항소법원)에 항소한 결과, 地法의 특허행사불가를 파기하고, 배심원의 균등론 침해를 지지하였으며, 손해배상은 파기하고 심리를 다시 하도록 결정했다.

그래서 Honeywell사가 대법원에 상고하였는데, 워너 젠킨슨 사건을 기초로 균등론 침해의 수정을 하도록 CAFC에 환송하였다는 것이 이 사건의 전말이다. CAFC는 Newman, Radar, Bryson으로된 패널을 구성하고, 다음과 같이 결정했다.

1. 클레임의 해석

Litton사는 본 재발행특허의 클레임의 카우프만타이프의 이온.빔이란 광역빔, 多數孔, 그리드.이온.빔(源)을 가지는 것이라면 어떠한 것이라도 좋다고 주장하고 있으나, 이것은 출원포대 금반언원칙에 모순되며, 결론적으로 카우프만타이프의 이온.빔인 바, 그것은 핫와이어.캐소드, 어노드, 그리드 및 마그네트의 네 가지 구성요건으로 되는 것으로 해석한다.

2. 문언침해

Honeywell사의 프로세스는 핫와이어.캐소드를 갖지 않으므로 문언침해는 아니라는 지법의 JMOL판결을 지지한다.

3. 균등론 침해

후술하는 바와 같이, 「카우프만타이프의 이온.빔」이라는 점에 대해서는 금반언을 구성한다고 인정한다. 그 경우, Honeywell사는 워너.젠킨슨 대법원사건의 판시에 의해, 카우프만타이프라는 한정에 대해서는 균등론은 일체 없다고 주장하고 있다.

먼저 이 점을 분석하는데, 균등론은 엘리먼트.바이.엘리먼트(요소 대 요소 ; element by element)로 결정해야 한다는 것은 동 대법원의 판결에서도 분명하다. 배심원은 균등론침해가 있다고 평결했을 때, 클레임해석에 대해서, 카우프만타이프의 이온.빔에 대해서 「어떠한 광역빔, 다수공, 그리드.이온.빔(源)을 가지는 것도 포함한다」고 하는 지침을 주어 평결하였다. 그러나 전술한 것처럼 이것은 틀린 것이며, 틀린 지침을 기초로한 균등론 침해의 평결은 기각되어야 한다.

따라서 반려된 地法에서는 (1)후술하는 출원포대 금반언 원칙을 기초로한 균등론침해가 있었는지 여부, (2)선행기술은 균등론침해를 배척하는 것이었는가의 여부를 심리하지 않으면 안된다.

4. 출원포대 금반언의 원칙

대법원의 워너.젠킨슨 사건은 출원포대 금반언 원칙을 미소하게 변경했다. Honeywell사는 클레임을 보정하여 금반언을 형성한 경우는 그 보정점에 대해서는 균등론은 일체 적용할 수 없다고 주장하고 있다. 그러나 만일 그렇다고 한다면 특허 후에 개발된 기술이라도 균등론으로 커버된다고 한 대법원의 판결과 모순이 되게 된다.

CAFC의 동 판결의 해석에 의하면, 대법원은 금반언 후의 균등론의 적용을 이처럼 변경한 것은 아니고, 종래와 같이 금반언이 있었던 경우에는 클레임 보정에 의해 拋棄된 主題를 다시 취득(리캡처)하는 것은 불가하다고 판시한 것에 불과하다. 즉, 금반언이 있었다 하여 보정사항의 해석은 그 문언범위에만 머무는 것은 아니다.

워너.젠킨슨 사건에서도 대법원은 에스토펠(금반언)을 인정한 것이 아니고, 그것이 있었는지 여부를 심리하도록 CAFC에 환송하고, CAFC는 다시 地法에 환송하였다. 그리고 대법원의 판시를 주의 깊게 읽어보면, 대법원은 금반언의 적용에 대해서 특별히 변경한 것은 아니라는 것이 분명하다.

5. 849재발행특허의 심사과정

→ 보정경위에 대해서는 전개 참조

6. 「카우프만타이프」보정 영향

이 보정이 特許性에 관한 것이었나 여부를 분석한다.

리튼사는 이 보정은 미국특허법 제112조 제2 페러그라프의 클레임 불비를 시정하기 위한 것으로, 이러한 보정은 특허성 때문은 아니라고 주장했다. 확실히 제112조의 기재불비나 실시가능성(보통 objection이다)에 관한 보정은 선행기술에 관한 것은 아니나, 여기서의 보정은 발명의 정의에 관한 거절에 관한 것이다. 또 이 거절은 통상 선행기술을 기초로 거절을 다투게 된다. 사실이 사건에서도 심사관은 발명을 그와 같이 정의하지 않으면 선행기술로부터 自明(용이)에 의해 거절한다고 표명하고 있다. 따라서 이 보정은 特許性에 관한 것이었다고 결론한다.

7. 금반언의 범위

「카우프만타이프」의 보정은 특허성에 관한 것이었으므로 금반언을 구성한다고 결론한다. 그러나 전술한 것처럼 금반언이기 때문이라 하여 균등론이 전혀 적용되지 않는 것은 아니다. 이 경우 적용범위는 특허권자는 그 선행기술로부터 특허가 되지 않는 범위에 대해서까지 균등론을 적용할 수 없다(Pall Corp v. Micron Separation Inc., 36USPQ2d 1225, Fed Cir.1995).

즉 선행기술과 동일하던가, 그것에 대한 사소한 변경(trivial variation)은 균등론으로 커버될 수 없다. 그런데 이 관점에 따라 본건을 분석하면, 심사관은 Honeywell사의 中空캐소드나 RF이온빔과 동일한 선행기술을 인용례로서 적용한 것은 아니므로, 카우프만타이프의 보정은 이 점까지는 금반언은 아니라고 말한다. 그러나 금반언은 이것만으로 결정되는 것은 아니다.

Litton사가 개시한 83건의 문헌에는 상기의 中空캐소드나 RF이온빔을 개시하고 있는 것이 있었다(73번째의 문헌). 금반언은 심사관이 의존한 문헌 뿐 아니고 심사관에 제출된 모든 문헌에 대해서 적용하는 것이다.

그렇다면 남은 문제는 Honeywell사의 제품이, 이 문헌에 開示된 것에서 「사소한 변경(trivial variation)」정도의 기술이었는데가이다.

이것은 사실인정의 문제이므로 地法에 환송한다. 혹시 地法이 이 점까지는 금반언이 적용되지 않는다고 인정한다면, 다시 균등론침해의 유무를 결정해야만 한다.

8. 州法상의 문제

Litton사는 다시, Honeywell사는 Litton사의 타사와의 계약에 위법이 있다고 주장하고, 배심원은 Honeywell사에 「불법수단」이 있었다고 인정했다.

그러나 배심원의 특수평결에는 무엇을 가지고 「위법수단」이라 인정했는지 불명확하다. 배심원은 혹시 특허침해행위를 위법행위로 인정했는지도 모르고, 이 점을 환송하므로 이 州法문제에 대해서도 환송하기로 한다.

이상과 같이, CAFC는 금반언의 범위에 대해서는 선행기술 내지 그것으로부터의 「사소한 변경」에 그친다고 판시 했다.

이에 의해 침해를 회피 가능한 설계변경도 그 범위에 그친다고 보고, 보정의 의한 금반언은 실질적으로 거의 의미가 없다고 보았다. 대법원은 워너.젠킨슨사건에서 금반언이 존재한 경우는 일체 재획득은 인정하지 않는다는 취지의 판시를 하고 있는 듯이 보이나, CAFC의 이 패널의 법관의 해석에서는 재획득은 매우 한정되어 있고, 균등론 침해는 다시 혼돈의 시대로 돌입하였다고 말한다.

한편 일본의 최고재판소(日대법원)는 선행기술로부터 용이한 범위는 특허침해는 아니라고 판시했으나, 미국의 CAFC는 금반언이 존재한다 하여도 선행기술과 동일하던가 또는 그것의 「사소한 변경」의 범위에만 균등론침해가 아니고, 그 이외는 균등론침해는 적용되며 이것에 의하면 금반

언의 유무에도 불구하고, 선행기술로부터 용이한 범위라도(사소한 변경은 넘어서고 선행기술과는 다른 범위), 침해가 될 가능성을 남기고 있고, 美.日 兩國에서는 완전히 침해의 범위가 다르다는 것이 명확해졌다고 할 수 있다.

클레임 해석은 법률상 문제이며, 배심원(사실문제에 대한 결정권이 있음)이 결정할 사항이 아니라는 대법원의 마크맨 사건(Markman v. Westview Instrument Inc., 116SCT(1384, 38 USPQ2d 1461, 1996년)의 기억이 새롭다.

따라서 지법에서의 법관의 해석을 CAFC가 비평할 때에는 원칙적으로 전면적인 수정(De novo)의 기준이 된다. 그러나 클레임해석 때에 전문가 증언을 참고하는 등, 사실인정 사항에 가까운 문제가 포함되면 그것을 CAFC가 비평할 때, 전면적으로 다시 시작해야 하는가, 혹은 명백한 판단의 그르침이 있는지 여부(법관 사실인정이나 결정을 비평할 때 쓰이는 기준)는 지금까지 CAFC 내부에서 서로 의견이 갈리고 있다.

그래서 CAFC는 전원합의체에서 이 사건을 검토한 결과, 클레임해석은 설령 사실 인정적 문제가 내재돼 있어도 CAFC는 전면적 재시작(de novo)의 기준에서 해야 한다고 결정했다.(Cyber Corp v. FAS Technologies Inc., CAFC Nos, 96-1286, 1287, 1998년 3월 25일).

사건의 경위는 다음과 같다.

FAS사는 반도체웨이퍼스에 쓰여지는 미국특허 제5,167,837(이하 837특허)호를 갖고 있었는데, 이것에 대해 경쟁기업인 Cyber사는 837특허가 무효이며, 침해가 아니라는 확인소송을 제기했다. 재판에서 법관이 전문가 증인의 증언을 참고하여 클레임 해석을 한 후, 배심원은 특허는 유효하며 특허침해가 있고, 게다가 침해는 고의라고 평결하였고, 법관은 이것을 판결했다. 그러나 법관은 FAS사가 요구한 변호사비용 지급을 부인했으므로 양측이 CAFC에 항소했다. CAFC의 담당패널은 Radar, Mayer, Plager의 3인이었는데, 지법 판사의 클레임해석을 전면적으로 다시시작(De novo)해야 하는가(법관혼자가 전부를 해석하였다면 당연히 작용됨), 혹은 전문가증인의 증언을 참고로 한 본 건의 경우는 명백한 그르침(clearly erroneous)의 기준에서 해야 하는가에 대해서 CAFC에 있어서 패널에 따라 의견이 달랐으므로 CAFC 전원합의체(온뱅크)에서 결정해야한다고 제안하고, 온뱅크 재판을 하였다.

온뱅크는 다음과 같이 분석하고, 결정을 내렸다.

먼저 마크맨 대법사건을 분석하면, 그 중에는 클레임 해석을 공판에서 증거(자료, 증언 등)를 참고하여 결정한 경우는 법과 사실의 중간적이 sans제라고 기재하고 있고, 순전한 법 문제라기보다 중간적 문제로서 다루고 있는 것으로 보인다. 그러나 이것은 클레임 해석이 종래의 전통적인 「법 혹은 사실(law or fact)」이란 두 가지 카테고리 나누기 어렵다는 것을 표현한 것으로, 클레임의 해석이 중간적 문제라고 판결한 것은 아니다. 대법이 클레임 해석은 순전한 법상의 문제라고 했던 것은 전문가 증언의 역할의 다음 분석으로도 명확하다.

즉, 그 분석에 의하면 대법은 전문가 증언의 신빙성(credibility)을 결정하는데 배심원의 역할이 중요하다는 것은 충분히 이해하고 있는데, 클레임 해석에 있어서는 명세서나, 파일레퍼(File wrapper)의 비중 쪽이 어느 정도 높고, 증인의 신빙성 문제는 좀더 낮다고 한 것이다. 이처럼 클레임의 해석은 「서면증거」의 해석이며, 이것은 법관W고의 사항으로, 이 경우 항고에서의 비평(review)은 전면적인 재시작(De novo)이다.

이상과 같이 CAFC는 온뱅크로 결정했으나, 각 Judge는 각기 독자의견을 다시 언급하였다.

플래거, 브라이슨

양 Judge는 온뱅크 의견에 전면적으로 동의하고 있고, 애초부터 클레임 해석에서 다른 문헌이나 전문가 증언의 의견을 참고하는 것은 전통적인 의미에서 「사실인정(fact finding)」이란 실질적인 것이며, 또 전면적인 재시작(De novo)이라도 Judge는 클레임 해석에는 당연 무게가 있다는 것을 보여주고 있다. 양 Judge는 클레임 해석은 완전한 법의 문제라는 결론에 찬동하고 있다.

메이어, 레이더, 뉴만

이들 3명 Judge는 온뱅크의 결론에 한편으로 찬성은 하지만, 마크맨 사건에서는 대법의 클레임 해석은 「완전한 법상의 문제」라고 까지는 결론하고 있지 않다고 반론하고 있다. 또 전면적인 재시작(De novo)의 비평기준에 의해, 클레임 해석은 CAFC에 오지 않으면 최종결정 되는 것이 없으므로, 지방법원에서의 해석불안정이 생기는 현상을 지적하고 있다.

이상과 같이 CAFC는 온뱅크에서 클레임 해석의 비평(review)은 전면적 재시작이라고 결정했으나, 아직껏 Judge 사이에는 미묘한 차이가 존재하고 있다.

또 명백한 그르침의 기준에서는 상당한 그르침이 없는 한 지방법원의 클레임 해석이 지지되지만, 전면적 재시작(De novo)이라면 엄격한 정밀조사가 이루어지므로, 클레임 해석은 CAFC가 비평하기까지는 어떻게 귀결될지 알 수 없음을 시사하고 있다.

- 끝 -

[참고문헌]

- 박대진, 「개정 특허청구범위 다항제」, 1991
- 박대진, 「특허청구범위의 작성과 회피설계」, 1997
- 박준국, 「미국특허실무」, 1995
- 이병균, 「특허심판의 쟁점과 사례」, 1993
- 특허청심사조정과, 「다항제에 관한 심사기준(안)」, 1991
- 국제특허연수원, 「특.실 심사기준」, 1993
- 田邊 徹, 윤동렬·이선희 역, 「영문특허 100의 상식」, 1996
- 정연용, 「특허신서」, 1998
- 최선배, 「법조문별대법원판결요지집 - 특허법」, 1996

박양수, 「지적소유권법에서 명세서작성까지」, 1997

「특허청구범위란 무엇인가?」

「미국 특허법 실무」

Jeffrey G. Sheldon, 「How to Write a Patent Application」, 1992